課程名稱：刑法11

00:00:04 - 00:00:06
好，我們今天要來看的是第六章。

00:00:07 - 00:00:10
同學你們看我的眼睛，左眼還是紅紅的。

00:00:10 - 00:00:10
沒事。

00:00:10 - 00:00:13
那個同學看的不用覺得害怕或怎麼樣。

00:00:13 - 00:00:22
那個我上次帶墨鏡上全程，因為上禮拜剛手術完，真的很可怕，左眼整個變血輪眼，所以上禮拜帶墨鏡上全程。

00:00:22 - 00:00:24
現在的話已經好很多了啦。

00:00:24 - 00:00:28
雖然左眼還是有一些出血，但是那個狀況已經好很多了。

00:00:29 - 00:00:33
上禮拜帶墨鏡真的是怕同學看到覺得恐怖啦。

00:00:33 - 00:00:35
所以這個沒辦法。

00:00:35 - 00:00:42
好，我們今天就來看到第六章，這個小單元，不法跟罪責之外的可罰性要件。

00:00:42 - 00:00:44
這個單元我們很快就會講過去。

00:00:44 - 00:00:48
因為這個單元裡面所涉及的很多條文，以後呢，我們在分則都會去講到。

00:00:49 - 00:00:50
這個在講什麼呢？

00:00:50 - 00:00:54
我們第一堂課畫圖啊，講三階論，該當違法有責。

00:00:54 - 00:01:00
這一章，這個單元在講的是，有些犯罪的成立要件。

00:01:00 - 00:01:02
要件，他在罪責的後面。

00:01:02 - 00:01:06
也就是結束之後，等於有點像第四階段那個概念，瞭解嗎？

00:01:06 - 00:01:08
就該當違法有責結束之後。

00:01:08 - 00:01:11
在罪責的後面，才要去審查的。

00:01:12 - 00:01:15
這個叫做不法跟罪責之外的可罰性要件。

00:01:16 - 00:01:17
放在三階之外。

00:01:18 - 00:01:21
也就是該當違法有責都結束之後。

00:01:21 - 00:01:23
我們才會去討論的東西。

00:01:23 - 00:01:24
好，有什麼呢？

00:01:25 - 00:01:27
第一個叫做客觀處罰條件。

00:01:27 - 00:01:29
這個東西在分則比較容易會遇到。

00:01:30 - 00:01:31
客觀處罰條件。

00:01:31 - 00:01:33
我們講啊，客觀處罰條件的概念是這樣子。

00:01:34 - 00:01:37
這個東西它不是不法要件。

00:01:37 - 00:01:39
它跟不法沒有關係。

00:01:39 - 00:01:40
也就是它跟法益性還沒有關係。

00:01:41 - 00:01:43
第二個，它跟罪責也沒有關係。

00:01:43 - 00:01:46
也就是說呢，它跟期待可能性也沒有關係。

00:01:47 - 00:01:49
這個東西既無關不法，也無關罪責。

00:01:50 - 00:01:59
立法者設置這個要件，純粹是從形式政策的角度來說，想要節制國家的刑罰權所設置的一個要件。

00:02:00 - 00:02:02
這個東西我們叫做客觀處罰條件,好,所以我們說了哈,不法跟罪責之外的可罰性要件。

00:02:09 - 00:02:12
這個東西無關不法,也無關罪責。

00:02:13 - 00:02:17
純粹是啊,國家基於其刑事政策的考量所設置的一個可罰性條件。

00:02:18 - 00:02:21
這個東西呢,叫做客觀處罰條件。

00:02:21 - 00:02:23
它最大的特色是什麼呢?

00:02:24 - 00:02:25
故意對它不用有認知。

00:02:25 - 00:02:26
知道嗎？

00:02:26 - 00:02:29
這它最大的特色，故意對它不用有認知。

00:02:29 - 00:02:34
也就是這個東西啊，只要客觀上存在就夠了喔。

00:02:34 - 00:02:36
故意不用對它有認知，知道嗎？

00:02:36 - 00:02:40
只要這個東西它客觀上存在就夠了。

00:02:41 - 00:02:43
所以各位啊，客觀處罰條件是什麼意思？

00:02:44 - 00:02:45
我舉一個極端的案例。

00:02:46 - 00:02:47
我舉一個極端的案例。

00:02:47 - 00:02:53
像比如說刑法227，這個條文不是講說跟未滿14歲的人發生性關係嗎，對不對？

00:02:53 - 00:02:53
來各位。

00:02:54 - 00:02:58
如果我們說那個未滿14歲是客觀處罰條件，那代表什麼意思？

00:02:59 - 00:03:04
代表行為人在跟那個少女發生性關係的時候，不用知道她未滿14哦。

00:03:04 - 00:03:05
不用哦。

00:03:05 - 00:03:08
只要這個少女客觀上未滿14，就夠了哦。

00:03:09 - 00:03:16
就算行為人說，他騙我啊，他騙我說他17啦，他也穿著高中制服啊，看起來就像高中生啊，誰知道他騙我才國中。

00:03:17 - 00:03:21
這樣的情況，假設你說17的年齡是客觀主條件，這看有沒有用？

00:03:22 - 00:03:23
沒有用欸。

00:03:23 - 00:03:26
客觀上滿14，客觀上未滿14，就算欸。

00:03:27 - 00:03:27
所以我們講，客觀處罰條件的特

00:03:30 - 00:03:31
色就是這樣子。

00:03:31 - 00:03:35
這個東西行為人主觀上不用對它有認知，不用喔。

00:03:36 - 00:03:39
客觀上這個東西存在，就當作條件成就，犯罪就成立了。

00:03:39 - 00:03:44
這個東西叫做客觀處罰條件。

00:03:45 - 00:03:45
好。

00:03:46 - 00:03:50
所以客觀處罰條件我們說它最大的特色，不需要行為人對它有認知。

00:03:51 - 00:03:54
同時呢，它也是罪疑惟輕的例外。

00:03:55 - 00:03:56
這個一般的犯罪審的要件啊。

00:03:56 - 00:03:59
不能證明的時候，我們會對被告做有利的解釋。

00:03:59 - 00:03:59
好。

00:04:00 - 00:04:02
是客觀處罰條件並沒有這樣的特性。

00:04:03 - 00:04:05
來，接著它的功能，

00:04:06 - 00:04:09
客觀處罰條件的功能是什麼呢？

00:04:09 - 00:04:10
你想喔，

00:04:11 - 00:04:12
想像上來說，

00:04:12 - 00:04:20
如果你把那種行為人對他有沒有認知很難證明的東西，都解釋成客觀處罰條件的話，

00:04:20 - 00:04:22
那對實務工作者來講是不是會覺得很高興？

00:04:23 - 00:04:25
這樣就可以不用去證明行為人對他有沒有認知嘛，

00:04:25 - 00:04:26
對不對？

00:04:26 - 00:04:35
所以如果我們把某些行為人主觀上對他有沒有故意很難證明的東西，我們都說他是客觀處罰條件的話，

00:04:35 - 00:04:37
我們如果這樣做，那會導致什麼結果？

00:04:37 - 00:04:39
刑罰權被擴張的結果，

00:04:39 - 00:04:41
可能會導致這個結果，

00:04:41 - 00:04:43
但是這並不是我們所樂見的，

00:04:43 - 00:04:46
這也不是客觀處罰條件原本的初衷。

00:04:47 - 00:04:49
因為如果你隨便這樣解釋的話，

00:04:49 - 00:04:54
那說好的刑法第12條說，行為非出於故意或過失不罰呢，

00:04:54 - 00:04:55
對不對？

00:04:55 - 00:04:57
所以這個解釋方向不可行，

00:04:57 - 00:04:57
知道嗎？

00:04:58 - 00:04:59
我們不能透過這個方式去解釋，

00:04:59 - 00:04:59
好。

00:05:00 - 00:05:05
所以我們講，客觀處罰條件它並不是一個擴張刑法事由，

00:05:05 - 00:05:06
而是什麼呢？

00:05:06 - 00:05:07
我們翻過來。

00:05:08 - 00:05:12
合理的解釋啊，叫做限縮刑法事由。

00:05:12 - 00:05:15
合理的解釋，叫做限縮刑法事由。

00:05:15 - 00:05:16
也就是啊，

00:05:16 - 00:05:16
你們想喔，

00:05:17 - 00:05:20
原本某一條罪，它有ABC三個要件。

00:05:21 - 00:05:27
那麼我們加上了豬這一個客觀可罰性的條件之後,會有什麼結果?

00:05:28 - 00:05:31
多加一個要件,是不是讓這一條罪的成立多一個篩選的門檻?

00:05:32 - 00:05:36
多一個要件,是不是讓這一條罪更難成立,因為多一個步驟,

00:05:36 - 00:05:36
對不對?

00:05:36 - 00:05:39
所以客觀處罰條件,合理的解釋叫什麼呢?

00:05:40 - 00:05:44
限縮刑法的事由，而不是擴張，

00:05:44 - 00:05:44
知道嗎？

00:05:44 - 00:05:45
而不是擴張。

00:05:45 - 00:05:47
所以啊，以後你們學證交法，

00:05:47 - 00:05:51
我記得證交法上面好像有類似這樣的見解。

00:05:51 - 00:05:52
就是說,

00:05:53 - 00:05:58
你內線交易犯罪所得超過不知道是一億還是多少，那個會有加重刑罰的規定。

00:05:58 - 00:06:00
我聽說有實務

00:06:00 - 00:06:00
講那個東西是客觀處罰條件。

00:06:02 - 00:06:05
那個說法從刑法學理來講一定有問題。

00:06:05 - 00:06:13
因為我記得那一派的說法是，內線交易的人他當初怎麼會知道說之後的所得會有多少，行為人不可能故意嘛。

00:06:13 - 00:06:14
他們說法是這樣。

00:06:15 - 00:06:18
但如果你用這個角度去解釋客觀主觀條件的話，那一定不對。

00:06:19 - 00:06:24
因為客觀主觀條件的初衷並不是要把那種難證明的東西都把它歸類過去，不是，知道嗎。

00:06:25 - 00:06:29
客觀主觀條件的初衷不是用來擴張刑法的，而是用來

00:06:30 - 00:06:32
來限縮刑法，所以那個解釋

00:06:34 - 00:06:35
一定會有問題。

00:06:35 - 00:06:38
好，接著我們來看怎麼判斷。

00:06:38 - 00:06:40
你看，刑法兩百多條條文。

00:06:41 - 00:06:46
我們要怎麼區分某個東西是構成要件要素，還是客觀處罰條件。

00:06:47 - 00:06:50
這個是很多第一次學刑法的同學會感到困惑的地方。

00:06:51 - 00:06:56
因為某個東西是客觀條件或者不是，法條本身不會直接跟你講。

00:06:56 - 00:06:58
所以這裡呢，我提供一個公式。

00:06:58 - 00:06:59
這個公式啊，很簡單。

00:07:00 - 00:07:00
要聽清楚。

00:07:01 - 00:07:04
我們怎麼判斷這個東西是不是客觀構成要件呢。

00:07:04 - 00:07:09
我們就把這一個疑似是客觀構成要件的東西遮住。

00:07:09 - 00:07:13
遮住之後啊，我們看法益侵害還存不存在。

00:07:14 - 00:07:15
就這麼簡單，知道嗎。

00:07:15 - 00:07:24
我們把疑似是客觀構成要件的東西遮住，然後遮住之後去看法益侵害還存不存在，所以什麼意思啊。

00:07:26 - 00:07:30
你把那個疑似是阻卻違法條件的東西遮住之後，如果法益侵害

00:07:33 - 00:07:35
就不存在了，那那個東西

00:07:35 - 00:07:37
百分之百是構成要件要素，它不會是阻卻違法條件。

00:07:40 - 00:07:46
反過來，如果你把那個東西遮住之後，法益侵害依然存在的話，那個東西

00:07:46 - 00:07:50
就有可能是阻卻違法條件，這是一個初步的判準，瞭解嗎。

00:07:52 - 00:07:55
所以我在下面放的兩個沒有爭議的案例。

00:07:56 - 00:07:59
客觀構成要件最沒有爭議的案例238。

00:08:00 - 00:08:01
詐術結婚罪，再來我們先來看條文，帶各位瞭解一下，這一條罪在罰什麼東西，因為這是一個非常了不起的犯罪。

00:08:07 - 00:08:09
考試啊，幾乎沒有考過。

00:08:09 - 00:08:15
近幾年考試有出現過這個條文，他在考你客觀構成要件，這一條罪的本身考試還真的沒有出現過。

00:08:15 - 00:08:17
好，238條說什麼呢？

00:08:18 - 00:08:25
他說啊，以詐術締結一個無效或得撤銷的婚姻。

00:08:25 - 00:08:28
那因爾之婚姻無效撤銷的裁判確定。

00:08:28 - 00:08:31
這個條文叫做詐術締婚罪。

00:08:31 - 00:08:32
好，這個在罰什麼呢？

00:08:32 - 00:08:32
我舉個例子喔。

00:08:33 - 00:08:35
假設我超喜歡我表妹。

00:08:35 - 00:08:38
我就跟我表妹說，那個表妹啊，我們結婚好不好？

00:08:38 - 00:08:39
假設我這樣問我表妹吼。

00:08:40 - 00:08:46
我每次講到這句話，都會覺得我不知道男同學女同學們你們怎麼想啊。

00:08:46 - 00:08:49
很多男生問女生要不要結婚，都會說你嫁給我好不好？

00:08:50 - 00:08:51
我絕對不會想說這種話。

00:08:52 - 00:08:53
為什麼結婚是嫁跟娶？

00:08:54 - 00:08:56
我覺得嫁跟娶的觀念我聽起來覺得不舒服。

00:08:57 - 00:08:59
嫁跟娶，那是一種男性中心的思維。

00:08:59 - 00:09:02
不知道什麼叫嫁給我，什麼叫娶進門。

00:09:02 - 00:09:07
那個不就是以男性為中心，甚至是男性的家族為中心的一種婚姻思維嗎？

00:09:08 - 00:09:14
我覺得婚姻的觀念應該是說，我們離開彼此的家，出去建立一個新的家，那個才合理吧。

00:09:15 - 00:09:16
怎麼會講嫁跟娶？

00:09:16 - 00:09:18
這觀念我聽得覺得不舒服。

00:09:19 - 00:09:22
從小有人叫我媽陳太太。

00:09:22 - 00:09:23
我聽得覺得不高興。

00:09:23 - 00:09:25
我想說奇怪，我媽沒有自己的姓嗎？

00:09:25 - 00:09:27
為什麼不是我爸被叫黃先生？

00:09:28 - 00:09:30
我覺得這種男性中心的思維對女性很不公平。

00:09:30 - 00:09:33
我自己身為男性，我覺得這個觀念我聽得覺得噁心，我不能接受。

00:09:33 - 00:09:34
所以。

00:09:34 - 00:09:36
這個男同學啊，以後想結婚。

00:09:36 - 00:09:38
不要說什麼嫁給我，不要講那種父權的話啦。

00:09:38 - 00:09:41
就講跟我結婚，就就好啦，不是。

00:09:42 - 00:09:44
我覺得聽起來比較舒服啦。

00:09:44 - 00:09:45
我真的不喜歡那種男性中心的觀念。

00:09:46 - 00:09:47
好。

00:09:47 - 00:09:47
我要講啊。

00:09:49 - 00:09:50
假設我超喜歡我表妹。

00:09:50 - 00:09:52
我就跟我表妹說，我們結婚好不好？

00:09:53 - 00:09:57
表妹就說，可是你是我表哥，我們真的可以結婚嗎？

00:09:57 - 00:09:58
我表妹又說啦，可是我...

00:09:59 - 00:10:00
嗯...

00:10:00 - 00:10:00
這個...去年...

00:10:01 - 00:10:02
才跟我男朋友結婚欸,

00:10:02 - 00:10:03
我已經結過了欸,

00:10:04 - 00:10:05
我們再結婚會有問題嗎?

00:10:05 - 00:10:05
我說安啦,

00:10:05 - 00:10:06
沒事啦。

00:10:06 - 00:10:07
第一個

00:10:07 - 00:10:09
我們是表兄妹啊

00:10:09 - 00:10:10
親上加親

00:10:10 - 00:10:11
法律是鼓勵的欸

00:10:12 - 00:10:12
當然可以結婚啊

00:10:13 - 00:10:14
而且你跟你男朋友登記過,

00:10:14 - 00:10:15
啊沒差啦,

00:10:15 - 00:10:15
我們表兄妹,

00:10:16 - 00:10:16
可以登記第二次,

00:10:17 - 00:10:18
這個是法律允許的例外,

00:10:18 - 00:10:19
你要相信我喔，

00:10:19 - 00:10:20
我是律師。

00:10:21 - 00:10:22
假設我表妹就這樣傻傻被騙了，

00:10:23 - 00:10:24
真的跟我登記結婚了。

00:10:24 - 00:10:25
這樣的話我犯的就是，

00:10:26 - 00:10:27
詐術締婚罪

00:10:28 - 00:10:28
就是238

00:10:29 - 00:10:29
知道嗎？

00:10:29 - 00:10:30
就是238。

00:10:30 - 00:10:30
好

00:10:31 - 00:10:31
那你要看喔,

00:10:32 - 00:10:34
詐術締婚罪不會就這樣成立喔,

00:10:34 - 00:10:35
還要怎麼樣？

00:10:36 - 00:10:39
那個婚姻無效或撤銷的裁判後來真的確定,

00:10:39 - 00:10:40
這樣犯罪才會成立

00:10:40 - 00:10:41
知道嗎？

00:10:41 - 00:10:42
要真的確定犯罪才會成立，

00:10:42 - 00:10:43
才會成立。

00:10:43 - 00:10:45
所以如果我表妹跟我結婚之後啊，

00:10:46 - 00:10:47
後來越想越不對勁，

00:10:47 - 00:10:48
自己去查法條,

00:10:49 - 00:10:50
發現蛤,

00:10:50 - 00:10:50
表哥騙我,

00:10:51 - 00:10:52
這根本是無效的婚姻啊。

00:10:53 - 00:10:53
這時候,

00:10:54 - 00:10:56
我表妹如果去法院確認說我們的婚姻是無效的,

00:10:57 - 00:10:58
最後那個裁判確定下來的話,

00:10:59 - 00:11:01
我才會成立詐術締婚罪。

00:11:01 - 00:11:02
來,

00:11:02 - 00:11:04
這一條罪的什麼東西是客觀處罰條件?

00:11:05 - 00:11:06
後面的那句話,

00:11:07 - 00:11:09
因而致婚姻無效或撤銷裁判確定,

00:11:10 - 00:11:12
那句話是客觀處罰條件,

00:11:12 - 00:11:12
知道嗎?

00:11:13 - 00:11:13
好,

00:11:13 - 00:11:14
依照我們的公式，

00:11:14 - 00:11:15
怎麼推導出來的？

00:11:16 - 00:11:17
你看喔，

00:11:17 - 00:11:19
如果把後面那句話，

00:11:19 - 00:11:22
因而致婚姻無效或撤銷的裁判確定，

00:11:23 - 00:11:24
你把那句話遮住,

00:11:25 - 00:11:26
這一條罪剩什麼？

00:11:27 - 00:11:30
剩下以詐術締結一個無效或得撤銷的婚姻。

00:11:30 - 00:11:31
那各位,

00:11:31 - 00:11:34
我光是用詐術締結一個無效或得撤銷的婚姻,

00:11:35 - 00:11:39
會不會侵害到這一條罪所要保護的那種婚姻秩序與善良風俗？

00:11:39 - 00:11:40
其實會，

00:11:40 - 00:11:40
對不對？

00:11:41 - 00:11:42
所以那個東西就是什麼呢？

00:11:42 - 00:11:44
跟不法跟罪責無關的可罰性要件。

00:11:45 - 00:11:45
就是這樣判斷的，

00:11:45 - 00:11:46
知道嗎？

00:11:46 - 00:11:46
好，

00:11:47 - 00:11:47
相對的，

00:11:47 - 00:11:48
我們舉一個反例。

00:11:48 - 00:11:49
227。

00:11:51 - 00:11:51
227,

00:11:51 - 00:11:53
我們不管第幾項都一樣,

00:11:53 - 00:11:55
我們就以第一項來說,

00:11:56 - 00:11:58
跟未滿14歲的人性交。

00:11:58 - 00:11:59
你知道嗎？

00:11:59 - 00:12:00
大概20

00:12:00 - 00:12:00
幾幾年前，過去曾經有一派的實務見解說啊

00:12:04 - 00:12:09
227的被害人年齡是客觀處罰條件，過去在就樣說法，為什麼會有這個說法呢

00:12:13 - 00:12:15
因為法官檢察官他們不想被被告騙。

00:12:16 - 00:12:17
簡單講這個說法就這樣來的。

00:12:18 - 00:12:24
因為很多犯227的人，他會說我哪知道那個人沒有滿14，我哪知道那個人沒有滿16。

00:12:24 - 00:12:28
他看起來真的很成熟，他騙我說他是高中生，他是大學生。

00:12:28 - 00:12:30
誰知道啊，我也被騙誒。

00:12:31 - 00:12:34
那有時候法官檢察官就想說，嗯，被告講的是真的嗎？

00:12:34 - 00:12:36
那個少女看起來真的還蠻成熟的。

00:12:36 - 00:12:41
可是法官檢察官又不甘心就像這樣相信被告的話，讓他不起訴或無罪。

00:12:41 - 00:12:42
所以他們怎麼說呢？

00:12:42 - 00:12:46
乾脆就硬拗，說那個被害人的年齡是客觀處罰條件。

00:12:47 - 00:12:50
過去有這樣的說法，說被害人年齡是客觀處罰條件。

00:12:50 - 00:12:53
那我要說啊，這個說法絕對不可採。

00:12:53 - 00:12:53
為什麼？

00:12:54 - 00:12:55
因為我跟各位說

00:12:56 - 00:13:01
如果你講227的被害人年齡是客觀處罰條件的話，來依照我們的公式。

00:13:03 - 00:13:07
把疑似是客觀處罰條件的東西遮掉看法益侵害還存不存在。

00:13:08 - 00:13:12
所以你把227的被害人年齡遮掉之後，這一條剩什麼？

00:13:13 - 00:13:16
剩下與男女行交，與男女猥褻。

00:13:16 - 00:13:17
所以各位啊

00:13:17 - 00:13:20
單純的跟男女行交跟男女猥褻

00:13:20 - 00:13:21
有法益侵害嗎？

00:13:22 - 00:13:23
當然沒有啊。

00:13:24 - 00:13:26
這不是很正常的生物行為嗎？

00:13:26 - 00:13:26
對吧？

00:13:26 - 00:13:27
所以喔

00:13:28 - 00:13:28
227

00:13:28 - 00:13:29
被害人的年齡

00:13:30 - 00:13:32
當然不是客觀處罰條件。

00:13:33 - 00:13:35
除非你說無夫奸是一種法益侵害。

00:13:36 - 00:13:37
每次講到這個地方我都會跟同學分享啊，你們知道嗎？

00:13:38 - 00:13:39
民國初年

00:13:39 - 00:13:42
當時在制定新刑法的時候，當時啊

00:13:43 - 00:13:46
中國的境內有人在討論一個東西，說無夫姦要不要繼續的入罪化。

00:13:49 - 00:13:50
什麼叫無夫姦呢？

00:13:50 - 00:13:59
就是中國歷代的刑律都有處罰女生在沒有丈夫的情況下，跟別的男生合意性交，那個叫無夫姦。

00:13:59 - 00:13:59
所以

00:14:00 - 00:14:01
一切的無夫姦會罰什麼的？

00:14:02 - 00:14:10
比如說少女跟她的青梅竹馬的這個好鄰居啊，兩個人合意性交，婚前性行為這一種，這個叫無夫姦，或者比如說那個女生啊，丈夫過世之後，她跟那個鄰居單身的男生，兩個人打得一炮，那那個叫無夫姦。

00:14:21 - 00:14:24
無夫姦真的，以前中國歷代的權力這個都犯罪。

00:14:24 - 00:14:28
現在聽得覺得很荒謬對不對，這有什麼好罰的，性行為自由嗎？

00:14:28 - 00:14:28
你知道嗎？

00:14:30 - 00:14:38
100多年前，當時很多，也不能說很多啦，當時有一派領教派的人說，不行啊，無夫姦不能就這樣除罪化。

00:14:38 - 00:14:45
他們說如果無夫姦除罪化的話，我們5000年的道德淪喪，道德會淪喪，文化會滅亡什麼的。

00:14:46 - 00:14:51
聽這個話語有沒有覺得很熟悉，多年前那個同性婚姻要通過的時候，保守派不是也講這種東西嗎？

00:14:52 - 00:14:54
他們的語言100多年來沒有變過。

00:14:54 - 00:14:57
所以當時一直有人力主說那個無夫姦不能就這樣除罪化。

00:14:57 - 00:14:58
後來他們沒有贏了。

00:14:58 - 00:15:02
所以在現在的刑法當中，沒有通姦罪，沒有這種東西。

00:15:02 - 00:15:02
所以我要講了。

00:15:03 - 00:15:06
單純的與人性交、與人猥褻。

00:15:06 - 00:15:07
當然沒有法益侵害啊。

00:15:07 - 00:15:10
對啊，除非你是保守派，說無夫姦要合法，侵害，除非是這樣。

00:15:10 - 00:15:11
那不可能嘛。

00:15:11 - 00:15:15
現在無夫姦有在處罰的，應該只有伊斯蘭教的國家吧。

00:15:15 - 00:15:17
這個正常的國家應該是不會罰這種東西喔。

00:15:18 - 00:15:18
所以我說啊。

00:15:19 - 00:15:23
當你把227的被害人年齡遮住之後,

00:15:24 - 00:15:25
剩下的部分還沒有法益侵害。

00:15:26 - 00:15:27
當然沒有啊，對不對？

00:15:27 - 00:15:28
當然沒有。

00:15:28 - 00:15:30
所以27的被害人年齡，

00:15:30 - 00:15:33
當然不可能是客觀處罰條件，知道嗎？

00:15:33 - 00:15:34
就是這樣判斷的喔。

00:15:35 - 00:15:37
好，所以如果這個公式同學瞭解的話，

00:15:37 - 00:15:39
接下來幾個條文，227頁這邊，

00:15:39 - 00:15:41
我們大概來看一下。

00:15:43 - 00:15:44
來。

00:15:44 - 00:15:45
像238我們剛剛講過哈。

00:15:45 - 00:15:49
那第二點283的致人於死或重傷，這個多數說也覺得它是客觀處罰條件。

00:15:49 - 00:15:54
詳細的我們到分則再說，因為283這個條文說來就複雜了。

00:15:57 - 00:15:58
接著下面哈，第三點。

00:16:00 - 00:16:03
酒駕罪的酒精濃度

00:16:03 - 00:16:05
這個東西同學不要誤會

00:16:07 - 00:16:10
一般講說0.185至0.25什麼東西是觀察條件

00:16:11 - 00:16:12
酒測值

00:16:13 - 00:16:14
那個數值本身

00:16:15 - 00:16:17
不是說喝酒的部分是關聯條件

00:16:18 - 00:16:19
不是喔

00:16:19 - 00:16:20
是那個酒測值

00:16:20 - 00:16:21
你知道嗎

00:16:21 - 00:16:24
因為這很多人搞錯，這個我到時候會再跟同學講一遍

00:16:24 - 00:16:25
各位這是什麼意思

00:16:26 - 00:16:29
假設有一天我喝酒開車

00:16:29 - 00:16:29
喔

00:16:30 - 00:16:34
那我被警察抓到，一吹氣啊，酒測值高達0.72

00:16:34 - 00:16:36
我跟警察說你那個酒測器有問題

00:16:36 - 00:16:39
對,我承認我有喝酒,我也覺得我有點暈

00:16:40 - 00:16:45
可是以我自己酒駕的經驗,這個頂多0.358,這不是0.72,你一個酒測器有問題

00:16:46 - 00:16:48
這種情況可不可以說我欠缺故意

00:16:48 - 00:16:50
不可以,酒測值是客觀條件,知道嗎

00:16:51 - 00:16:54
那個東西請為的故意不用認識到,因為技術上不可行啊

00:16:55 - 00:16:58
你要行為人知道自己體內的酒測值才有故意的話

00:16:59 - 00:17:00
那誰會有

00:17:00 - 00:17:01
這條罪的故意啊

00:17:01 - 00:17:04
就除了有醫學背景的人，或者他是酒駕慣犯

00:17:04 - 00:17:05
對不對，正常來說不可能嘛

00:17:05 - 00:17:06
所以一般會認為說

00:17:07 - 00:17:08
這一條的話呢

00:17:09 - 00:17:12
行為人不需要具體認識到自己的酒測值

00:17:12 - 00:17:13
不用

00:17:14 - 00:17:16
只要意識到什麼呢

00:17:17 - 00:17:18
自己有喝酒

00:17:18 - 00:17:22
自己體內的酒測值，自己當時喝酒的身心狀態

00:17:22 - 00:17:24
已經不太適合開車了

00:17:24 - 00:17:25
有這樣的意識就OK

00:17:25 - 00:17:25
知道嗎

00:17:26 - 00:17:27
所以各位，行為人要不要知道自己喝酒

00:17:28 - 00:17:29
要喔

00:17:29 - 00:17:30
他是要

00:17:30 - 00:17:31
知道這件事的喔

00:17:31 - 00:17:35
他只是不用知道說具體的酒測值這個數字是多少，知道吧

00:17:36 - 00:17:37
這個各位不要誤會喔

00:17:37 - 00:17:39
所以以前考試有出過

00:17:39 - 00:17:40
說有個人

00:17:41 - 00:17:42
他被人陷害

00:17:43 - 00:17:47
就是別人在他的飲料裡面摻入了酒精

00:17:47 - 00:17:48
他不知道

00:17:48 - 00:17:49
他開車上路

00:17:49 - 00:17:49
後來被警察抓

00:17:50 - 00:17:51
這個會不會成立185之3

00:17:52 - 00:17:53
不會

00:17:53 - 00:17:53
不可能

00:17:53 - 00:17:54
因為他連自己在喝酒都不知道

00:17:54 - 00:17:55
知道嗎

00:17:55 - 00:17:56
再講一次喔

00:17:56 - 00:17:58
會被認為是關條件的頂多是什麼

00:17:58 - 00:17:59
酒測值，那個是無理

00:18:00 - 00:18:00
子，

00:18:00 - 00:18:01
懂嗎？

00:18:01 - 00:18:02
喝酒本身不是喔。

00:18:03 - 00:18:03
好。

00:18:03 - 00:18:04
接下來,

00:18:04 - 00:18:05
第四點,

00:18:05 - 00:18:08
廢弛職務，釀成災害罪。

00:18:09 - 00:18:11
這個東西，會有一些討論的空間。

00:18:12 - 00:18:12
來，

00:18:12 - 00:18:13
我們來看一下這個條文,

00:18:13 - 00:18:15
這個我們到分則會再講一遍。

00:18:15 - 00:18:16
這個有些東西,

00:18:16 - 00:18:18
因為你會發現我們的課程就是這樣子,

00:18:19 - 00:18:20
很多東西,

00:18:20 - 00:18:20
總則會講，

00:18:20 - 00:18:21
分則也會講，

00:18:22 - 00:18:23
加深同學的印象。

00:18:23 - 00:18:26
因為只講一遍，同學很容易忘記，

00:18:26 - 00:18:28
所以有的時候我在總則講過的東西，

00:18:28 - 00:18:29
分則也會再講一遍,

00:18:29 - 00:18:31
加深同學的印象。

00:18:31 - 00:18:31
來,

00:18:31 - 00:18:36
130這個條文叫做公務員廢弛職務釀成災害罪。

00:18:36 - 00:18:37
我們看喔,

00:18:37 - 00:18:39
這個條文規定的非常非常的簡單。

00:18:40 - 00:18:40
130只說,

00:18:41 - 00:18:44
公務員廢弛職務，釀成災害者。

00:18:45 - 00:18:46
各位啊,

00:18:47 - 00:18:49
我們學構成要件的時候都學過。

00:18:49 - 00:18:54
如果一個犯罪，條文沒有規定他是故意的還是過失的話，

00:18:54 - 00:18:56
那他是故意犯還是過失犯？

00:18:57 - 00:18:58
當然是故意犯，

00:18:58 - 00:18:58
對不對？

00:18:58 - 00:18:59
當然是故意犯。

00:18:59 - 00:19:40
沒錯喔。

00:19:40 - 00:19:44
條文沒有講他是故意還過失的話，他就是故意犯喔。

00:19:44 - 00:19:46
因此130有沒有講他故意還過失？

00:19:46 - 00:19:46
沒有，

00:19:46 - 00:19:47
所以他怎麼犯？

00:19:47 - 00:19:48
他是故意犯。

00:19:48 - 00:19:51
好，那130是故意犯的話，必須公務員對什麼有故意？

00:19:51 - 00:19:53
對廢弛職務有故意，

00:19:53 - 00:19:53
還要對什麼有故意？

00:19:54 - 00:19:56
還要對釀成災害有故意。

00:19:56 - 00:19:58
有沒有感覺講到這邊就覺得不太對勁了？

00:20:00 - 00:20:02
這個東西我現在不太會講啦。

00:20:02 - 00:20:04
因為，我跟各位簡單這樣說，

00:20:05 - 00:20:06
這個東西，

00:20:06 - 00:20:08
以前是柯耀成老師主張啦。

00:20:09 - 00:20:10
柯老師後來退休了,

00:20:10 - 00:20:11
我印象中其他沒有學者,

00:20:12 - 00:20:12
應該沒有學者,

00:20:13 - 00:20:15
應該沒有其他的學者做這樣的主張,

00:20:16 - 00:20:16
應該沒有,

00:20:17 - 00:20:20
所以這個說法在現在來說比較沒那麼重要。

00:20:20 - 00:20:22
有時候準備國考就很現實啦，

00:20:22 - 00:20:23
真的就這樣，

00:20:23 - 00:20:24
我大概講一下這個問題怎麼來的。

00:20:25 - 00:20:29
那個，同學應該有一個常識，訴訟法上面的常識。

00:20:30 - 00:20:32
我們一般人上法庭作證要不要具結？

00:20:33 - 00:20:33
要，對不對？

00:20:34 - 00:20:37
因為我們行訴是反面表列兩種情況不用具結嘛。

00:20:37 - 00:20:38
第一個是未滿16歲，

00:20:39 - 00:20:41
第二個是精神障礙不瞭解具結的意義。

00:20:42 - 00:20:43
就這兩種人嘛。

00:20:43 - 00:20:44
你們是這兩種人嗎？

00:20:45 - 00:20:46
你們一定滿16歲啦。

00:20:47 - 00:20:48
你們會是後面那種人嗎？

00:20:49 - 00:20:49
不會吧？

00:20:50 - 00:20:52
會的話，我會很訝異。

00:20:52 - 00:20:53
不會嘛，對不對？

00:20:53 - 00:20:54
一定不會。

00:20:54 - 00:20:56
所以各位上法庭作證都是要具結的。

00:20:57 - 00:20:58
來，各位，那我舉個例子。

00:20:59 - 00:21:00
那個,

00:21:01 - 00:21:04
如果說，我叫我堂妹的小孩，

00:21:05 - 00:21:06
我堂妹的小孩在唸國小。

00:21:07 - 00:21:09
假設我叫我堂妹的小孩，是我的什麼？

00:21:09 - 00:21:12
不重要啦，我也不知道那個親戚怎麼稱謂、怎麼稱呼。

00:21:12 - 00:21:16
以前，對啊，以前堂妹的小孩看到我說要叫我什麼，

00:21:16 - 00:21:18
我說叫哥哥就好了，聽起來比較年輕。

00:21:19 - 00:21:21
結果竟然我叔叔說不行欸。

00:21:21 - 00:21:23
我說哪有不行，沒差，聽起來年輕就好了。

00:21:24 - 00:21:28
好啦，反正，如果我叫我堂妹的小孩上法庭去做偽證，

00:21:29 - 00:21:30
然後檢察官一時疏忽,

00:21:31 - 00:21:33
他沒發現他是小朋友啊,還叫他具結喔。

00:21:33 - 00:21:35
然後我堂妹的小孩做成的虛偽陳述,

00:21:36 - 00:21:38
這樣我可不可以成立偽證罪的教唆犯?

00:21:39 - 00:21:40
對啊,就這個案例,

00:21:40 - 00:21:42
我就不畫黑板了，這個我帶過就好。

00:21:43 - 00:21:44
一般認為不行，為什麼？

00:21:44 - 00:21:48
因為我堂妹的小孩他未滿16嘛，他怎麼具結？

00:21:49 - 00:21:51
他就算有具結，那個具結也不合法啊。

00:21:52 - 00:21:53
偽證罪不是要具結嗎，對不對？

00:21:54 - 00:21:55
所以我可不可以成立教唆犯？不可以。

00:21:56 - 00:21:59
但你知道嗎？曾經有一派的學者把偽證罪的具結拉到

00:22:00 - 00:22:00
放到三階之外。

00:22:00 - 00:22:00
放到三階外變成客觀處罰條件。

00:22:00 - 00:22:00
各位啊，168的具結，如果你把它拉到三階之外變客觀處罰條件的話。

00:22:00 - 00:22:01
那我堂妹的小孩有沒有偽證罪的觸法？

00:22:01 - 00:22:01
有喔。

00:22:01 - 00:22:01
那我可不可以成立教唆犯的？

00:22:01 - 00:22:01
可以喔。

00:22:01 - 00:22:01
對，這科老師20年前的想法，曾經有這個說法。

00:22:01 - 00:22:01
以前好像考試有考過吧,但後來這個說法,支持者不多了。

00:22:01 - 00:22:02
柯老師後來也退休了,所以這個說法我到這邊點到為止就好,知道嗎?

00:22:02 - 00:22:02
如果同學你真的有興趣,柯老師20年前的一篇文章,叫做聰明

00:22:03 - 00:22:03
反被聰明誤,我記得是這個名字。

00:22:03 - 00:22:03
有興趣去看,沒興趣沒關係哦。

00:22:03 - 00:22:03
好。

00:22:03 - 00:22:03
我注意是不是有寫？

00:22:03 - 00:22:03
好像是另外一篇，不是這一篇，注意有寫。

00:22:04 - 00:22:04
注意的話，我引的可能是另外一篇了，我剛說。

00:22:04 - 00:22:04
柯老師那篇叫聰明反被聰明誤，沒興趣沒關係。

00:22:04 - 00:22:04
有興趣去看。

00:22:04 - 00:22:05
好，接著肇事逃逸罪。

00:22:05 - 00:22:05
那個肇事逃逸罪啊，他的致人死亡、傷害重傷，是不是客觀處罰條件？

00:22:06 - 00:22:06
這個東西。

00:22:06 - 00:22:06
2021年修法前，有爭議。

00:22:06 - 00:22:06
但現在已經沒有爭執的空間了。

00:22:06 - 00:22:06
好。

00:22:06 - 00:22:07
我講一下喔。

00:22:07 - 00:22:07
肇事逃逸罪的成立，光有車損不夠嗎？

00:22:07 - 00:22:07
你們看條文就學到，肇事逃逸的成立必須怎麼樣？

00:22:07 - 00:22:07
被害人有死亡、傷害或重傷，對不對？

00:22:07 - 00:22:07
好。

00:22:08 - 00:22:08
那假設，行為人出了一場車禍。

00:22:08 - 00:22:08
他知道自己出了車禍。

00:22:08 - 00:22:08
但是他不知道這個車禍有人死傷，他就跑掉了。

00:22:09 - 00:22:09
這樣的話，他會成立肇事逃逸罪嗎？

00:22:09 - 00:22:09
好，舉個例子嘛。

00:22:09 - 00:22:09
我晚上開車回家，半路我打瞌睡。

00:22:09 - 00:22:09
車子衝到人行道，當場撞倒了一排機車。

00:22:10 - 00:22:10
我心想沒事嘛，車損而已，我就心虛跑掉了。

00:22:10 - 00:22:10
結果後來警察來找我才知道，原來機車被我撞倒的時候啊。

00:22:10 - 00:22:11
倒他的機車壓到了一個在路邊睡覺的遊民，那個遊民有受傷。

00:22:11 - 00:22:11
但我根本不知道遊民的存在，我以為只有車損，我就跑掉了。

00:22:11 - 00:22:11
你覺得我這樣的情況會不會成立肇事逃逸罪？

00:24:02 - 00:24:05
我客觀上確實發生了交通事故，確實有人受傷，對不對？

00:24:06 - 00:24:09
我也知道我發生交通事故，但我不知道這個時候會有人受傷。

00:24:10 - 00:24:11
現在我有故意嗎？

00:24:11 - 00:24:13
交通隊當然說沒有，對吧？

00:24:13 - 00:24:15
因為我不知道有人受傷嘛，所以我不承認有罪。

00:24:15 - 00:24:21
但你知道嗎，以前有一個說法，說致人死傷是客觀構成要件，我照樣可以成立這條罪。

00:24:21 - 00:24:24
過去有這個說法，以前林玉瓊老師一直主張這一說。

00:24:24 - 00:24:26
過去有這個說法，但我跟你們說，這個說法在2021年修法之後，已不可採了，為什麼呢？

00:24:30 - 00:24:33
因為我再講一次，什麼叫做客觀處罰條件？

00:24:33 - 00:24:36
它跟不法無關，它跟罪責也無關。

00:24:36 - 00:24:38
這叫客觀處罰條件，對吧？

00:24:38 - 00:24:39
無關不法也無關罪責。

00:24:39 - 00:24:42
但是請各位來看條文185之4。

00:24:43 - 00:24:45
我們來看現在的185之4長什麼樣子。

00:24:45 - 00:24:47
現在的185之4。

00:24:47 - 00:24:50
它的第一項分成前後兩段。

00:24:51 - 00:24:53
前段是致人傷害而逃逸。

00:24:54 - 00:24:55
六個月以上五年以下。

00:24:56 - 00:24:58
後段是致人於死或重傷而逃逸。

00:24:59 - 00:25:00
一年以上起。

00:25:00 - 00:25:01
刑。

00:25:01 - 00:25:02
有沒有看到兩段的刑度？

00:25:02 - 00:25:04
那兩段的刑度用什麼分，我再講一次，用什麼分？

00:25:04 - 00:25:07
用被害人在車禍當下的死傷狀況去分的。

00:25:08 - 00:25:09
所以同學啊。

00:25:09 - 00:25:13
肇事逃逸罪當中，被害人在車禍當下的死傷狀況。

00:25:13 - 00:25:15
決定了這一條罪刑度的區間呢。

00:25:16 - 00:25:17
你能說他跟不法無關嗎？

00:25:18 - 00:25:19
沒有吧，超相關吧。

00:25:19 - 00:25:20
懂我的意思吧？

00:25:20 - 00:25:22
所以在現行的立法之下，肇事逃逸罪的法定刑範圍，正是由被害人的死傷狀況來決定的。

00:25:28 - 00:25:29
所以那個東西怎麼可能是客觀條件？

00:25:30 - 00:25:31
條件。

00:25:31 - 00:25:31
瞭解吧，當然不可能喔。

00:25:32 - 00:25:36
所以這個說法過去有爭議，但2021年修法之後，它不可採了。

00:25:37 - 00:25:37
好。

00:25:37 - 00:25:39
然後啊,最後一點,227號,利用年幼人心委棄罪,這一條罪的被害人年齡是法定條件嗎?

00:25:44 - 00:25:45
當然不可能,好嗎?

00:25:45 - 00:25:45
當然不可能啊,所以現在當然也不能採這個說法了。

00:25:49 - 00:25:50
好。

00:25:50 - 00:25:50
即什麼翻過來第二節。

00:25:51 - 00:25:55
個人阻卻違法是由跟個人的起處性法是由。

00:25:55 - 00:25:56
第一點這邊講,個人的阻卻違法事由,這裡說,個人

00:26:00 - 00:26:00
阻卻違法事由是指呢

00:26:00 - 00:26:01
行為時就足以排除可罰性的個人情狀

00:26:05 - 00:26:08
這個叫做個人的切面,這個叫做阻卻違法事由

00:26:09 - 00:26:11
像比如說288第三項說

00:26:12 - 00:26:17
因疾病或防止其他生命上危險的必要而犯前兩項之罪的話，免除其刑

00:26:18 - 00:26:20
這是一個因免除其刑的規定

00:26:20 - 00:26:20
墮胎罪這邊

00:26:21 - 00:26:24
那我跟各位說，這個規定現在不會有適用的空間

00:26:24 - 00:26:24
為什麼

00:26:25 - 00:26:29
因為孕婦為了避免自己的生命危險而人工流產

00:26:29 - 00:26:31
那可以優生保健法就阻卻違法了

00:26:31 - 00:26:33
違法性就過不了了

00:26:33 - 00:26:34
不會跑到這邊

00:26:34 - 00:26:34
知道嗎

00:26:34 - 00:26:35
所以這一條規定

00:26:36 - 00:26:37
現在用不到

00:26:38 - 00:26:40
那我跟各位分享一下我的看法

00:26:40 - 00:26:41
這個下面註記是有寫

00:26:41 - 00:26:46
我個人啊，我反而不覺得288第三項是什麼個人的阻卻違法事由，我不覺得是

00:26:47 - 00:26:51
我反而覺得這個條文很像是一個緊急避難的除外規定

00:26:51 - 00:26:52
為什麼呢

00:26:52 - 00:26:52
因為你們想喔

00:26:53 - 00:26:56
假設沒有優生保健法，我們預設這個前提

00:26:56 - 00:26:58
假設沒有優生保健法

00:26:59 - 00:27:01
那也沒有288條第三項

00:27:02 - 00:27:05
那麼孕婦為了避免自己的生命危險而墮胎

00:27:05 - 00:27:06
他會怎麼處理

00:27:07 - 00:27:08
他不就緊急避難阻卻違法了嗎

00:27:09 - 00:27:09
對吧

00:27:09 - 00:27:11
所以立法者為什麼特別是這個規定

00:27:11 - 00:27:14
立法者可能想宣示他們覺得胎兒也很重要

00:27:14 - 00:27:15
是不讓孕婦誤殺

00:27:16 - 00:27:17
我個人是覺得是這樣的理由啦

00:27:17 - 00:27:19
我不覺得那什麼阻卻違法事由呀

00:27:19 - 00:27:21
不過這個條文因為現在沒有適用的空間

00:27:21 - 00:27:22
所以探討的實益恐怕不大

00:27:23 - 00:27:25
而另外一個規定275第四項

00:27:25 - 00:27:29
謀為同死而犯前三項之罪，得免除其刑

00:27:29 - 00:27:33
這個東西是一個個人阻卻違法事由，應該比較不會有疑問

00:27:33 - 00:27:35
這跟不法罪責沒有關係啦

00:27:35 - 00:27:37
他純粹是形式政策上的考量啦

00:27:37 - 00:27:38
這個在指什麼呢

00:27:38 - 00:27:45
兩個人相約自殺，後來一個人活下來，一個人死了，那個活下來的人所犯的加工自殺罪

00:27:45 - 00:27:47
得免除其刑

00:27:49 - 00:27:50
這個規定不難理解

00:27:50 - 00:27:51
我都會跟同學這樣說

00:27:52 - 00:27:53
你們想一件事喔

00:27:53 - 00:27:55
為什麼自殺不是犯罪

00:27:55 - 00:27:59
好,當然自殺不是犯罪,是為什麼,我們可以從兩個方向去講

00:27:59 - 00:27:59
第一個

00:28:00 - 00:28:01
是本質論、法益論

00:28:01 - 00:28:04
因為法益論的觀點,我們可以說,我們是自己生命的主人嘛

00:28:05 - 00:28:07
處分自己的生命又沒有傷害到別人,這當然OK啊

00:28:07 - 00:28:07
對不對？

00:28:07 - 00:28:08
這是一個說法。

00:28:08 - 00:28:11
另外，我們可以從技術面來講，為什麼自殺不是犯罪？

00:28:12 - 00:28:18
我們就不要套，我們就先跳脫這個本質的問題，因為本質的問題那個講下去會變哲學的問題。

00:28:19 - 00:28:22
我們就純從技術的考量來說，為什麼自殺不是犯罪？

00:28:22 - 00:28:26
很簡單，因為第一個，自殺既遂你怎麼罰？

00:28:27 - 00:28:29
自殺既遂就被告死亡啊，就不起訴啦，怎麼罰，對不對？

00:28:30 - 00:28:31
自殺未遂可不可以罰？

00:28:32 - 00:28:33
技術上罰得到。

00:28:33 - 00:28:36
但是罰自殺未遂，不利於生命的保護。

00:28:37 - 00:28:40
真的啦，你們想，如果自殺未遂是犯罪，

00:28:40 - 00:28:46
那自殺未遂被救回來的人，張開眼第一個看到的可能不是他親愛的家人、朋友，

00:28:47 - 00:28:48
而是兩個警察。

00:28:49 - 00:28:52
穿著防彈背心、荷槍實彈的警察就跟那個自殺被救回來的人說呢，

00:28:52 - 00:28:55
這位先生小姐啊，你涉及自殺未遂罪。

00:28:55 - 00:28:56
這是犯罪喔。

00:28:56 - 00:28:58
清醒喔，清醒，那我對你做筆錄喔。

00:28:58 - 00:28:59
你有權保持緘默。

00:29:00 - 00:29:01
你可以選任辯護人。

00:29:02 - 00:29:04
你可以請求法院調查有利於你的證據。

00:29:04 - 00:29:04
知道嗎？

00:29:05 - 00:29:06
知道，知道我對你做筆錄了。

00:29:06 - 00:29:08
如果自殺未遂的人醒來看這個畫面，

00:29:09 - 00:29:10
他會有什麼想法？

00:29:10 - 00:29:11
算了，去死好了。

00:29:11 - 00:29:12
有可能，對吧？

00:29:13 - 00:29:19
所以我們講，自殺未遂要罰技術上不是做不到，但是這樣罰下去，反而不利於生命的保護啦。

00:29:19 - 00:29:22
所以自殺未遂，他當然也不是犯罪。

00:29:22 - 00:29:26
好啦，那你想像，兩個人約好一起自殺，男女相約燒炭殉情，

00:29:27 - 00:29:29
後來女生死了，男生還活下來了。

00:29:29 - 00:29:31
那男生不也是一個想死的人嗎?

00:29:32 - 00:29:35
你給他論罪科刑,是不是反而不利於他的生命保護,對不對?

00:29:36 - 00:29:38
所以275第四項是這樣來的,知道嗎?

00:29:38 - 00:29:43
所以這個東西,它也是一個個人的阻卻刑罰事由。

00:29:43 - 00:29:45
那第二點這邊叫解除刑罰事由。

00:29:46 - 00:29:50
這邊指呢,在違反可罰性的犯罪之後才發生的情狀。

00:29:51 - 00:29:52
所以阻卻跟解除差在哪裡?

00:29:53 - 00:29:54
阻卻是一開始就存在,

00:29:55 - 00:29:56
解除是事後才發生,

00:29:57 - 00:29:58
比如說中止未遂,

00:29:59 - 00:30:00
中止未遂我們

00:30:00 - 00:30:01
等下就會講到的。

00:30:02 - 00:30:03
我跟你們說啊。

00:30:03 - 00:30:05
中止未遂這個東西啊。

00:30:05 - 00:30:06
其實在國內。

00:30:07 - 00:30:09
叫解除刑法是有這個翻譯不好。

00:30:09 - 00:30:11
其實應該叫做減免刑罰事由才對。

00:30:12 - 00:30:14
我個人習慣是都寫減免刑罰事由。

00:30:15 - 00:30:17
因為我跟你們說啦，這個牽涉到臺灣跟德國法制的不同。

00:30:18 - 00:30:20
德國的中止未遂是根本就無罪。

00:30:21 - 00:30:22
很特別對不對。

00:30:22 - 00:30:24
沒錯，德國的中止未遂，他根本就無罪。

00:30:24 - 00:30:27
所以在德國講解除刑法很合理。

00:30:28 - 00:30:29
因為刑法真的被解除了。

00:30:30 - 00:30:30
可是我……

00:30:30 - 00:30:31
我不是啊。

00:30:31 - 00:30:33
我國的中止未遂還是有罪耶。

00:30:33 - 00:30:34
所以在我國的話。

00:30:35 - 00:30:36
蔡聖偉老師講的沒有錯。

00:30:37 - 00:30:38
你講解除不太對。

00:30:38 - 00:30:40
應該講什麼呢，前面？

00:30:40 - 00:30:42
講前面應該比較合理喔。

00:30:42 - 00:30:43
好，這個以後我們會說。

00:30:44 - 00:30:46
啊，小單元我們就看到這了喔。

00:30:48 - 00:30:51
接下來我們來看到未遂犯這邊。

00:30:54 - 00:30:55
好，我們來看未遂喔。

00:30:55 - 00:30:58
我們在正式講未遂犯之前。

00:30:58 - 00:31:00
234頁。

00:31:00 - 00:31:03
我們這裡先來畫個圖，犯罪的行為階段。

00:31:04 - 00:31:06
這個東西同學應該不陌生。

00:31:06 - 00:31:07
我們講未遂犯開始。

00:31:07 - 00:31:09
每個老師應該都會畫這個圖。

00:32:37 - 00:32:38
好，我們這邊來看一下吼，

00:32:39 - 00:32:43
黑板上這個圖，講的是犯罪的行為階段。

00:32:43 - 00:32:48
這個圖啊，我想同學不陌生，我剛說的，應該每一本書都會去對他做介紹。

00:32:49 - 00:32:50
這個圖在講什麼呢？

00:32:50 - 00:32:57
在故意犯罪當中，行為人從一開始想犯罪，到他最後順利地實現犯罪，

00:32:58 - 00:33:00
中間可能會經歷

00:34:00 - 00:34:03
經過的階段，這個叫做故意犯罪的行為階段。

00:34:03 - 00:34:06
那這個階段啊，我們講可長可短。

00:34:07 - 00:34:11
衝動型的犯罪，從決議到終了，到既遂。

00:34:11 - 00:34:13
可能短短的幾秒鐘。

00:34:14 - 00:34:21
有計畫的犯罪，這整個時間軸可能拉得很長，好幾個月，甚至好幾年都是有可能的。

00:34:21 - 00:34:23
比如說計畫刺殺總統之類的。

00:34:23 - 00:34:25
可能會計畫很久都是有可能的。

00:34:26 - 00:34:31
我說,不管是怎麼樣的犯罪,不管是怎麼樣的犯罪行為人。

00:34:31 - 00:34:34
只要是故意犯罪,一定都會經歷這些階段。

00:34:34 - 00:34:35
我們大致來看喔。

00:34:37 - 00:34:42
假設我想殺人,第一個,我腦袋中浮現想殺人的想法,這個叫決意。

00:34:42 - 00:34:45
接著,我跟我的朋友兩個人一起討論,這個叫陰謀。

00:34:46 - 00:34:49
討論完之後，我們去買刀、去買衣服，這個叫預備。

00:34:49 - 00:34:52
被害人出現，我們揮刀砍向被害人，這個叫著手。

00:34:52 - 00:34:55
砍完之後，被害人倒地，我們心滿意足的離開，這個叫完成。

00:34:56 - 00:34:58
被害人送醫不治，這個叫既遂。

00:34:59 - 00:35:00
那殺人罪是

00:35:00 - 00:35:02
狀態犯，所以不會有額外的

00:35:02 - 00:35:04
終了的問題，這個叫故意犯的行為階段。

00:35:04 - 00:35:06
來，這些行為階段

00:35:06 - 00:35:07
我們從左往右看，最左邊叫決意。

00:35:09 - 00:35:14
決意的意思就是行為人的腦中浮現想犯罪的想法，這個叫決意。

00:35:15 - 00:35:15
我們都知道啊。

00:35:17 - 00:35:17
刑法

00:35:17 - 00:35:22
要罰一個人，一定是因為這個人他做了某些的行為。

00:35:23 - 00:35:26
所以決意本身不可能是犯罪。

00:35:26 - 00:35:29
記得喔，刑法不罰思想，知道嗎？

00:35:29 - 00:35:30
刑法是不罰思想的。

00:35:31 - 00:35:34
就算你腦中有再怎麼邪惡的想法。

00:35:34 - 00:35:35
比如說假設

00:35:35 - 00:35:41
那個路人甲啊，他每天都在幻想跟幼稚園的女生發生性關係。

00:35:41 - 00:35:44
假設路人甲每天晚上都在做這樣的幻想。

00:35:44 - 00:35:45
但只要他不要真的去做。

00:35:45 - 00:35:47
那我們也拿他沒辦法。

00:35:47 - 00:35:48
就不要做就好了嘛。

00:35:48 - 00:35:50
思想本身是無罪的，知道嗎？

00:35:50 - 00:35:51
思想是無罪的。

00:35:51 - 00:35:53
不管在什麼樣的時候都一樣，思想是無罪的。

00:35:53 - 00:35:55
所以決議的部分，當然不可能會成立犯罪。

00:35:55 - 00:35:59
不過跟同學說，

00:36:00 - 00:36:00
刑法當中有兩個條文，

00:36:02 - 00:36:05
如果你不好好解釋，它會變成思想犯。

00:36:06 - 00:36:11
第一個最典型的我先帶各位看348之一，那個叫準強盜勒贖罪

00:36:12 - 00:36:13
這一條很冷門

00:36:14 - 00:36:16
但這一條前幾年

00:36:17 - 00:36:19
三年前先是考在北大法研所

00:36:20 - 00:36:22
然後去年考在律師三等

00:36:22 - 00:36:24
這冷門的條文竟然考得出來

00:36:24 - 00:36:26
我們來看一下348之一，準擄人勒贖罪

00:36:30 - 00:36:32
來，準擄人勒贖罪在罰什麼呢

00:36:32 - 00:36:38
他說擄人後意圖勒贖者，以意圖勒贖而擄人論，這個叫準擄人勒贖罪

00:36:40 - 00:36:42
他要補的是一個洞啦

00:36:42 - 00:36:44
因為你看，你往回看347

00:36:45 - 00:36:47
347是一般的擄人勒贖

00:36:47 - 00:36:50
347說什麼，說意圖勒贖而擄人

00:36:50 - 00:36:56
所以要論347的話，必須行為人在擄人的時候，就有勒贖的意圖喔

00:36:57 - 00:37:00
那如果他事後才產生意圖怎麼辦

00:37:00 - 00:37:01
對啊

00:37:01 - 00:37:01
比如說你想

00:37:02 - 00:37:04
如果那個

00:37:04 - 00:37:04
假設

00:37:05 - 00:37:08
明天我跟我的朋友一起看罷免的開票

00:37:09 - 00:37:13
明天好像沒辦法，我們下課五點那個結局可能都已經快出來了

00:37:14 - 00:37:16
少了這個樂趣好可惜，對啊

00:37:16 - 00:37:18
不然我每次

00:37:18 - 00:37:18
有

00:37:18 - 00:37:22
有選舉罷免的時候，我都喜歡去朋友家

00:37:22 - 00:37:22
那個

00:37:22 - 00:37:24
那個好兄弟，尼哥的主人，我很喜歡去他家

00:37:24 - 00:37:26
跟他一起去看開票

00:37:26 - 00:37:27
今年沒辦法

00:37:27 - 00:37:27
好

00:37:28 - 00:37:34
我覺得明天四點之後，我不知道你們會不會這樣，可能會不專心上課，一直想著結果怎麼樣

00:37:34 - 00:37:34
這

00:37:35 - 00:37:37
不能停課啦，不能為這種鳥事停課

00:37:37 - 00:37:37
好

00:37:37 - 00:37:38
我要講

00:37:38 - 00:37:39
那個

00:37:40 - 00:37:40
假設

00:37:40 - 00:37:42
我跟朋友一起看開票

00:37:43 - 00:37:45
看著看著，彼此政治立場不同，吵了起來

00:37:46 - 00:37:49
我一氣之下，把我的朋友鎖在我家的後陽臺

00:37:50 - 00:37:55
結果，我把他鎖在後陽臺呢，原本是單純的想報復他

00:37:55 - 00:37:59
但我後來想一想，他老爸是建商呢

00:37:59 - 00:38:00
那我跟他老爸

00:38:00 - 00:38:01
在後陽臺勒索一下好了。

00:38:01 - 00:38:04
這時候啊，我叫做準擄人的勒索罪，348之一，知道嗎？

00:38:05 - 00:38:10
我如果一開始就是為了跟他老爸勒索，而把他鎖在後陽臺，這個就347嘛。

00:38:11 - 00:38:18
如果我一開始只是想報復他，而把他鎖到後陽臺，後來才想到，他老爸有錢，跟他老爸勒索一下好了。

00:38:18 - 00:38:20
這時候呢，叫做348之一。

00:38:20 - 00:38:23
來各位你看哦，348之一的行為是什麼？

00:38:24 - 00:38:28
他說擄人後意圖勒索者，以意圖勒索而擄人論。

00:38:28 - 00:38:30
所以這條罪的行為是什麼？

00:38:31 - 00:38:32
你跟我說是擄人嗎？

00:38:32 - 00:38:34
不是喔，擄人只是這條罪的前提喔。

00:38:35 - 00:38:36
那你說是勒索嗎？

00:38:36 - 00:38:38
沒有，勒索是主觀要件，是意圖。

00:38:39 - 00:38:41
所以這條罪，沒有行為。

00:38:41 - 00:38:43
對，沒錯，這條罪沒有行為。

00:38:43 - 00:38:50
這條罪你光看條文字面的話，那行為人只要產生勒索的壞念頭的瞬間，本罪即遂。

00:38:51 - 00:38:54
莫名其妙，對吧，說好的刑法不罰思想呢。

00:38:54 - 00:38:56
所以這一條罪我們以後到分則就會說。

00:38:57 - 00:38:59
他要加上行為啦，要有勒索的行為才會起訴啦，知道嗎？

00:39:00 - 00:39:01
像這一條罪就是。

00:39:01 - 00:39:03
還有像侵佔罪也是，335的侵佔。

00:39:04 - 00:39:07
其實335的侵佔條文本身沒有問題。

00:39:08 - 00:39:10
侵佔他人實務嘛，條文本身沒有問題。

00:39:10 - 00:39:12
有問題的是傳統的學說跟實務。

00:39:13 - 00:39:14
你以前學過刑法的話應該聽過。

00:39:15 - 00:39:17
傳統上說什麼叫侵佔？

00:39:18 - 00:39:19
意圖持有為所有，說這個叫侵佔。

00:39:20 - 00:39:21
好，那什麼叫意圖持有為所有？

00:39:22 - 00:39:25
傳統的說法會說，那就是你主觀上想法改變的瞬間。

00:39:27 - 00:39:29
也就是我幫我朋友保管筆電的時候，

00:39:30 - 00:39:36
如果我突然產生一個壞壞的想法，我最近有點缺錢，他那臺筆電很輕，我要不要把它拿去賣掉啊？

00:39:37 - 00:39:39
我那個想法產生的瞬間就叫「以持有為所有」。

00:39:40 - 00:39:42
那是過去的實務其實是廚餘，知道嗎？

00:39:42 - 00:39:48
所以以後我們到刑分就會說，像348之1，像335這種條文，我們要好好解釋了。

00:39:48 - 00:39:51
不然這兩條呢，真的會淪為在處罰思想，知道吧？

00:39:51 - 00:39:54
好，所以不管怎麼樣，思想本身是不罪的。

00:39:55 - 00:39:56
好，再來第二個，陰謀。

00:39:58 - 00:39:59
各位，陰謀這個東西喔，

00:40:00 - 00:40:01
我們要做合理的解釋,

00:40:02 - 00:40:03
你不能看字面的意思,

00:40:04 - 00:40:07
因為如果你講字面的話，陰謀不也是思想嗎？當然不是。

00:40:08 - 00:40:12
刑法上的陰謀指的是什麼呢？兩個人以上共同謀議。

00:40:13 - 00:40:15
所以一個人是陰謀不起來的喔，知道嗎？

00:40:15 - 00:40:19
陰謀一定是指什麼呢?兩個以上的人共同謀議,

00:40:20 - 00:40:21
這個才叫陰謀,知道吧?

00:40:21 - 00:40:23
兩個人以上共同謀議,所以一個人不叫陰謀。

00:40:24 - 00:40:26
兩個人以上的人共同謀議才叫做陰謀。

00:40:26 - 00:40:32
有罰陰謀的,只有國家存在的那種犯罪,內亂外患那一種,那個才有罰。

00:40:32 - 00:40:33
再來叫預備，

00:40:34 - 00:40:35
再來叫預備。

00:40:35 - 00:40:38
預備指什麼呢？犯罪的準備階段，

00:40:39 - 00:40:39
這個叫預備。

00:40:40 - 00:40:44
那我們講，現行法在罰預備啊，有兩種不同的處罰方式。

00:40:45 - 00:40:47
一種方式叫做形式預備犯。

00:40:48 - 00:40:49
什麼叫形式預備？

00:40:50 - 00:40:53
就是條文裡面它就直接寫了預備這兩個字的,

00:40:54 - 00:40:55
那個叫形式預備犯。

00:40:56 - 00:40:58
那個271條第三項，預備殺人罪。

00:40:58 - 00:41:02
第328條第三項、第328條第五項，預備強盜罪。

00:41:02 - 00:41:08
那個條文有寫「預備」兩個字的，那一種一看到就在罰預備的，那個叫做形式預備犯。

00:41:09 - 00:41:11
相對的，什麼叫做實質預備犯？

00:41:12 - 00:41:17
實質的意思是，這個條文本身沒有出現「預備」兩個字，

00:41:18 - 00:41:19
可是我們探索它的本質會發現，

00:41:20 - 00:41:22
其實這一條罪就是別條的預備行為,

00:41:22 - 00:41:23
這個叫做實質預備犯。

00:41:24 - 00:41:27
比如說你看喔，刑法199的規定，這是一個典型的例子，

00:41:28 - 00:41:28
刑法199。

00:41:30 - 00:41:33
你看喔，刑法199這個條文他說，

00:41:34 - 00:41:38
如果你意圖供偽造、變造貨幣等等之用，那又怎麼樣呢？

00:41:38 - 00:41:43
收集交付各項器械原料，有沒有？

00:41:44 - 00:41:45
所以199在罰什麼？

00:41:46 - 00:41:54
我想偽造貨幣，而去收集紙張、油墨、機臺、排版軟體，

00:41:54 - 00:41:56
這個時候我犯的叫做199的犯罪。

00:41:57 - 00:42:00
所以各位啊，199這個條文，它條文本身

00:42:00 - 00:42:03
它雖然沒有出現預備這兩個字，可是其實199是什麼的預備？

00:42:05 - 00:42:06
195的預備啊，知道嗎？

00:42:07 - 00:42:12
所以這一種立法模式，條文本身沒有出現預備兩個字，可是其實它的本質就是另外一條罪的預備行為，這一種立法模式我們叫做實質預備犯。

00:42:20 - 00:42:24
還有像什麼呢？187，加重持有危險物品罪，這個也是哈。

00:42:25 - 00:42:29
187條是一個在考情中還容易出現的條文。

00:42:29 - 00:42:35
當題目裡面說到行為人有拿槍，我們通常要考慮的就是187這個犯罪。

00:42:36 - 00:42:41
187說啊，意圖供犯罪之用，而持有軍用的槍砲子彈，這是187。

00:42:44 - 00:42:48
所以187罰什麼呢？你意圖供犯罪使用，而持有槍枝，那個就187。

00:42:48 - 00:42:54
187本身雖然沒有寫預備兩個字，但他本質上就是什麼呢？犯罪的預備啊，對不對？

00:42:54 - 00:42:57
所以187呢,它也是一種實質預備犯。

00:42:57 - 00:43:02
所以各位啊,以後你寫到刑總的考題,有那種打擊錯誤拿槍的。

00:43:02 - 00:43:11
不要忘記187哦,除非題目跟你說那個人是什麼原住民合法持有獵槍,或者題目跟你說那個槍不用檢討,不然不要忘記187,知道嗎?187哦。

00:43:14 - 00:43:15
我這邊先跟各位說。

00:43:15 - 00:43:16
187不是講軍用嗎?

00:43:17 - 00:43:22
那個軍用的意思是，不是說現在的軍隊要真的在使用那個型號，不用。

00:43:22 - 00:43:27
那個軍用的意思是說，性能上可以供軍事使用，那就算。

00:43:27 - 00:43:29
所以我們一般的手槍就是對。

00:43:30 - 00:43:31
手槍當然是。

00:43:31 - 00:43:33
因為軍隊當中當然會有手槍。

00:43:34 - 00:43:37
連長手上會有一把啊,如果有兵要做亂,他可以打下去啊。

00:43:37 - 00:43:39
所以手槍當然是軍用,知道嗎?當然是哦。

00:43:40 - 00:43:42
好,接下來,那個什麼?

00:43:44 - 00:43:45
我們來講一下形式預備犯。

00:43:46 - 00:43:49
有罰形式預備犯的犯罪不多,就那麼幾條。

00:43:50 - 00:43:53
這邊我畫一個圖來給同學參考哈。

00:44:11 - 00:44:11
這個圖啊

00:44:11 - 00:44:12
請各位記得

00:44:16 - 00:44:16
這個圖不是我原創的

00:44:17 - 00:44:18
這個是蔡勝偉老師原創的

00:44:20 - 00:44:21
蔡老師畫的比我好100倍

00:44:22 - 00:44:24
你們知道蔡勝偉老師很會素描嗎

00:44:24 - 00:44:25
蔡老師素描超厲害

00:44:26 - 00:44:28
這個以前看過他畫畫，真的沒得說

00:44:29 - 00:44:33
蔡老師當初怎麼沒有想過去唸藝術，對不對，選擇念法律，蔡老師很會畫畫

00:44:34 - 00:44:38
當時蔡老師在畫這個在屋子裡面的那個強人的時候啊

00:44:39 - 00:44:41
他畫的就是一副肌肉男的樣子

00:44:41 - 00:44:45
然後當下我們在臺下的同學說老師在畫自己的自畫像吧

00:44:45 - 00:44:47
因為蔡老師就是肌肉男啊

00:44:47 - 00:44:48
他練得非常壯

00:44:49 - 00:44:50
來，這圖是這樣喔

00:44:52 - 00:44:54
這個口訣叫做內外放火，殺強人

00:44:56 - 00:44:58
有個強人在屋子裡面舉重

00:44:59 - 00:44:59
看起來很強

00:46:00 - 00:46:01
對吧？

00:46:01 - 00:46:01
在屋子裡面舉重。

00:46:01 - 00:46:03
行為人為了要殺掉這個強人，

00:46:03 - 00:46:05
所以行為人他在屋內屋外放火，

00:46:06 - 00:46:09
屋內屋外放火，就是要為了要殺這個強人。

00:46:09 - 00:46:12
好，他在屋內屋外放火，殺完這個強人之後，

00:46:13 - 00:46:16
他很緊張地騎乘了一臺民航機跑掉了。

00:46:16 - 00:46:17
這就是我們的口訣：

00:46:17 - 00:46:20
內外放火殺強人，外加一架飛機。

00:46:20 - 00:46:23
蔡聖偉老師原始的版本是沒有這個飛機的。

00:46:23 - 00:46:25
飛機是我自己加上去的。

00:46:25 - 00:46:29
來，這個圖，就跟各位講，有什麼犯罪，有罰預備，

00:46:29 - 00:46:30
記得這個口訣，

00:46:30 - 00:46:33
內外放火殺強人再加上一架飛機。

00:46:34 - 00:46:36
來，我們看喔，有哪些犯罪有罰預備？

00:46:36 - 00:46:38
內是內亂。

00:46:38 - 00:46:39
外是外患

00:46:40 - 00:46:42
放火就是一七三的放火罪

00:46:43 - 00:46:44
殺搶人

00:46:44 - 00:46:48
殺是殺人，搶是強盜，人是擄人勒贖

00:46:48 - 00:46:49
記得喔

00:46:49 - 00:46:52
內亂外患放火殺人強盜擄人勒贖

00:46:52 - 00:46:57
啊不要忘記這一架飛機，185之一的劫持民用航空器罪。

00:46:58 - 00:47:02
記得這個圖喔，內外放火殺強盜再加上這一架飛機。

00:47:03 - 00:47:08
內亂外患放火殺人強盜擄人勒贖，還有劫持民用航空器。

00:47:08 - 00:47:11
這是有罰預備的犯罪，就是這些喔。

00:47:12 - 00:47:16
我說了，原本蔡聖偉老師的圖是沒有這個飛機的，飛機是我自己加上去的。

00:47:17 - 00:47:21
啊然後之前喔，我現在在網路上有看到有人在討論，

00:47:21 - 00:47:25
說你們求學的時代有沒有什麼口訣是讓你難忘的。

00:47:26 - 00:47:27
當時網路上的討論，

00:47:28 - 00:47:32
比較多在講的都是一個化學的口訣，我不知道同學以前高中有沒有背過。

00:47:33 - 00:47:38
那個化學的口訣是，氯溴碘、拱銅銀金鉑。

00:47:39 - 00:47:40
你們有背過這個口訣嗎？

00:47:41 - 00:47:43
我我我以前高中的時候有背過。

00:47:43 - 00:47:45
什麼呂秀蓮共同引薦他什麼的喔？

00:47:46 - 00:47:48
對啊，就以前化學老師就講這個口訣啊。

00:47:48 - 00:47:50
當時呂秀蓮是副總統啊,

00:47:50 - 00:47:53
然後老師就說你們講快一點,你們講快一點,看會變什麼,

00:47:53 - 00:47:56
然後有同學就說,啊就秀蓮共同引薦他,不要,我才不要,

00:47:56 - 00:47:58
然後化學老師就說,你怎麼這樣講,

00:47:58 - 00:48:00
我沒有叫你侮辱國家的副元首。

00:48:00 - 00:48:00
話題就結束了

00:48:00 - 00:48:02
你看我一次記到現在

00:48:03 - 00:48:04
那個口訣在講什麼

00:48:04 - 00:48:05
其實我早就忘了

00:48:05 - 00:48:06
我化學被當

00:48:06 - 00:48:06
我早就忘了

00:48:07 - 00:48:08
可是我記得讓現在

00:48:08 - 00:48:11
我記得那篇討論串下面最多人講就什麼綠點那個

00:48:12 - 00:48:16
然後下面有個同學就回內外放火殺人強姦外加一下飛機

00:48:16 - 00:48:17
我看到好高興

00:48:17 - 00:48:17
這是我的學生

00:48:18 - 00:48:19
因為蔡老師原本的版本是沒有飛機的

00:48:19 - 00:48:20
飛機是我加上去的哈

00:48:21 - 00:48:21
所以記得這個圖

00:48:22 - 00:48:24
內外放火殺強人，再加上一下飛機

00:48:24 - 00:48:26
這就是有預謀的犯罪

00:48:27 - 00:48:29
考試作弊的同學雖然你們有違法點

00:48:29 - 00:48:30
可是我跟你們說

00:48:30 - 00:48:32
有違法點你們法條還是要守

00:48:32 - 00:48:34
不然當場你們根本就不會想到

00:48:34 - 00:48:35
不會想到你就不會去煩

00:48:35 - 00:48:37
不會去煩你就會漏氣

00:48:37 - 00:48:37
知道嗎

00:48:38 - 00:48:40
像有些考試三天兩頭的同學

00:48:40 - 00:48:42
那更不用說沒有複習

00:48:42 - 00:48:44
當然法條要守，所以記得喔

00:48:44 - 00:48:47
內外放火殺強人再加上這一架飛機喔

00:48:48 - 00:48:49
這個是我們依法預備的犯罪

00:48:50 - 00:48:52
所以這個函授的筆記公讀生會辛苦一點

00:48:52 - 00:48:54
要畫這種奇怪的東西

00:48:54 - 00:48:56
我課程前端畫的佩佩豬

00:48:56 - 00:48:58
後來有同學傳給我看

00:48:59 - 00:49:00
工讀生畫的還

00:49:00 - 00:49:00
不錯

00:49:01 - 00:49:02
對他整隻佩佩豬畫出來

00:49:02 - 00:49:05
但他畫的佩佩豬那個鼻子長到不太合理

00:49:06 - 00:49:07
就是鼻子超長

00:49:07 - 00:49:08
我有PO在我IG上

00:49:09 - 00:49:10
然後下面有同學回

00:49:11 - 00:49:13
那佩佩豬一定是有說謊

00:49:13 - 00:49:13
所以鼻子才變長

00:49:14 - 00:49:15
我都沒有想到對不對

00:49:15 - 00:49:15
同學好有創意

00:49:16 - 00:49:16
好

00:49:17 - 00:49:19
所以這個是我們講有罰預備的犯罪

00:49:20 - 00:49:20
來

00:49:20 - 00:49:22
那我跟各位說啊

00:49:22 - 00:49:24
預備犯有分形式跟實質嘛

00:49:24 - 00:49:27
實質預備犯通常沒有什麼好討論的

00:49:27 - 00:49:30
因為實質預備犯那個就是分則解釋的問題

00:49:30 - 00:49:31
的問題

00:49:31 - 00:49:32
我們講一下形式預備犯

00:49:33 - 00:49:36
很多學者遲疑形式預備犯的正當性

00:49:37 - 00:49:37
為什麼呢

00:49:38 - 00:49:40
因為很多學者會講說啊

00:49:40 - 00:49:44
你講什麼叫預備犯罪的準備行為，這叫預備？

00:49:44 - 00:49:44
好。

00:49:44 - 00:49:46
那問題來了，什麼叫準備？

00:49:46 - 00:49:47
你們想喔。

00:49:47 - 00:49:50
持刀殺人的人，他的準備行為有什麼？

00:49:52 - 00:49:53
拿刀埋伏是不是準備

00:49:54 - 00:49:54
是

00:49:55 - 00:49:59
那拿刀埋伏的路上，前往埋伏這個路上是不是準備

00:49:59 - 00:49:59
是

00:50:00 - 00:50:01
那再往前

00:50:01 - 00:50:03
買刀是不是準備

00:50:03 - 00:50:04
是，也是

00:50:04 - 00:50:07
那買刀前面調查被害者的行蹤是不是準備

00:50:07 - 00:50:08
是啊，也是啊

00:50:09 - 00:50:12
甚至買刀錢他在比價

00:50:12 - 00:50:14
想說我要

00:50:14 - 00:50:15
買這把刀

00:50:15 - 00:50:21
我到底是要去五金行，要去小北，還是要上網買，還是要怎麼樣

00:50:21 - 00:50:22
他在做比價

00:50:23 - 00:50:24
那你現在要講那個是不是準備

00:50:24 - 00:50:25
也是啊對不對

00:50:26 - 00:50:30
所以很多學者會講說，你講準備行為就要預備

00:50:30 - 00:50:32
那犯罪的準備行為超多

00:50:32 - 00:50:35
這樣的話預備犯根本不符合法律的明確性

00:50:35 - 00:50:35
瞭解嗎

00:50:35 - 00:50:39
所以有些學者他們會反對預備犯，就是說預備的定義太過廣泛

00:50:39 - 00:50:41
所以後來有一派的說法是說

00:50:42 - 00:50:45
預備行為並不是什麼樣的準備都算

00:50:45 - 00:50:46
唯有什麼呢

00:50:46 - 00:50:47
那你來看到課本這邊

00:50:50 - 00:50:55
唯有啊，重要性，重要的準備行為，這個才算

00:50:56 - 00:50:58
要構成犯罪的重要準備行為才算

00:50:58 - 00:51:02
所以同樣是拿到槍，埋伏，這個可以算

00:51:03 - 00:51:06
拿刀走去埋伏地，勉勉強強可以算

00:51:07 - 00:51:09
再往前的那些，通通不算

00:51:09 - 00:51:09
知道嗎

00:51:09 - 00:51:10
所以有人說

00:51:10 - 00:51:14
重要的準備行為，這才能算是預備

00:51:14 - 00:51:15
有這樣線索的說法

00:51:17 - 00:51:18
好

00:51:18 - 00:51:19
所以這個是我們講的預備

00:51:19 - 00:51:21
再來翻過來，著手

00:51:23 - 00:51:23
其實

00:51:23 - 00:51:26
著手這個東西我們前面已經偷偷講過很多次了

00:51:26 - 00:51:27
著手指的是什麼呢

00:51:29 - 00:51:33
著手指的是行為人開始做這個行為

00:51:33 - 00:51:34
這個叫著手

00:51:34 - 00:51:34
開始做

00:51:35 - 00:51:36
記得喔

00:51:36 - 00:51:37
著手才是未遂喔

00:51:38 - 00:51:42
我們第一堂課講客觀構成要件沒有完全實現

00:51:42 - 00:51:44
而且行為人主觀上具有故意叫未遂

00:51:44 - 00:51:45
其實第一堂課那個說法不太精確

00:51:46 - 00:51:50
因為光是客觀構成要件沒有完全實現，主觀上有故意

00:51:50 - 00:51:52
那個也不能排除預備的情況啊

00:51:52 - 00:51:52
對不對

00:51:53 - 00:51:54
重點是什麼

00:51:54 - 00:51:54
要著手，知道嗎

00:51:55 - 00:51:55
所以我說嘛

00:51:56 - 00:52:00
我拿刀想殺人，我還在被害人的距離

00:52:00 - 00:52:00
外面埋伏就被警察抓了。

00:52:00 - 00:52:00
這只是什麼而已？

00:52:04 - 00:52:05
預備而已有。

00:52:05 - 00:52:09
被害人出現了我拿刀揮他,那才叫著手,那才叫未遂哦。

00:52:09 - 00:52:11
所以有著手才叫未遂。

00:52:11 - 00:52:15
換句話說,著手跟未遂就是一體兩面。

00:52:16 - 00:52:19
有著手必然就進到未遂的階段。

00:52:20 - 00:52:22
好,那什麼叫著手,我們等一下當然會說。

00:52:23 - 00:52:26
著手之後啊,會遇到行為的完成。

00:52:26 - 00:52:29
就是啊,該做的事做完了,這個叫行為的完成。

00:52:29 - 00:52:35
行為的完成在刑法上比較不具有重要性,他只是在講一個現象,你該做的事做完了,這個叫行為的完成。

00:52:35 - 00:52:40
所以以殺人罪來講,行為人砍完了,看到被害人倒下去了,這叫行為的完成。

00:52:41 - 00:52:44
接著一分鐘之後,被害人氣絕身亡,這個叫犯罪的既遂,應該不會有疑問。

00:52:46 - 00:52:48
最後來說什麼叫終了啊。

00:52:48 - 00:52:48
我再講一次哦。

00:52:49 - 00:52:50
終了跟完成不一樣喔。

00:52:51 - 00:52:53
完成是行為做完。

00:52:54 - 00:52:55
終了是什麼？

00:52:55 - 00:52:57
法益侵害結束。

00:52:58 - 00:52:59
不要混淆，知道嗎？

00:52:59 - 00:53:01
因為中文本身看起來很像，但這個意思不一樣。

00:53:02 - 00:53:03
完成就是行為做完而已。

00:53:04 - 00:53:07
終了是指法益侵害的結束。

00:53:08 - 00:53:08
記得喔。

00:53:08 - 00:53:10
完成跟終了不一樣喔。

00:53:11 - 00:53:12
我強調過很多次啦。

00:53:12 - 00:53:18
因為如果你把完成跟終了混在一起的話,你以後學相續的共同正犯一定會學不懂。

00:53:18 - 00:53:20
終了是法益侵害的結束。

00:53:20 - 00:53:25
那同時我也強調,並不是每個犯罪都拉得出紅色這一段。

00:53:27 - 00:53:30
既遂後終了前這一段,紅色這一段拉得出來的。

00:53:31 - 00:53:34
那只有少數的犯罪，比如說繼續犯。

00:53:35 - 00:53:37
或者比如說像竊盜那種財產犯罪。

00:53:38 - 00:53:40
少數的犯罪才拉得出紅色這一段喔。

00:53:41 - 00:53:42
殺人傷害會不會有紅色這一段？

00:53:43 - 00:53:43
不會喔。

00:53:43 - 00:53:47
殺人傷害這種一般的狀態犯，既遂的同時就終止了喔。

00:53:48 - 00:53:50
還記得吧，我們前面有講過。

00:53:50 - 00:53:53
並不是每個犯罪都拉得出紅色這一段喔，記得喔。

00:53:55 - 00:53:56
好。

00:53:56 - 00:53:57
所以這個是我們講到啊。

00:53:57 - 00:53:58
關於這個。

00:53:59 - 00:54:00
這裡。

00:54:00 - 00:54:02
講什麼呢，犯罪的行為階段。

00:54:02 - 00:54:06
好，接下來237頁，第二大點，未遂犯的處罰根據。

00:54:08 - 00:54:09
這是一個非常學理的概念。

00:54:11 - 00:54:13
這個東西啊，它不會用來解決個案。

00:54:14 - 00:54:16
它只是在跟我們談一個問題：

00:54:16 - 00:54:18
為什麼未遂犯要被處罰？

00:54:19 - 00:54:21
所以這個東西我們就當嘗試聽一聽。

00:54:21 - 00:54:24
因為現在這個年代的考題不流行考問答題。

00:54:26 - 00:54:29
20年前的考題真的會問你哦，未遂犯的處罰根據為何。

00:54:30 - 00:54:31
現在不會啦。

00:54:32 - 00:54:33
不能講，現在不會。

00:54:34 - 00:54:39
應該說，現在的國考，尤其是三等這樣的國考，基本上不會考問答題。

00:54:40 - 00:54:41
法研所有的時候會有哦。

00:54:42 - 00:54:46
因為法研所他要收的學生，要去有這種思考學理的能力嘛。

00:54:46 - 00:54:48
所以法研所他有的時候會考問答題喔。

00:54:48 - 00:54:49
國考一般不會，好。

00:54:50 - 00:54:53
我們講未遂犯的處罰根據是什麼。

00:54:53 - 00:54:53
你們想過啊。

00:54:55 - 00:54:57
為什麼未遂的行為是要被處罰的？

00:54:58 - 00:55:00
未遂犯其實沒有造成法益侵害啊。

00:55:00 - 00:55:01
對不對？

00:55:01 - 00:55:04
我要殺人，我拿刀去砍被害人，那沒有砍到啊，被害人跑掉了啊。

00:55:05 - 00:55:06
沒有生命法益的侵害啊。

00:55:07 - 00:55:07
為什麼要被處罰。

00:55:08 - 00:55:11
還有現在更常見的詐欺未遂。

00:55:13 - 00:55:14
同學們接過詐騙電話，一定有吧，對不對？

00:55:15 - 00:55:18
我們每天都籠罩在各式各樣的詐騙訊息當中。

00:55:19 - 00:55:21
臉書一直推送詐騙廣告給我啊。

00:55:22 - 00:55:22
一堆啊。

00:55:22 - 00:55:24
張國煒邀你飆股。

00:55:25 - 00:55:26
你看不覺得很可笑嗎？

00:55:26 - 00:55:29
張國煒，星宇航空的董事長，他邀你去飆股幹什麼？

00:55:30 - 00:55:31
就有人會信，真的有人會信。

00:55:31 - 00:55:33
張國煒邀你飆股，還有什麼一大堆啦。

00:55:33 - 00:55:36
網路上有一大堆那種詐騙訊息。

00:55:38 - 00:55:39
我記得。

00:55:40 - 00:55:42
我真的好久沒有接到詐騙電話了。

00:55:42 - 00:55:43
感覺好懷念。

00:55:44 - 00:55:45
真的好久沒接到了。

00:55:46 - 00:55:48
我上一次接到詐騙電話可能是五六年前的事喔。

00:55:48 - 00:55:50
當時喔，我想起來了。

00:55:50 - 00:55:52
我當時接到詐騙電話是這樣子。

00:55:53 - 00:55:56
那時候啊，我在蕾莉歐的網站買香氛。

00:55:56 - 00:55:58
有聽過蕾莉歐吧。

00:55:58 - 00:55:59
就是那個香氛品牌，因為我蠻喜歡。

00:56:00 - 00:56:00
喜歡把家裡弄得香香的，所以我很喜歡買香氛。

00:56:00 - 00:56:00
我那個時候買蕾莉歐的香氛網購。

00:56:00 - 00:56:01
啊網購完沒有幾天呢，就有人自稱是蕾莉歐打給我。

00:56:11 - 00:56:16
他就問我說你是不是買的那個什麼黑檀木的那個擴香瓶，然後還有幾根那個薰香竹，我說對啊，沒有錯啊。

00:56:19 - 00:56:25
接著，他就說啦，他說這位先生抱歉，我不小心把你設定成廠商戶。

00:56:25 - 00:56:28
這個每個月呢都會定期從你的信用卡當中扣款。

00:56:29 - 00:56:32
你有要解除這個定期扣款的設定嗎？

00:56:32 - 00:56:33
那聽懂就知道是詐騙嘛。

00:56:33 - 00:56:34
我就跟他說。

00:56:34 - 00:56:37
沒關係，我不想解除。

00:56:37 - 00:56:40
你們生意那麼差，都給你們扣啊，那沒多少錢啊，當作贊助你們啦。

00:56:41 - 00:56:43
不然你們倒了，我香氛找誰買。

00:56:43 - 00:56:47
我就跟他這樣說，說沒關係，多扣一點沒關係，我不介意，我錢多的是。

00:56:47 - 00:56:49
對方聽到就把電話掛了，好無趣，對不對。

00:56:50 - 00:56:52
照理來說這是詐欺未遂。

00:56:52 - 00:56:53
對啊，這個是啊。

00:56:53 - 00:56:57
因為實務說詐欺罪只要開始施用詐術就著手。

00:56:57 - 00:56:59
不用被害人陷於錯誤，不用喔。

00:56:59 - 00:57:00
施用詐術就著手。

00:57:00 - 00:57:02
對啊，這個是詐欺未遂啊。

00:57:02 - 00:57:04
那你說未遂犯為什麼要處罰？

00:57:05 - 00:57:06
對啊，為什麼未遂犯要處罰？

00:57:07 - 00:57:08
他沒有造成我的損失。

00:57:09 - 00:57:11
我還把它當笑話每年講給同學聽。

00:57:11 - 00:57:13
對啊，對我來說沒有任何的損失，為什麼會處罰？

00:57:13 - 00:57:16
所以來，我們來看，未遂犯處罰的根據是什麼呢？

00:57:17 - 00:57:20
下面幾說，第一個叫客觀未遂論。

00:57:21 - 00:57:23
客觀未遂論講說，為什麼要處罰未遂犯？

00:57:23 - 00:57:25
因為他有危險。

00:57:26 - 00:57:27
很簡單，因為他有危險。

00:57:28 - 00:57:30
你想，詐騙集團騙不到我。

00:57:30 - 00:57:32
因為我的工作。

00:57:32 - 00:57:34
日常就會在處理這些案件。

00:57:34 - 00:57:35
我知道他們有什麼手法。

00:57:36 - 00:57:37
他們當然騙不到我。

00:57:37 - 00:57:39
可是不代表騙得到別人啊。

00:57:39 - 00:57:43
你們知道有很多被詐騙集團騙的，你們要有一個認知。

00:57:43 - 00:57:45
會被詐騙集團騙的不見得都是老人喔。

00:57:46 - 00:57:47
很多年輕人被騙,真的哦。

00:57:48 - 00:57:49
我經手接過年輕人的案子啊。

00:57:49 - 00:57:52
就那種大學生,剛出社會的人,20幾歲人都有啊。

00:57:53 - 00:57:58
就是有些他們的話術,一時之間可能被害人真的不會相信,真的不會去懷疑啦,我真的遇過。

00:58:00 - 00:58:01
所以我的意思就是說,

00:58:02 - 00:58:06
客觀未遂論的主張就是，這個詐騙行為這一次沒有既遂，

00:58:07 - 00:58:08
那只是他騙錯人啊，

00:58:09 - 00:58:12
騙到那個笨一點的，或者騙到那個反應沒有那麼靈敏的，

00:58:12 - 00:58:14
他就被騙了啊，對不對？

00:58:14 - 00:58:16
所以客觀未遂論的主張是什麼呢？

00:58:17 - 00:58:26
就是覺得說，未遂的行為，雖然沒有造成實際的損害，但是他有法益侵害的危險。

00:58:26 - 00:58:26
知道嗎？

00:58:27 - 00:58:29
這個是客觀未遂論的想法，因為他有法益侵害的危險。

00:58:30 - 00:58:34
好，相對來說第二個說法叫做主觀未遂論。

00:58:35 - 00:58:37
主觀未遂論的想法不太一樣。

00:58:38 - 00:58:40
主觀未遂論覺得為什麼要罰未遂犯？

00:58:41 - 00:58:43
因為未遂犯跟既遂犯一樣壞,

00:58:44 - 00:58:47
一樣壞，他著眼於行為人的法敵對意思。

00:58:47 - 00:58:48
你們想一想喔,

00:58:49 - 00:58:53
詐欺既遂的人跟詐欺未遂的人,

00:58:54 - 00:58:55
他的壞應該是一樣的吧。

00:58:56 - 00:58:58
只是有既遂沒有既遂，那是偶然嘛，對不對？

00:58:58 - 00:59:03
所以主觀未遂論的著眼點是什麼呢？行為人腦中的壞東西，

00:59:03 - 00:59:04
這個是主觀未遂論。

00:59:04 - 00:59:09
接著德國的通說叫主客觀混合理論，又叫印象理論。

00:59:10 - 00:59:13
這一說的想法是，這一說其實本質上是一種主觀理論。

00:59:14 - 00:59:16
但是它不是純粹的主觀理論。

00:59:16 - 00:59:18
他會覺得為什麼要罰未遂犯呢？

00:59:18 - 00:59:25
他說啊，未遂的行為人透過客觀上的行為，展現出他的法敵對意思。

00:59:26 - 00:59:28
那行為人透過他客觀的行為

00:59:28 - 00:59:31
展現了法敵對意思之後，

00:59:31 - 00:59:33
讓其他看到的人，

00:59:33 - 00:59:35
讓知道的人會產生一種

00:59:35 - 00:59:38
法律的威信被動搖的形象。

00:59:38 - 00:59:41
進而未遂犯是值得被處罰的。

00:59:42 - 00:59:42
這什麼意思？

00:59:43 - 00:59:46
我們以各位，我們每個人都經歷過的詐欺未遂來講，

00:59:47 - 00:59:47
你想喔，

00:59:48 - 00:59:50
當你接收到詐騙訊息的時候，

00:59:51 - 00:59:53
就算你沒有被騙,

00:59:53 - 00:59:54
一般人會有什麼想法？

00:59:55 - 00:59:58
會覺得說為什麼這個國家治安那麼差，詐騙那麼多。

00:59:58 - 00:59:59
大家還真的

01:00:00 - 01:00:00
有在防範嗎？

01:00:00 - 01:00:02
會有這樣的想像，對不對？

01:00:02 - 01:00:04
印象理論強調的就是這個面向，知道吧？

01:00:04 - 01:00:07
雖然未遂犯沒有造成實質的損害，

01:00:07 - 01:00:11
可是透過他的行為展現出他的法敵對意思，會怎麼樣？

01:00:11 - 01:00:16
會讓一般人民產生一種法律秩序受到動搖的想像。

01:00:16 - 01:00:17
這叫印象理論，OK喔。

01:00:17 - 01:00:18
這樣想。

01:00:20 - 01:00:20
好，我說。

01:00:21 - 01:00:22
這幾種說法。

01:00:22 - 01:00:24
考實例題不太會用到。

01:00:25 - 01:00:27
他就只在跟你講說為什麼要罰未遂犯,

01:00:28 - 01:00:29
那我跟各位說啦,

01:00:31 - 01:00:32
這幾種說法當中,

01:00:33 - 01:00:36
留德的老師大部分採的是印象理論,

01:00:37 - 01:00:38
因為德國的刑法真的這樣寫,

01:00:40 - 01:00:42
留德老師大部分採印象理論,

01:00:45 - 01:00:50
留日的老師呢,大部分採的是客觀未遂論,

01:00:50 - 01:00:51
大概是這樣,

01:00:52 - 01:00:53
你說那主觀未遂論呢,

01:00:54 - 01:00:55
那個幾乎沒有人採,

01:00:55 - 01:00:57
因為那個是歷史上的說法,知道嗎?

01:00:57 - 01:00:59
所以國內大概是有這樣的現象,

01:01:40 - 01:01:43
等一下我會跟各位講,未遂犯的處罰根據,

01:01:44 - 01:01:47
對於後面的法條會產生什麼影響

01:01:47 - 01:01:50
這個等下再來說，我們先把學理的概念看到這邊就好。

01:01:50 - 01:01:52
好，那我們就先休息個10分鐘。

01:01:52 - 01:01:55
等一下呢，我們再來看討論未遂犯的共同要件。

01:02:00 - 01:02:00
叫故意喔。

01:02:01 - 01:02:02
再來第二個要著手。

01:02:02 - 01:02:03
我們剛剛圖畫過了,

01:02:03 - 01:02:05
著手之後才有未遂喔,

01:02:06 - 01:02:09
著手前那個頂多是陰謀或預備,

01:02:09 - 01:02:11
陰謀預備大部分的犯罪是沒有罰的,

01:02:11 - 01:02:12
所以要著手。

01:02:12 - 01:02:13
再來第三個是不遂

01:02:14 - 01:02:15
沒有實現構成要件

01:02:15 - 01:02:17
最後要法律有處罰的明文規定

01:02:18 - 01:02:20
四大要件：故意、著手、不遂、明文。

01:02:21 - 01:02:23
好，那我們這裡呢，故意我們剛剛講的嘛

01:02:24 - 01:02:26
接下來我們來看著手。

01:02:27 - 01:02:28
什麼叫做著手呢？

01:02:29 - 01:02:31
我們終於要來正式講這個東西了,

01:02:31 - 01:02:32
什麼叫著手？

01:02:32 - 01:02:36
著手指的是行為人開始做構成要件。

01:02:36 - 01:02:37
這個叫做著手,

01:02:37 - 01:02:38
開始做，這樣叫做著手。

01:02:39 - 01:02:41
所以各位啊，我們粗略地講說，

01:02:41 - 01:02:44
著手是指行為人開始做。

01:02:45 - 01:02:46
那麼接下來的問題是，

01:02:46 - 01:02:48
什麼叫做開始做？

01:02:49 - 01:02:51
因為開始做是一個很籠統的觀念，

01:02:51 - 01:02:52
很籠統的標準，

01:02:52 - 01:02:55
所以我們接著會問什麼叫做開始做呢？

01:02:56 - 01:02:58
於是我們來看到下面這邊。

01:02:59 - 01:03:41
關於著手的認定，

01:03:41 - 01:03:43
這邊有幾種不同的說法，

01:03:43 - 01:03:46
第一個說法叫做形式客觀說，

01:03:46 - 01:03:47
這個是最早以前的說法。

01:03:48 - 01:03:49
這說法啊，非常簡單。

01:03:49 - 01:03:51
非常好判斷。

01:03:51 - 01:03:53
形式客觀說的意思就是，

01:03:54 - 01:03:59
要行為人開始做嚴格意義的構成要件行為，

01:03:59 - 01:04:00
才是著手。

01:04:00 - 01:04:02
嚴格意義的構成要件行為才算著手，好，這個說法算歷史上的說法。

01:04:05 - 01:04:09
真說啊,雖然有人,雖然以前有人採,但現在採的人不多了,為什麼?

01:04:10 - 01:04:17
真說雖然好處上是說它很明確沒有錯,可是它對著手的認定超嚴格,所以採這說,恐怕不利於法益的保護。

01:04:21 - 01:04:23
所以這說呢,現在比較少人採。

01:04:23 - 01:04:24
於是我們來看第二說。

01:04:26 - 01:04:28
第二說叫做實質客觀說。

01:04:29 - 01:04:32
這個實質客觀說啊，是比較後期的說法。

01:04:32 - 01:04:36
這一說呢，他就放棄了所謂嚴格意義的構成要件行為，因為這說也知道，你想嚴格意義的構成要件行為，會讓標準變得僵化。

01:04:43 - 01:04:45
所以這一說呢，後來就放棄這個標準。

01:04:45 - 01:04:53
這一說反而認為說啊，只要行為人他做到一個，讓法益有迫切危險的階段，那他就算是有著手。

01:04:56 - 01:05:03
客觀上來看啊，這個行為如果對法益有迫切的危險呢，他就可以認為有著手，這個叫做實質客觀說。

01:05:04 - 01:05:13
那個以前的實質客觀說啊，下面又有好幾個分支，比如說什麼中間密切先行行為說啊，中間行為說啊或什麼的。

01:05:13 - 01:05:19
但我們現在採的就是其中具有代表性的說法，這個叫做行為危險說。

01:05:19 - 01:05:21
那這種行為危險說的說法，就是說怎麼樣？

01:05:22 - 01:05:29
只要行為人做到一個階段，就是這個階段會讓法益產生迫切的危險，那行為人就著手了。

01:05:32 - 01:05:42
所以照這一說啊，殺人罪，比如說槍殺的情形，不用到真的扣板機喔，瞄準就算喔。

01:05:42 - 01:05:44
因為瞄準的話再過沒幾秒就扣板機了嘛。

01:05:44 - 01:05:46
所以瞄準的階段可不可以認為是有迫切的危險？

01:05:46 - 01:05:47
可以。

01:05:47 - 01:05:49
這個叫做實質客觀說，好，叫實質客觀說。

01:05:50 - 01:05:56
好，所以照實質客觀說的話，我再舉另外一個例子，下面註釋這個104年的判決。

01:05:57 - 01:05:59
這一則判決的事實很有趣。

01:06:00 - 01:06:00
就是有個成年的男生，跟他還在讀國中的女朋友，兩個人相約去女生家打炮。

01:06:07 - 01:06:10
那這個男生到了女生的房間中呢，他沒有鎖門。

01:06:11 - 01:06:13
他就只把房門關起來。

01:06:13 - 01:06:19
接著這個男生就跟女生在房間裡面親嘴、愛撫，在做這些前戲。

01:06:19 - 01:06:21
接著雙方的衣服都脫光了。

01:06:22 - 01:06:24
男生的生殖器也戴上保險套了。

01:06:25 - 01:06:30
正當男生的生殖器距離女生的陰道大概三公分左右距離的時候，女生的弟弟忽然開門進來了。

01:06:35 - 01:06:38
想當然男生應該瞬間就軟了吧，這事情後來也沒辦法做了嘛。

01:06:39 - 01:06:41
這件行為人著手了沒有？

01:06:42 - 01:06:44
這個判決我每次看到都一種感覺啊。

01:06:45 - 01:06:46
這個判決在跟我們講另外一件事啦。

01:06:47 - 01:06:49
在家打炮記得要鎖門。

01:06:49 - 01:06:55
真的，如果當初這對男女有稍微謹慎一點，有所警惕的話，就不會有這個案件啦，不是嗎？

01:06:55 - 01:06:56
有所警惕的話。

01:06:57 - 01:06:59
那弟弟發現怎麼門鎖起來。

01:07:00 - 01:07:04
不然，那女生一定會辦法說你很煩，在忙，一定的嘛，就不會有這個案子了嘛。

01:07:05 - 01:07:08
這個鎖門，不管你打的炮合法或不合法都一樣啊，這個鎖門。

01:07:08 - 01:07:10
好，這一則判決的說法是。

01:07:11 - 01:07:17
當男生的陰莖套上保險套，距離女生的陰道三公分左右的距離的時候，來，你來看到後面這邊哦。

01:07:21 - 01:07:22
240頁。

01:07:23 - 01:07:25
後面這裡說呢，客觀上。

01:07:27 - 01:07:30
他說這個行為跟性交具有直接密切的關聯。

01:07:30 - 01:07:34
客觀上可以認為已經著手，知道嗎？

01:07:34 - 01:07:38
所以做到這個階段，確實已經著手了，不用說陰莖到外陰部摩擦，不用到這個階段。

01:07:38 - 01:07:42
套上保險套，距離女生的陰道大概三公分左右的距離啊，因為沒意外的話。

01:07:42 - 01:07:44
過幾秒就插入的嘛。

01:07:44 - 01:07:47
所以這個時候呢，確實可以說這個行為已經著手，OK嗎？

01:07:47 - 01:07:48
這個確實可以認為已經著手啊。

01:07:56 - 01:07:58
好，所以這是一個實務上面的案例。

01:07:59 - 01:07:59
那。

01:08:00 - 01:08:00
這個案例的話

01:08:00 - 01:08:00
當然我每次在看這個判決都想說那個三公分是怎麼算的

01:08:06 - 01:08:07
那一定是女生說的嘛

01:08:07 - 01:08:09
說距離三公分

01:08:09 - 01:08:13
所以女生怎麼算是有量過她男朋友的size然後這樣這樣做一個對比嗎

01:08:13 - 01:08:15
不知道,反正判決是寫三公分

01:08:16 - 01:08:17
好,所以這個是

01:08:18 - 01:08:19
這個是我們講的

01:08:19 - 01:08:20
客觀來說

01:08:20 - 01:08:22
再來第三說叫主觀說

01:08:23 - 01:08:25
那個主觀說也是一個歷史上的說法

01:08:26 - 01:08:27
國內應該也沒有人採

01:08:27 - 01:08:34
主觀說是說呢，看行為人什麼時候覺得他開始做，那個時點就是著手

01:08:34 - 01:08:37
這一說幾乎沒有被採取過

01:08:37 - 01:08:40
因為這一說，說真的他技術上很難判斷

01:08:41 - 01:08:43
你怎麼知道行為人在想什麼

01:08:43 - 01:08:43
對不對

01:08:43 - 01:08:49
所以這一說歷來呢，幾乎就是只有被提出，沒有人真的支持這一說了，沒有

01:08:50 - 01:08:52
於是我們來看到目前通說的說法

01:08:52 - 01:08:56
通說採的呢,叫做主客觀混合說

01:08:58 - 01:09:00
這一說的主客觀混合說

01:09:01 - 01:09:04
同學,不要把它當作是主加客的大雜燴

01:09:04 - 01:09:04
不是

01:09:05 - 01:09:07
主客觀混合說它在混合什麼

01:09:08 - 01:09:08
我跟各位說

01:09:09 - 01:09:11
這一說在混合的地方是這樣

01:09:12 - 01:09:13
他認為呢

01:09:14 - 01:09:15
來，他認為區分兩件事

01:09:16 - 01:09:18
第一個是判斷的對象

01:09:19 - 01:09:20
就是我們判斷的課題

01:09:21 - 01:09:23
第二個是判斷的標準

01:09:25 - 01:09:26
主客觀混合說強調一件事

01:09:27 - 01:09:30
他說，我們在判斷著手的時候

01:09:30 - 01:09:32
判斷的對象

01:09:33 - 01:09:37
要用行為人腦袋當中的犯罪計畫來做判斷

01:09:38 - 01:09:39
所以第一個

01:09:40 - 01:09:42
判斷的對象

01:09:43 - 01:09:44
不是客觀上真實的事實

01:09:44 - 01:09:44
不是喔

01:09:44 - 01:09:48
而是什麼呢，行為人腦中的犯罪計畫

01:09:48 - 01:09:51
所以他的主觀面是在這個地方

01:09:51 - 01:09:55
知道嗎，他以行為人的犯罪計畫作為判斷的對象

01:09:55 - 01:09:56
好，再來

01:09:57 - 01:09:58
那主，那他的客觀面在哪

01:09:58 - 01:09:58
在裡面

01:10:00 - 01:10:00
在哪裡呢?

01:10:01 - 01:10:01
這樣說啊,

01:10:01 - 01:10:05
我們要把它這個犯的計畫拿去給一般的標準去做判斷。

01:10:06 - 01:10:06
我們看什麼呢?

01:10:07 - 01:10:09
從一般人的眼中，

01:10:09 - 01:10:12
行為人做到這個階段的話，

01:10:12 - 01:10:16
會不會對保護的法益產生迫切的危險性。

01:10:16 - 01:10:17
所以各位啊，

01:10:17 - 01:10:22
主客觀混合說他的判斷標準，其實跟實質客觀說是差不多的。

01:10:23 - 01:10:24
有沒有發現？

01:10:24 - 01:10:25
他們主要的差別在哪裡？

01:10:26 - 01:10:27
判斷的對象不一樣，

01:10:27 - 01:10:28
知道吧？

01:10:28 - 01:10:31
客觀來說，不管是形式客觀或實質客觀，

01:10:32 - 01:10:34
他看的都是純粹的客觀事實喔。

01:10:35 - 01:10:35
知道吧？

01:10:35 - 01:10:37
他的判斷對象都是純粹的客觀事實喔。

01:10:37 - 01:10:40
而主客觀混合說，

01:10:41 - 01:10:42
他的判斷對象是什麼？

01:10:43 - 01:10:46
行為人主觀上的犯罪計畫

01:10:46 - 01:10:46
知道嗎？

01:10:46 - 01:10:47
他的判斷對象是犯罪計畫

01:10:48 - 01:10:49
兩者不同是在這邊。

01:10:51 - 01:10:54
如果你們對那個主客觀和說對著手理論有興趣的話

01:10:55 - 01:10:58
蔡聖偉老師最近有一篇文章，我覺得寫得還不錯。

01:11:38 - 01:11:40
那篇文章叫做惡視力。

01:11:41 - 01:11:42
不是黑道惡勢力的那個勢力，

01:11:42 - 01:11:44
是眼睛很不好的那個惡視力。

01:11:45 - 01:11:48
蔡聖偉老師很有趣，他的文章都很喜歡用諧音梗，超多。

01:11:48 - 01:11:50
那十幾二十篇都是諧音梗。

01:11:50 - 01:11:53
其中這一篇惡視力，就在講著手理論。

01:11:53 - 01:11:54
有興趣的話可以去看，

01:11:54 - 01:12:00
這個應該是前大概半年左右的文章啦，寫的內容還蠻有趣，還蠻淺白的。

01:12:00 - 01:12:00
判斷對象，然後把這個事實拿給一般人的標準去判斷，看這個行為人做到這邊呢，會不會導致構成要件的侵害危險，會不會導致法律的侵害危險。

01:12:11 - 01:12:13
好，所以這個是它的特色，那我們剛剛講，這一說的判斷標準其實跟實質客觀說差不多，對不對？差別在哪裡？

01:12:19 - 01:12:20
在判斷對象嘛。

01:12:21 - 01:12:21
對啊，在判斷對象。

01:12:22 - 01:12:25
所以差別在判斷對象的話，在審判力會有差異。

01:12:26 - 01:12:32
這兩種說法，最能彰顯出差異的，就是一種不能未遂的情形。

01:12:33 - 01:12:36
蔡聖偉老師的那篇文章叫惡視力，也是探討這種案例。

01:12:37 - 01:12:41
我這邊講一個更極端的案例，加深同學的印象。

01:12:42 - 01:12:48
這個案例啊，是我剛上研究所的時候，當時參加一場研討會，那一場研討會是甘田貴老師在主持的。

01:12:49 - 01:12:51
當時甘老師舉了一個非常有趣的例子。

01:12:52 - 01:12:53
甘老師他這麼說啊。

01:12:53 - 01:13:02
他說啊，假設有個臺灣人，他在花蓮的海邊，七星潭那邊，持一把手槍，朝著東邊開槍。

01:13:04 - 01:13:11
這個臺灣人確信，他的這一把手槍，可以打死美國西岸的人。

01:13:12 - 01:13:14
那他什麼時候著手？

01:13:15 - 01:13:15
就這樣的案例。

01:13:16 - 01:13:19
對啊，臺灣人在花蓮的七星潭，拿了一把普通的小手槍，朝著東邊開槍。

01:13:21 - 01:13:27
這個臺灣人確信他的手槍的子彈可以橫越太平洋，打死美國西岸的人，那他什麼時候著手？

01:13:29 - 01:13:31
甘老師舉了一個這樣的例子。

01:13:33 - 01:13:35
同學可能會心想，這種人的責任歸屬是有問題。

01:13:35 - 01:13:37
啊，不管嘛，那個是罪責的問題，我們不管嘛。

01:13:38 - 01:13:40
我們這裡純看構成要件，他著手了沒有？

01:13:41 - 01:13:42
對啊，他著手了沒有？

01:13:42 - 01:13:46
各位，這一種案例，如果你照客觀著手理論。

01:13:47 - 01:13:48
根本找不出著手時點。

01:13:49 - 01:13:50
你知道為什麼嗎？

01:13:50 - 01:13:50
哎呀。

01:13:51 - 01:13:54
那個手槍的子彈又不像洲際飛彈這樣。

01:13:54 - 01:13:56
子彈頂多飛個幾百公尺就掉了嘛。

01:13:57 - 01:14:00
所以你在臺灣的海邊朝著美國的領

01:14:00 - 01:14:01
馬上去開槍,

01:14:01 - 01:14:03
不可能對任何人的生命有威脅的。

01:14:03 - 01:14:03
對不對？

01:14:04 - 01:14:09
所以這樣的案例，如果你採客觀著手理論的話，根本找不到著手時點。

01:14:10 - 01:14:13
可是如果你採取主客觀混合理論的話，

01:14:14 - 01:14:14
有沒有著手？

01:14:15 - 01:14:15
有啊。

01:14:16 - 01:14:16
為什麼？

01:14:16 - 01:14:22
因為主客觀理論它是怎麼樣，它是用行為人的犯罪計畫去判斷。

01:14:22 - 01:14:24
所以各位什麼叫做行為人的犯罪計畫？

01:14:24 - 01:14:30
意思就是，不管這個行為人的犯罪計畫再怎麼的荒謬，再怎麼的不可能實現，

01:14:30 - 01:14:33
那行為人會去做就代表他相信這個可以實現嘛。

01:14:33 - 01:14:33
對不對？

01:14:34 - 01:14:38
所以我們要假設行為人的犯罪計畫客觀上是可實現的，

01:14:38 - 01:14:44
然後我們去思考說，那他做到這個階段，會不會導致法益的迫切危險？

01:14:44 - 01:14:45
所以你想喔，

01:14:47 - 01:14:48
以花蓮開槍案來講，

01:14:48 - 01:14:50
我們會怎麼假設？

01:14:51 - 01:14:58
假設這個人使用的手槍，它真的有能力激發如同洲際飛彈般射程的子彈。

01:14:59 - 01:15:01
那行為人扣下板機有沒有著手？

01:15:01 - 01:15:01
有啊。

01:15:01 - 01:15:02
當然有啊。

01:15:02 - 01:15:03
瞭解我的意思吧？

01:15:03 - 01:15:09
所以他們的差別主要會彰顯在這一種不能未遂的案例當中。

01:15:09 - 01:15:11
不能未遂我們等一下馬上就會講到,

01:15:11 - 01:15:12
不能未遂是什麼意思？

01:15:12 - 01:15:15
就是指這一種客觀上根本無法實現的未遂。

01:15:15 - 01:15:16
這個叫不能未遂，

01:15:16 - 01:15:17
知道嗎？

01:15:17 - 01:15:21
你看到一個已經腐爛長蛆的屍體，你以為他是人，你要去砍殺他，

01:15:21 - 01:15:22
那個就叫不能未遂，

01:15:22 - 01:15:22
知道吧？

01:15:23 - 01:15:24
這個以後我們會講。

01:15:25 - 01:15:28
好，所以這個是關於著手的認定。

01:15:28 - 01:15:29
來，

01:15:29 - 01:15:33
各種理論我們大概都看過了，接著我們來看下面的綜合比較。

01:15:34 - 01:15:36
各種案例的著手認定。

01:15:36 - 01:15:39
好，首先，括號一。

01:15:40 - 01:15:46
因為著手這個東西，說真的，對第一次學習的同學來講，不好學。

01:15:47 - 01:15:50
我跟你們說啊，以前我大一在學行銷的時候，

01:15:51 - 01:15:54
我覺得有三大問題困擾著我。

01:15:55 - 01:15:57
我當初的問題也可能是很多同學的問題。

01:15:57 - 01:16:00
我覺得當初我學完一遍行總,有三

01:16:00 - 01:16:01
大問題困擾著我。

01:16:01 - 01:16:04
第一個是我覺得客觀歸責好難。

01:16:04 - 01:16:06
第一個,對,我覺得客觀歸責好難。

01:16:06 - 01:16:08
什麼叫規範保護目的,什麼叫風險實現,

01:16:09 - 01:16:10
大一讀不懂，正常。

01:16:11 - 01:16:12
第一個我覺得客觀歸責好難。

01:16:13 - 01:16:16
第二個，我覺得容許構成要件錯誤好難。

01:16:17 - 01:16:18
我相信同學也覺得很難，正常。

01:16:19 - 01:16:21
第三個，我覺得著手理論好抽象。

01:16:22 - 01:16:26
真的啊，大一困擾我的三大問題，我還記得，事隔那麼久。

01:16:27 - 01:16:28
第一個我覺得客觀歸責好難。

01:16:28 - 01:16:30
第二個我覺得容許構成要件錯誤好難。

01:16:31 - 01:16:32
第三個我覺得著手理論好抽象。

01:16:33 - 01:16:36
因為我大一的想法是什麼叫做法律的迫切危險？

01:16:36 - 01:16:38
你可不可以給我一個具體的時點？

01:16:38 - 01:16:39
對啊，超難的啊。

01:16:39 - 01:16:46
所以我們接下來就要來看，我這邊就試著幫同學分析在各種不同的案情當中，

01:16:46 - 01:16:50
什麼樣的時點是法益有迫切危險的時點。

01:16:51 - 01:16:52
好，首先第一件事，

01:16:53 - 01:16:54
各位啊,

01:16:55 - 01:16:59
雖然我們現在的通說都已經放棄了形式客觀說,

01:17:00 - 01:17:06
可是其實你知道嗎，形式客觀說，它的基準沒有真的被大家放棄。

01:17:06 - 01:17:13
因為其實我們現在會肯認一件事，當行為人已經開始做構成要件行為的時候，我們會不會傾向認為他著手？

01:17:14 - 01:17:15
廢話，當然會啊。

01:17:15 - 01:17:16
瞭解吧？

01:17:16 - 01:17:18
所以我們現在第一個會講，

01:17:18 - 01:17:26
當行為人已經開始做構成要件行為的時候，原則上他就會有著手喔。

01:17:26 - 01:17:27
知道嗎？

01:17:27 - 01:17:30
只是我們會不會說，所以沒有做構成要件行為就沒有著手？

01:17:31 - 01:17:32
我不會這樣反推，知道吧？

01:17:32 - 01:17:37
因為形式客觀說它原本的意思就是說，你有做構成要件行為，它就是著手，啊沒有的話就沒有著手。

01:17:37 - 01:17:38
懂這意思吧？

01:17:38 - 01:17:40
現在的話是說，

01:17:40 - 01:17:44
有做構成要件行為，原則上他就是有著手。

01:17:46 - 01:17:48
有沒有著手，不一定，我們還要看其他的標準，知道嗎？

01:17:49 - 01:17:50
現在的標準大概是這樣子。

01:17:51 - 01:17:55
好，所以我們說第一個，有做構成要件行為，原則上就已經著手了，沒錯。

01:17:55 - 01:17:57
那我們講有原則就有例外嘛。

01:17:57 - 01:17:58
來我們來看到242頁。

01:18:00 - 01:18:03
有另外一種情況叫做隔離犯

01:18:03 - 01:18:04
隔離犯。

01:18:05 - 01:18:06
這個東西啊，我先說，

01:18:06 - 01:18:07
這篇是司律的考點

01:18:08 - 01:18:09
這個偏司律。

01:18:09 - 01:18:12
所以如果是考一般三等的同學，

01:18:12 - 01:18:14
隔離犯這一塊，

01:18:14 - 01:18:15
你自己斟酌。

01:18:15 - 01:18:17
我等一下會講一個簡單的說法，

01:18:17 - 01:18:19
考司律的話，我覺得你還是要會。

01:18:20 - 01:18:22
因為這個是許恆達老師今年的文章。

01:18:23 - 01:18:25
好，什麼叫隔離犯？

01:18:26 - 01:18:28
行為人做完犯罪行為，

01:18:29 - 01:18:31
到最後犯罪的實現，

01:18:32 - 01:18:35
中間需要間隔一定的時間。

01:18:35 - 01:18:36
一定的空間,

01:18:37 - 01:18:38
或者需要被害人配合的,

01:18:39 - 01:18:40
這一種叫做隔離犯。

01:18:41 - 01:18:43
好，比如說最簡單的例子，

01:18:43 - 01:18:44
裝定時炸彈。

01:18:45 - 01:18:47
定時炸彈裝下去,

01:18:47 - 01:18:48
到它倒數完引爆,

01:18:49 - 01:18:50
中間可能要好幾分鐘,

01:18:50 - 01:18:52
好幾十分鐘或好幾個小時,

01:18:52 - 01:18:53
都有可能

01:18:53 - 01:18:54
裝定時炸彈，

01:18:54 - 01:18:54
這是個例子。

01:18:55 - 01:18:55
還有像什麼呢？

01:18:56 - 01:18:58
在別人的飲食當中下毒，

01:18:58 - 01:18:59
這也是。

01:18:59 - 01:19:01
因為你下完毒要人來吃人來喝,

01:19:01 - 01:19:03
喝完之後要中毒,

01:19:03 - 01:19:04
可能又需要一些時間,

01:19:04 - 01:19:06
這種叫做隔離飯。

01:19:07 - 01:19:08
好,

01:19:08 - 01:19:09
我們講，

01:19:09 - 01:19:11
剛剛我們講判斷著手的原則是什麼？

01:19:12 - 01:19:13
做完構成要件行為，

01:19:14 - 01:19:15
原則上就著手，

01:19:15 - 01:19:15
對不對？

01:19:16 - 01:19:19
那所以這個標準到隔離犯也一樣適用嗎?

01:19:19 - 01:19:20
嗯？會有問題喔。

01:19:20 - 01:19:21
為什麼？

01:19:22 - 01:19:23
那我講極端一點。

01:19:23 - 01:19:24
第一個比較沒有疑問。

01:19:24 - 01:19:25
裝定時炸彈。

01:19:25 - 01:19:27
我在臺北車站裝了一個定時炸彈，

01:19:28 - 01:19:29
放在廣場，

01:19:29 - 01:19:32
這一顆炸彈是30分鐘之後引爆，

01:19:32 - 01:19:33
裝完我就走掉了。

01:19:34 - 01:19:36
原則上你說我著手OK,

01:19:36 - 01:19:36
還說得過去，

01:19:36 - 01:19:37
對不對？

01:19:37 - 01:19:40
但如果裝這個炸彈，我的設定是三天後引爆呢？

01:19:41 - 01:19:42
你一樣說我裝完就著手嗎？

01:19:43 - 01:19:45
有沒有感覺好像離法益侵害還有點遠？

01:19:45 - 01:19:45
對不對？

01:19:46 - 01:19:48
所以後來的學者就會意識到說，

01:19:48 - 01:19:49
隔離犯，

01:19:49 - 01:19:51
著手與否你不能說一做完就著手了。

01:19:52 - 01:19:54
那萬一真的隔很久怎麼辦？

01:19:55 - 01:19:56
像之前國考考題有出過啊，

01:19:57 - 01:19:59
那題我可能拿掉了，因為時間很久了。

01:20:00 - 01:20:01
媒體說，

01:20:01 - 01:20:03
中華賽鴿協會舉辦飛鴿競賽，

01:20:04 - 01:20:06
鴿子從臺北飛往臺東。

01:20:07 - 01:20:07
臺中在

01:20:08 - 01:20:12
然後那個鴿子呢,在臺中的山區高地要架網捕捉賽鴿。

01:20:13 - 01:20:13
比賽開始

01:20:14 - 01:20:15
鴿子的網子架好了

01:20:16 - 01:20:17
問說甲著手沒？

01:20:18 - 01:20:19
一樣類似的問題。

01:20:20 - 01:20:21
當然啦，這一題事實不合理。

01:20:22 - 01:20:23
我以前跟各位說過，

01:20:23 - 01:20:26
鴿子從臺北飛到臺東，怎麼會經過臺中的山區高地？

01:20:26 - 01:20:29
會的話鴿子要橫越中央山脈，這根本就不合理。

01:20:29 - 01:20:31
但我們就假設鴿子能翻山越嶺。

01:20:31 - 01:20:32
你想嘛,

01:20:32 - 01:20:36
鴿子從臺北飛到臺東，途經臺中。

01:20:37 - 01:20:39
鴿子從臺北飛到臺中，你覺得要飛多久？

01:20:41 - 01:20:43
高鐵臺北臺中的直達車是50分鐘,

01:20:44 - 01:20:45
臺鐵是兩個小時。

01:20:46 - 01:20:48
鴿子不可能比這兩者快,

01:20:49 - 01:20:50
起碼可能要飛個三小時,

01:20:50 - 01:20:51
對吧?

01:20:51 - 01:20:53
所以比賽一開始你就說他著手了嗎?

01:20:53 - 01:20:54
是不是怪怪的?

01:20:54 - 01:20:54
對不對?

01:20:55 - 01:20:57
所以我們這裡就會說,隔離犯怎麼著手呢?

01:20:58 - 01:20:58
下面來,

01:20:59 - 01:21:00
學者說,

01:21:01 - 01:21:06
隔離犯的著手類似間接正犯的著手,有下面的不同說法,

01:21:06 - 01:21:09
個別理論跟整體理論。

01:21:09 - 01:21:10
來你旁邊寫一下,

01:21:10 - 01:21:15
個別理論跟整體理論,它其實就是間接正犯的著手理論。

01:21:15 - 01:21:16
你寫一下,

01:21:16 - 01:21:20
這兩說其實就是間接正犯的著手理論。

01:21:20 - 01:21:27
因為許恆達老師前幾個月有另外一篇文章在談錯誤支配，其中有涉及到間接正犯的著手,

01:21:27 - 01:21:29
他也是用這幾個理論。

01:21:30 - 01:21:32
所以這幾個理論在許老師的文章已經第二次出現了喔。

01:21:34 - 01:21:35
它其實就是間接正犯的著手。

01:21:36 - 01:21:38
以後我們會再講什麼叫間接正犯的著手，

01:21:38 - 01:21:40
我們這裡先來看隔離犯的部分。

01:21:41 - 01:21:44
因為其實隔離犯跟間接正犯很像啦，所以我們來看一下，

01:21:45 - 01:21:46
這幾種理論怎麼說。

01:21:48 - 01:21:48
好,

01:21:49 - 01:21:52
第一個說法叫做嚴格的個別理論。

01:21:53 - 01:21:54
這一說講呢,

01:21:55 - 01:21:57
只要行為人出於整體計畫,

01:21:58 - 01:21:59
出於這個

01:22:00 - 01:22:06
整體竊盜犯罪，依照個別行為來看，足以認定已經啟動犯罪行為的執行，就可以認為著手。

01:22:10 - 01:22:17
所以這一說會講，開始下毒，開始做行為，就認為是行為人的著手，這個叫做嚴格的個別理論。

01:22:19 - 01:22:22
所以你會發現，嚴格的個別理論的主張是什麼？

01:22:23 - 01:22:25
就像我說的，你做完就著手。

01:22:26 - 01:22:27
知道嗎？食物是請這個說法喔。

01:22:28 - 01:22:29
你做完就著手喔。

01:22:29 - 01:22:33
至於做完之後，損害要多久才實現，他不管。

01:22:34 - 01:22:35
你做完就著手，知道嗎？

01:22:35 - 01:22:38
這個是嚴格的個別理論。

01:22:38 - 01:22:44
所以考一般的非思律的同學，你主要要記得的就是這一套，知道嗎？

01:22:44 - 01:22:46
隔離犯跟一般犯罪有什麼不同，你做完就著手。

01:22:47 - 01:22:50
這是一般的說法，做完就著手，嚴格的個別理論。

01:22:51 - 01:22:54
再來第二說叫做修正的個別理論。

01:22:56 - 01:22:57
這一說認為，圈圈二。

01:22:59 - 01:23:04
行為人必須完成主觀計畫所預期的所有行為。

01:23:05 - 01:23:14
並且在持續的流程當中，失去對損害流程控制的支配還有控制。

01:23:15 - 01:23:20
引起損害的因素啊，必須要脫離行為人支配的領域，才能認為著手。

01:23:21 - 01:23:23
這一說，白話的意思就是說啦。

01:23:24 - 01:23:26
光是做完行為還不夠。

01:23:27 - 01:23:28
還要等到什麼時候？

01:23:29 - 01:23:32
那個損害已經失控的狀態。

01:23:32 - 01:23:35
行為人想要挽回，恐怕也來不及了。

01:23:36 - 01:23:37
要等那個狀態才算是著手。

01:23:38 - 01:23:41
所以我這邊再舉個例子，讓同學思考一下，好。

01:23:43 - 01:23:44
我的案例是這樣，一樣。

01:23:45 - 01:23:48
我在臺北車站，我這樣說，講精確一點。

01:23:52 - 01:23:55
我在一個行李箱裡面，裝了一個定時炸彈。

01:23:56 - 01:23:59
這一顆炸彈的設定是30分鐘後引爆。

01:24:00 - 01:24:00
之後會引爆。

01:24:02 - 01:24:07
那我把這個手提行李呢，放在車站旁邊柱子的一個角落，然後我就假裝離開去上廁所了。

01:24:10 - 01:24:13
實際上，我跑去二樓的伯朗咖啡。

01:24:13 - 01:24:17
我想要親眼看這個行李被引爆。

01:24:18 - 01:24:19
各位，這樣的案例，我什麼時候做過？

01:24:21 - 01:24:26
如果照嚴格的個別理論，是不是我一裝完就做掉，對不對？

01:24:27 - 01:24:29
那照修正的個別理論呢？

01:24:29 - 01:24:31
我裝完會不會中邪？

01:24:31 - 01:24:31
為什麼？

01:24:32 - 01:24:36
因為我裝完之後，我去二樓的伯朗咖啡看。

01:24:37 - 01:24:38
那我現在回頭是不是還來得及？

01:24:38 - 01:24:41
二樓到一樓很快啊，頂多兩分鐘就到了啊。

01:24:41 - 01:24:44
所以照這一說，要到什麼時候才著手？

01:24:45 - 01:24:47
我想回頭也來不及的時候。

01:24:48 - 01:24:50
比如說引爆前的兩三分鐘。

01:24:51 - 01:24:57
兩三分鐘我要下去，我還要把行李推出去，可能來不及嘛，對不對，所以要到這個時候才左手，知道嗎？

01:24:57 - 01:24:58
要到這個時候才著手。

01:24:59 - 01:25:00
好，那我後

01:25:00 - 01:25:00
換一個版本哦。

01:25:01 - 01:25:06
那如果是我裝完這個炸彈之後，我就到樓下搭高鐵要離開了。

01:25:08 - 01:25:14
而且我裝完之後我搭的高鐵，是百位數三四頭，不停板橋下一站桃園的高鐵。

01:25:15 - 01:25:16
誒，你們知道有這種班次嗎？

01:25:18 - 01:25:19
高鐵的停站要看百位數。

01:25:20 - 01:25:22
真的啦，高鐵停站要看百位數。

01:25:22 - 01:25:25
百位數，因為高鐵一般都是三位數的車次哦。

01:25:26 - 01:25:28
你看那個高鐵的車次有四位數的。

01:25:29 - 01:25:30
那個通常是

01:25:30 - 01:25:31
加班車。

01:25:31 - 01:25:33
四位數一的就是特定日才有。

01:25:33 - 01:25:35
四位數八的那個是特殊加班車。

01:25:36 - 01:25:38
我搭到十個秒會背的啦，真的。

01:25:39 - 01:25:40
那看百位數啦。

01:25:40 - 01:25:43
百位數一是直達車啦，中間只有停臺中。

01:25:43 - 01:25:45
二的話是加停一個臺南。

01:25:45 - 01:25:47
然後八的話，我最討厭搭八。

01:25:47 - 01:25:49
因為八的話是每一站都停，那個叫慢鐵。

01:25:49 - 01:25:51
那個不叫高鐵，我超討厭搭八。

01:25:53 - 01:25:54
然後

01:25:54 - 01:25:55
好了，我要講。

01:25:55 - 01:25:57
三是一種很特殊的停站。

01:25:58 - 01:26:00
三是南港發車。

01:26:00 - 01:26:01
就停臺北。

01:26:01 - 01:26:03
臺北發車之後他下一站不會停板橋。

01:26:03 - 01:26:05
下一站桃園。

01:26:05 - 01:26:10
然後桃園之後是哪一站？

01:26:10 - 01:26:11
臺中。

01:26:11 - 01:26:11
好像吧。

01:26:11 - 01:26:13
然後南部好像都會停。

01:26:13 - 01:26:14
三好像是這樣子,對好像是。

01:26:15 - 01:26:18
因為我搭高鐵我都是從板橋,我不能搭三的啦,所以

01:26:19 - 01:26:21
我反正我記得他不會停板橋,因為我以前被載過。

01:26:22 - 01:26:23
我跟你們講,我以前被載過,真的啊。

01:26:24 - 01:26:28
我那時候剛搬去板橋,隔天我臺北這邊下課。

01:26:28 - 01:26:33
我就想說從臺北回板橋的家,當然要搭高鐵啊,六分鐘就到了,我才不要搭捷運。

01:26:34 - 01:26:36
我看到一般自由座的高鐵,我就興沖沖跳上去。

01:26:36 - 01:26:39
結果跳上去之後呢,嗯,說板橋沒有停,開過去,我嚇死。

01:26:40 - 01:26:43
跑去問,蛤,沒有停板橋,下一站桃園。

01:26:43 - 01:26:45
對,所以我就被載到桃園。

01:26:45 - 01:26:47
被載到桃園之後,我再去對面。

01:26:48 - 01:26:50
然後等了十幾分鐘,再搭回板橋。

01:26:50 - 01:26:53
超浪費時間,根本沒有省到時間,我被駭過,我印象超深刻。

01:26:53 - 01:26:55
三次都沒停板橋。

01:26:55 - 01:26:57
真的啊，自強號沒有停板橋，好。

01:26:57 - 01:26:57
那我講啦。

01:26:58 - 01:27:03
我裝完炸彈之後，我就跳上一班自強號的高鐵，離開了。

01:27:05 - 01:27:06
為什麼要特別強調自強號？

01:27:07 - 01:27:10
因為你想，我跳上自強號的高鐵，他下一站是桃園。

01:27:11 - 01:27:12
臺北到桃園。

01:27:13 - 01:27:15
那我到桃園之後，我還要再回來。

01:27:15 - 01:27:16
是不是還要再等車？

01:27:17 - 01:27:19
那一來一回至少40分鐘以上。

01:27:19 - 01:27:20
所以代表什麼意思？

01:27:20 - 01:27:23
我跳上高鐵的瞬間，我要回頭就來不及了。

01:27:24 - 01:27:27
所以在我裝完炸彈之後就馬上跳上高鐵的情形。

01:27:28 - 01:27:29
我跳上高鐵是用我的著手按的。

01:27:30 - 01:27:31
所以我要回頭也來不及了。

01:27:31 - 01:27:32
懂我的意思吧，大概是這個意思。

01:27:33 - 01:27:33
好。

01:27:34 - 01:27:35
接下來

01:27:35 - 01:27:37
另外一種說法叫整體理論。

01:27:37 - 01:27:39
來，個別跟整體是什麼意思？

01:27:39 - 01:27:39
因為你看哦。

01:27:40 - 01:27:43
個別理論，他只看個別行為人做到什麼階段。

01:27:44 - 01:27:47
他沒有考量到整體的法益侵害有沒有逼近。

01:27:47 - 01:27:48
這是個別理論啊。

01:27:49 - 01:27:51
相對的整體理論看什麼呢？

01:27:51 - 01:27:52
你看喔。

01:27:52 - 01:27:54
整體理論認為說啊,

01:27:54 - 01:27:57
我們不能只看行為人本身,

01:27:57 - 01:28:00
而是呢，。

01:28:00 - 01:28:00
他說啊，本說立主要考量被害人的相應行動

01:28:00 - 01:28:01
的後期階段流程有沒有進入這個損害結果的攻擊範圍才能認為是著手。

01:28:14 - 01:28:16
所以整體的意思就是說你不能只看行為人這邊

01:28:17 - 01:28:19
你要看被害人這邊一起看

01:28:19 - 01:28:23
要被害人的部分,他也已經產生了法益的迫切危險

01:28:24 - 01:28:27
這裡才可以認為已經著手。

01:28:29 - 01:28:30
這個更嚴格

01:28:30 - 01:28:33
所以延續我剛剛講搭高鐵這個例子

01:28:33 - 01:28:35
30分鐘後要爆炸的炸彈

01:28:35 - 01:28:39
我裝完之後馬上跳上時速三百的高鐵離開臺北

01:28:40 - 01:28:43
這個例子,如果照前兩說,我當然都著手了,對不對

01:28:44 - 01:28:47
照第三說整體理論，我還沒有

01:28:47 - 01:28:47
為什麼

01:28:48 - 01:28:51
那如果有人發現他是炸彈的話，把它推開不就沒事了

01:28:51 - 01:28:51
對吧

01:28:52 - 01:28:54
所以要等到什麼時候，快要爆炸的時候才著手喔

01:28:55 - 01:28:56
這個說法更嚴格，知道吧？

01:28:57 - 01:28:59
許恆達老師採的就是

01:28:59 - 01:29:01
這一個整體理論，叫做嚴格的整體理論。

01:29:03 - 01:29:05
許恆達老師才說，其實整體理論也有寬鬆版。

01:29:06 - 01:29:08
但這個國內沒有人採，所以我這邊沒有特別的去引用。

01:29:09 - 01:29:11
所以這三說的排序,你看吧

01:29:12 - 01:29:14
第一說嚴格個別理論,所以寬鬆

01:29:16 - 01:29:18
第二說修正個別理論,中間

01:29:19 - 01:29:21
第三說最嚴,整體理論,最嚴格

01:29:23 - 01:29:24
許恆達老師傾向的是整體理論

01:29:25 - 01:29:28
但反觀我們的實務呢,食物比較傾向寬鬆的說法

01:29:29 - 01:29:31
這個嚴格的個別理論

01:29:31 - 01:29:32
實務比較傾向這一說

01:29:34 - 01:29:35
好,所以這個是我們講

01:29:35 - 01:29:38
已經從事構成要件行為的情況

01:29:39 - 01:29:40
再來第三點顛倒過來

01:29:40 - 01:29:43
那如果還沒有進行構成要件行為有沒有著手呢

01:29:44 - 01:29:46
這裡的話,當然不一定

01:29:46 - 01:29:47
我們來看下面這個例子

01:29:49 - 01:29:53
甲要行竊於宅,才剛進入客廳,就被屋主制服

01:29:54 - 01:29:55
我們看這個案例

01:29:55 - 01:29:56
想要偷東西啊

01:29:57 - 01:30:00
剛進入客廳，就被屋主制服

01:30:00 - 01:30:01
的，各位

01:30:02 - 01:30:04
這個案例甲著手的沒有？

01:30:05 - 01:30:05
你看喔,

01:30:07 - 01:30:12
採實質客觀說跟才主客觀混合說,

01:30:13 - 01:30:15
判斷的結果會不太一樣。

01:30:16 - 01:30:19
這個案例才主客觀混合說,

01:30:20 - 01:30:21
一定會認為有著手。

01:30:22 - 01:30:24
當你知道這個人是小偷了，

01:30:25 - 01:30:27
小偷已經進到被害人家客廳了，

01:30:27 - 01:30:29
你會不會覺得被害人的財產有危險？

01:30:30 - 01:30:30
會嘛，

01:30:31 - 01:30:31
一定會。

01:30:31 - 01:30:32
對不對？

01:30:32 - 01:30:34
所以才主客觀混合說的話，

01:30:34 - 01:30:35
這件一定有著手。

01:30:36 - 01:30:38
那如果你採實質客觀說呢？

01:30:38 - 01:30:39
我剛剛強調，

01:30:39 - 01:30:41
實質客觀說他怎麼判斷？

01:30:42 - 01:30:46
他看的是行為人的行為階段。

01:30:48 - 01:30:50
他看的是純從客觀來講喔，

01:30:50 - 01:30:51
純從客觀來說，

01:30:51 - 01:30:54
這個行為會不會對法益造成迫切的危險？

01:30:55 - 01:30:55
所以啊,

01:30:56 - 01:30:56
各位你要想喔,

01:30:57 - 01:30:58
照實質客觀說的話,

01:30:59 - 01:31:00
你知不知道那個人是小偷？

01:31:01 - 01:31:02
你不知道啊。

01:31:02 - 01:31:03
那你不知道的話,

01:31:04 - 01:31:05
光是有人進到他們家客廳,

01:31:06 - 01:31:07
你哪知道他要幹嘛？

01:31:08 - 01:31:09
進而你會覺得他財產有危險嗎？

01:31:10 - 01:31:10
就不見得了。

01:31:10 - 01:31:11
對不對？

01:31:11 - 01:31:12
所以你會發現，

01:31:12 - 01:31:13
實質客觀來說，

01:31:14 - 01:31:16
他好像對行為人比較有利。

01:31:17 - 01:31:17
對。

01:31:17 - 01:31:17
沒錯,

01:31:17 - 01:31:19
大部分案例確實是這樣子。

01:31:19 - 01:31:21
可是其實不盡然喔,

01:31:21 - 01:31:22
你來看第四點,

01:31:22 - 01:31:23
顛倒過來的情形。

01:31:25 - 01:31:26
你看這個案例,

01:31:26 - 01:31:27
甲要殺A,

01:31:27 - 01:31:29
計畫用安眠藥迷昏A,

01:31:29 - 01:31:31
再持刀刺死A。

01:31:31 - 01:31:33
結果甲要拿安眠藥的時候啊,

01:31:33 - 01:31:33
誤拿毒藥，

01:31:34 - 01:31:35
造成A中毒，

01:31:35 - 01:31:36
所幸A沒有死掉。

01:31:38 - 01:31:38
我說啊，

01:31:39 - 01:31:40
傳統上都會講，

01:31:40 - 01:31:43
實質客觀說對行為人相對有利,

01:31:44 - 01:31:46
而主客觀混合說對行為人相對不利。

01:31:46 - 01:31:47
傳統上都這麼說,

01:31:48 - 01:31:49
但我絕對找得到例外，

01:31:49 - 01:31:49
就是這個例子。

01:31:50 - 01:31:52
這個例子剛好顛倒，

01:31:52 - 01:31:52
有沒有發現？

01:31:53 - 01:31:56
因為這個例子如果你照實質客觀說的話，

01:31:56 - 01:31:57
反而會怎麼樣？

01:31:57 - 01:31:58
他就拿毒藥啦。

01:31:58 - 01:31:59
當然著手啦,

01:31:59 - 01:31:59
對不對?

01:32:00 - 01:32:01
可是反過來,

01:32:01 - 01:32:04
如果你照主客觀混合說呢?

01:32:05 - 01:32:06
行為人的想像是,

01:32:06 - 01:32:08
在用安眠藥迷惑被害人。

01:32:09 - 01:32:10
所以你想行為人會怎麼覺得？

01:32:11 - 01:32:12
安眠藥摻下去，

01:32:12 - 01:32:13
人要先昏，

01:32:13 - 01:32:15
起碼要個二三十分鐘。

01:32:15 - 01:32:16
昏了之後，

01:32:16 - 01:32:18
還要再拿刀去捅被害人。

01:32:18 - 01:32:20
這是不是需要一段時間？

01:32:20 - 01:32:20
對啊，

01:32:20 - 01:32:23
所以這個例子如果照主客觀混合說，

01:32:23 - 01:32:25
根本就還沒有著手啊。

01:32:26 - 01:32:27
其實這個例子同學你會覺得有點熟。

01:32:28 - 01:32:29
因為這個例子，

01:32:29 - 01:32:31
我改編自之前的一個國考考題。

01:32:32 - 01:32:34
在我們前面講結果提前發生的時候，

01:32:34 - 01:32:36
就出現過幾乎一樣的。

01:32:37 - 01:32:38
我們往回翻。

01:32:53 - 01:32:54
來121頁。

01:32:56 - 01:32:58
121頁的案例二。

01:33:33 - 01:33:33
對啊。

01:33:33 - 01:33:35
你看121頁那個案例二。

01:33:36 - 01:33:36
這個案例二，

01:33:36 - 01:33:39
跟我們剛剛那個案例是不是幾乎一樣，

01:33:39 - 01:33:40
只是差別在人死沒嘛。

01:33:41 - 01:33:41
假設你看喔，

01:33:41 - 01:33:43
在案例二這邊，人

01:33:43 - 01:33:45
在前階段就死掉了。

01:33:46 - 01:33:47
我們複習一下。

01:33:48 - 01:33:50
在結果提前發生之下，

01:33:51 - 01:33:52
我們會判斷什麼？

01:33:53 - 01:33:53
行為人，

01:33:53 - 01:33:56
有沒有跨到著手階段？

01:33:57 - 01:33:58
因為這個會影響到什麼呢？

01:33:58 - 01:34:00
他腦中那個想像，

01:34:00 - 01:34:01
殺人的想法。

01:34:01 - 01:34:02
會不會是故意？

01:34:02 - 01:34:02
對吧？

01:34:03 - 01:34:04
所以這件當中，

01:34:04 - 01:34:06
行為人有沒有跨到著手階段？

01:34:07 - 01:34:09
如果你採實質客觀說的話，

01:34:10 - 01:34:10
有喔。

01:34:11 - 01:34:11
對不對？

01:34:11 - 01:34:11
有喔。

01:34:12 - 01:34:13
所以這件有機會論過失犯喔。

01:34:14 - 01:34:17
可是如果你採主客觀混合[redacted]　呢？

01:34:18 - 01:34:19
他著手了嗎?

01:34:19 - 01:34:20
還沒耶。

01:34:20 - 01:34:22
所以這件是不是只能論過失致死?

01:34:22 - 01:34:22
對啊，

01:34:22 - 01:34:24
所以當時我為什麼沒講這個案例？

01:34:25 - 01:34:26
因為太難了啦。

01:34:26 - 01:34:29
這個案例表面上在考結果提前發生，

01:34:29 - 01:34:31
其實它涉及到著手的問題，

01:34:31 - 01:34:32
知道嗎？

01:34:32 - 01:34:33
這是一個比較難的案例喔。

01:34:35 - 01:34:35
好,

01:34:36 - 01:34:36
接著來,

01:34:37 - 01:34:37
我們回來。

01:34:38 - 01:34:39
243頁。

01:34:42 - 01:34:43
我們接下來啊,

01:34:43 - 01:34:43
來看到光華二。

01:34:44 - 01:34:49
那如果行為人只開始做加重構成要件呢？

01:34:50 - 01:34:52
加重構成要件它是一種立法模式。

01:34:52 - 01:34:54
像321條的加重竊盜罪，

01:34:55 - 01:34:57
222條的加重強制性交罪,

01:34:58 - 01:35:21
339之4的

01:35:21 - 01:35:40
加重詐欺罪

01:35:41 - 01:35:44
這種東西都叫做加重構成要件。

01:35:44 - 01:35:44
好,

01:35:45 - 01:35:46
我們在問的是說啊,

01:35:46 - 01:35:50
行為人如果開始做加重構成要件,

01:35:50 - 01:35:52
可不可以認為著手?

01:35:53 - 01:35:53
答案是不可以。

01:35:54 - 01:35:55
記得喔,

01:35:55 - 01:35:56
通說實務都認為不可以。

01:35:56 - 01:35:57
也就是啊,

01:35:57 - 01:35:59
在加重構成要件當中,

01:36:00 - 01:36:00
那個如果陸伯言他想對我性侵害

01:36:00 - 01:36:01
所以陸伯彥今天半夜呢從我家的頂樓平臺用繩索垂降到我的主臥室的陽臺

01:36:09 - 01:36:10
他要進來對我性侵害

01:36:10 - 01:36:14
結果他在陽臺的時候啊不得其門而入

01:36:14 - 01:36:15
因為我落地窗的門是鎖起來的

01:36:15 - 01:36:18
陸伯言就被卡在那個陽臺上面呼救

01:36:18 - 01:36:20
所以他著手於222的沒有

01:36:22 - 01:36:22
沒有喔

01:36:23 - 01:36:25
這種加重構成要件的著手

01:36:25 - 01:36:30
我們怎麼樣一律回歸基本構成要件去認定

01:36:30 - 01:36:32
知道嗎我們一律回歸基本構成要件

01:36:33 - 01:36:33
好

01:36:33 - 01:36:35
那我接著再舉一個例子我們以竊盜為例

01:36:36 - 01:36:39
請問一個人剛進到被害人的住宅

01:36:39 - 01:36:40
要偷東西

01:36:40 - 01:36:46
才在物色財物，還沒有真的開始拿喔，才在物色財物就被抓了

01:36:47 - 01:36:51
這個例子通說會覺得行為人有著手

01:36:52 - 01:36:52
有人會說好

01:36:52 - 01:36:53
為什麼

01:36:53 - 01:36:55
你不是說加重構成要件不得認定著手嗎

01:36:56 - 01:36:59
那行為人才剛開始進入被害人的住宅

01:36:59 - 01:36:59
那他

01:37:00 - 01:37:01
也沒有竊取行為啊

01:37:02 - 01:37:03
他不是

01:37:03 - 01:37:06
只做了321條的侵入住宅的試有而已嗎

01:37:07 - 01:37:09
為什麼這個例子通說卻說著手了呢

01:37:09 - 01:37:13
所以我跟各位說這個例子的著手跟321根本一點關係也沒有

01:37:14 - 01:37:16
而是你要想就算沒有321

01:37:17 - 01:37:22
一個基於竊盜意圖的人進入被害者的住宅，而且已經開始搜尋財物

01:37:22 - 01:37:23
就算沒有321

01:37:24 - 01:37:27
他對被害人財務有沒有迫切的危險性

01:37:27 - 01:37:28
當然有啊對不對所以就著手了

01:37:29 - 01:37:30
是這樣判斷的

01:37:30 - 01:37:32
知道吧不是用321本身判斷的

01:37:32 - 01:37:32
好

01:37:33 - 01:37:34
那我們再回來221

01:37:35 - 01:37:35
222

01:37:36 - 01:37:37
條第一項啊他有一款適用

01:37:39 - 01:37:41
第一項的第四款，第四款是那個以藥劑犯姦

01:37:45 - 01:37:45
很奇怪喔

01:37:47 - 01:37:49
通說跟實務都說行為人開始

01:37:49 - 01:37:52
對被害人下藥就著手了

01:37:54 - 01:37:55
通說都是這樣講的

01:37:55 - 01:37:59
當行為人開始對被害人下藥就已經著手了

01:38:00 - 01:38:01
好

01:38:01 - 01:38:02
所以什麼意思啊

01:38:03 - 01:38:07
他要對我性侵,所以他拿了一杯摻了安眠藥的飲料給我喝

01:38:07 - 01:38:10
給我，我一開始喝，他就未遂了

01:38:10 - 01:38:11
你說好為什麼

01:38:12 - 01:38:13
這一款有什麼特殊的魔力嗎

01:38:14 - 01:38:15
沒有啦，我跟你說沒有

01:38:15 - 01:38:16
理由是什麼很簡單

01:38:17 - 01:38:19
因為使用藥劑本身就是221的強暴

01:38:20 - 01:38:21
就這樣而已，知道嗎？

01:38:22 - 01:38:25
你用藥劑給人家喝，那個本質上就是一種強暴。

01:38:25 - 01:38:27
所以就跟222一樣沒有關係。

01:38:28 - 01:38:30
就算222整條都廢掉。

01:38:31 - 01:38:32
就算沒有222。

01:38:32 - 01:38:37
你要性侵人家開始對人家下藥的時候,著手有沒有,著手有沒有,因為那個就叫強暴,知道吧

01:38:38 - 01:38:39
所以我們總歸一句

01:38:39 - 01:38:41
加重構成要件

01:38:41 - 01:38:43
我們會不會用那個東西判斷著手

01:38:43 - 01:38:43
不會

01:38:44 - 01:38:51
就算有些案例很巧的，剛好行為人開始做加重構成要件，我們就雙方著手

01:38:51 - 01:38:54
那其實也是基本構成要件使然

01:38:54 - 01:38:56
那跟加重構成要件一點關係都沒有

01:38:57 - 01:38:58
瞭解嗎，完全沒有關係喔

01:39:00 - 01:39:03
好，所以這個是加重構成要件的情形

01:39:03 - 01:39:04
接著我們翻過來

01:39:06 - 01:39:07
244頁

01:39:10 - 01:39:11
接著

01:39:11 - 01:39:12
第三個是未遂

01:39:12 - 01:39:13
好

01:39:13 - 01:39:13
未遂

01:39:13 - 01:39:19
我們說啊，未遂犯罪就是說行為人客觀上沒有充分地實現構成要件

01:39:19 - 01:39:20
這個叫做未遂

01:39:21 - 01:39:23
那到底是哪一個要件沒有被實現

01:39:24 - 01:39:25
都可以喔

01:39:25 - 01:39:27
我重要喔,我們第一堂課講過了喔

01:39:28 - 01:39:33
客觀構成要件要素六格嘛,主體,客體,行為,結果,因果關係,還有情狀,六格對不對

01:39:33 - 01:39:34
這六格

01:39:34 - 01:39:37
不管是哪一個沒有實現都是未遂喔

01:39:37 - 01:39:44
所以這邊再次提醒各位,你不要覺得結果沒發生才叫未遂,不是喔

01:39:44 - 01:39:48
客觀上有任何一個沒有實現

01:39:48 - 01:39:50
都是未遂

01:39:50 - 01:39:51
瞭解嗎，都是未遂喔

01:39:53 - 01:39:54
所以比如說

01:39:54 - 01:39:57
那個人死了，你以為他還活著

01:39:57 - 01:39:58
對他開槍

01:39:58 - 01:39:59
殺人未遂啊

01:39:59 - 01:40:00
是

01:40:00 - 01:40:05
下雨天你沒有帶傘，你去偷別人的傘，結果偷了老半天發現不對，那個傘根本是你自己放的。

01:40:06 - 01:40:07
竊盜未遂，好嗎？

01:40:07 - 01:40:09
竊確認四個要件,都是未遂喔。

01:40:10 - 01:40:14
好,最後啊,未遂犯的處罰,必須法律要有明文的規定。

01:40:15 - 01:40:16
這個叫做法律的明文。

01:40:16 - 01:40:19
我們講四大要件:故意,著手,不遂,明文四大要件。

01:40:20 - 01:40:22
未遂犯的處罰要法律有明文。

01:40:22 - 01:40:25
記得有一個犯罪沒有罰未遂,大家很容易會搞混。

01:40:25 - 01:40:27
普通傷害277。

01:40:27 - 01:40:30
記得哦,277沒有罰未遂哦。

01:40:31 - 01:40:33
所以你考試上不要寫什麼傷害未遂。

01:40:34 - 01:40:35
沒有那種東西哦。

01:40:35 - 01:40:36
沒有罰未遂，記得哦。

01:40:39 - 01:40:42
好，最後第四點，普通未遂的法律效果。

01:40:42 - 01:40:46
我們說符合四大要件，故意,著手,不遂,明文。

01:40:46 - 01:40:49
全部都符合了，那就叫做普通未遂。

01:40:52 - 01:40:58
當一個行為被判定成普通未遂的話，效果就是得減，好，效果就是得減。

01:40:59 - 01:41:00
可減。

01:41:00 - 01:41:00
可不減。

01:41:01 - 01:41:02
通常會減。

01:41:02 - 01:41:05
但是有些情節惡劣的未遂犯，實務上不給減。

01:41:06 - 01:41:07
也是有可能。

01:41:07 - 01:41:09
那種就是法官看不下去那種。

01:41:09 - 01:41:11
不多了，但實務上確實有發生過。

01:41:11 - 01:41:12
欸，那我們講喔。

01:41:13 - 01:41:14
當符合四大要件之後，

01:41:15 - 01:41:17
一般的說法會說這個叫做普通未遂。

01:41:19 - 01:41:22
那實務跟部分早期的學者,

01:41:22 - 01:41:24
他們會講障礙未遂。

01:41:25 - 01:41:27
障礙未遂那個是日語的用語。

01:41:27 - 01:41:29
日本的漢字他們就寫障礙未遂。

01:41:29 - 01:41:33
但是一般我們臺灣現在的主流學界,

01:41:33 - 01:41:33
不會講障礙未遂。

01:41:34 - 01:41:36
因為障礙未遂其實那個名詞很怪。

01:41:37 - 01:41:39
普通未遂不見得是行為人遇到障礙啊。

01:41:39 - 01:41:42
所以我們一般都是用普通未遂啦。

01:41:42 - 01:41:44
障礙未遂就看得懂就好，一般比較不會用這個名字。

01:41:47 - 01:41:48
好。

01:41:48 - 01:41:49
接著來，我們往下看喔。

01:41:50 - 01:41:54
我們看完了，一般的未遂，未遂犯的要件，處罰之後，我們就來看到未遂犯的特殊類型。

01:41:57 - 01:41:59
未遂犯的特殊類型，來，兩類喔。

01:42:00 - 01:42:01
不能未遂，還有中止未遂。

01:42:04 - 01:42:08
我們這裡首先來看到第一種類型，叫做不能未遂。

01:42:09 - 01:42:15
所謂不能未遂的意思就是，這個犯罪之所以沒有辦法達於既遂，

01:42:16 - 01:42:17
本來就不可能。

01:42:18 - 01:42:21
換作是任何人都不能的，這個叫做不能未遂。

01:42:22 - 01:42:29
像我剛說的，想在花蓮的海邊，用手槍打到美國西岸的人。

01:42:29 - 01:42:29
不能未遂。

01:42:30 - 01:42:36
用或者比如說，這個是屍體，而且很明顯腐腫發臭流膿了。

01:42:36 - 01:42:39
行為人還以為那個人活著，要去砍殺他。

01:42:39 - 01:42:40
不能未遂。

01:42:40 - 01:42:42
這樣的情況，這個叫不能未遂。

01:42:44 - 01:42:47
好，我們來看哦，26這邊。

01:42:49 - 01:42:52
不能未遂啊，在現行法26條的規定。

01:42:53 - 01:42:54
你看哦，26條這麼說。

01:42:57 - 01:43:00
行為不能發生犯罪的結果。

01:43:01 - 01:43:03
又無危險者，不罰。

01:43:04 - 01:43:05
所以兩個要件都要有。

01:43:05 - 01:43:09
第一個是不能發生犯罪的結果。

01:43:10 - 01:43:12
第二個是無危險。

01:43:13 - 01:43:15
兩個都具備的話，這個行為是不罰。

01:43:15 - 01:43:18
不能發生結果又有危險的話呢，不罰，像我剛剛講的案例。

01:43:19 - 01:43:22
全部都是不能未遂。

01:43:22 - 01:43:24
不能未遂其實以前有罪啦。

01:43:24 - 01:43:26
對，他以前是有罪的。

01:43:26 - 01:43:30
後來在2006年刑法修正之後，他改成無罪，他改成不罰。

01:43:30 - 01:43:30
為什麼呢？

01:43:33 - 01:43:35
因為這個說來就有點詭異啦。

01:43:36 - 01:43:41
我剛剛講，我們目前多數說的，多數說的那個什麼，我們多數說的未遂犯處罰根據是什麼？

01:43:42 - 01:43:43
是印象理論，對不對？

01:43:44 - 01:43:46
可是2006年那一次的刑法修正。

01:43:46 - 01:43:50
是由甘添貴老師他們的臺灣刑事法學會所主導的。

01:43:51 - 01:43:53
那他們是以劉日老師為主,所以他們採的是客觀未遂論。

01:43:55 - 01:43:57
進而會得出這個結論。

01:43:57 - 01:43:58
就跟現在通說不一樣,你想好。

01:43:59 - 01:43:59
你

01:44:00 - 01:44:03
客觀未遂論必然會得出不能未遂不法的結論啊,一定會啊,為什麼?

01:44:04 - 01:44:09
因為客觀未遂論覺得罰未遂犯的理由是因為未遂犯有危險。

01:44:10 - 01:44:13
那反觀不能未遂,他就沒有危險,你罰他幹什麼?

01:44:13 - 01:44:14
合理嘛,對不對?

01:44:15 - 01:44:21
所以如果採客觀未遂論的話,不能未遂當然會不罰,當然會無罪,知道嗎?

01:44:21 - 01:44:24
這個是採客觀未遂論必然的結果,所以

01:44:25 - 01:44:29
我們現行法不能未遂不罰呢,當然跟客觀未遂論是有關的。

01:44:30 - 01:44:30
好。

01:44:30 - 01:44:31
那我們知道了。

01:44:32 - 01:44:33
不能未遂前面有預備。

01:44:34 - 01:44:41
那你想哦,不能未遂是不法的話,那麼不能未遂在預備階段,難道要處罰嗎?

01:44:43 - 01:44:43
當然不用啊。

01:44:44 - 01:44:45
舉重若輕嘛，對不對？

01:44:46 - 01:44:49
你想用砂糖把糖尿病的病患毒死。

01:44:50 - 01:44:53
你把砂糖給他吃，那個叫不能為繼，對不對？

01:44:54 - 01:44:56
那你正拿著砂糖去找糖尿病的病患呢？

01:44:57 - 01:44:59
預備啊,對不對?

01:44:59 - 01:44:59
預備啊。

01:44:59 - 01:45:00
欸,那不能未遂

01:45:00 - 01:45:00
不罰了。

01:45:00 - 01:45:03
不能未遂在預備階段難道有罪哦?

01:45:03 - 01:45:04
當然更無罪嘛，對不對？

01:45:04 - 01:45:05
非常容易理解喔。

01:45:05 - 01:45:09
所以不能未遂，如果在預備階段呢，當然也不會成立犯罪。

01:45:10 - 01:45:10
好。

01:45:10 - 01:45:11
我們來看它的要件。

01:45:12 - 01:45:14
前面體系圖都有畫喔。

01:45:14 - 01:45:15
我們講不能未遂兩大要件。

01:45:16 - 01:45:19
第一個叫做不能發生犯罪結果。

01:45:20 - 01:45:22
第二個叫做無危險。

01:45:23 - 01:45:24
我們先來看到第一個要件。

01:45:25 - 01:45:26
不能發生犯罪結果。

01:45:28 - 01:45:29
這個要件喔，說真的。

01:45:30 - 01:45:31
他沒有什麼篩選的意義。

01:45:32 - 01:45:33
也就是說這個要件其實不重要。

01:45:34 - 01:45:36
可是沒辦法，因為法條有規定。

01:45:36 - 01:45:37
所以我們還是要審，知道嗎？

01:45:37 - 01:45:38
其實它不重要，但法條寫，所以我們還是要審。

01:45:40 - 01:45:44
那我們講喔，不能發生犯罪結果。

01:45:44 - 01:45:45
理論上有三類。

01:45:46 - 01:45:50
主體不能，客體不能，還有手段不能，有這三類。

01:45:52 - 01:45:55
主體不能是說啊，這個犯罪是身分犯。

01:45:55 - 01:45:59
可是行為人因為誤認事實的關係，

01:45:59 - 01:46:00
而覺得

01:46:00 - 01:46:01
幾是這條罪的主體，這個叫主體不能。

01:46:03 - 01:46:07
比如說這個人，他明明就不是，算這個例子我等下來說，主體不能。

01:46:08 - 01:46:13
再來第二個例子叫做，第二種情況叫客體不能，行為客體不存在。

01:46:14 - 01:46:17
像我剛剛說的啊，你要去殺的那個人，他早就死了。

01:46:18 - 01:46:22
你持槍掃射被害人的家，但被害人家根本就沒有人在家。

01:46:22 - 01:46:23
這個叫客體不能。

01:46:24 - 01:46:26
還有什麼呢，手段不能。

01:46:27 - 01:46:30
這個手段根本無法遂行犯罪。

01:46:30 - 01:46:35
槍枝的射程不夠，毒藥的劑量不夠之類的，這個叫手段不能。

01:46:36 - 01:46:41
好，不管是哪一種不能，都可以符合不能發生犯罪的結果這個要件。

01:46:42 - 01:46:44
來，我們翻到248頁。

01:46:45 - 01:46:47
這個有一隻小豬符號的專題研究，來我們來看一下。

01:46:51 - 01:46:55
主體不能這個東西啊，在國內的學界引發蠻多誤會的。

01:46:56 - 01:46:57
不只是同學搞錯。

01:46:58 - 01:47:00
有的時候連學者都搞錯。

01:47:00 - 01:47:02
來，我們講什麼叫主體不能。

01:47:02 - 01:47:10
主體不能指的是，行為人因為誤認事實，而以為自己是這條罪的主體。

01:47:11 - 01:47:12
這才叫主體不能喔，知道嗎？

01:47:13 - 01:47:16
誤認事實的關係，而以為自己是這條罪的主體。

01:47:17 - 01:47:19
像我第一堂課舉過的例子啊，我課本上就有寫啊。

01:47:22 - 01:47:23
公司的業務經理。

01:47:24 - 01:47:25
他一早被老闆開除了。

01:47:26 - 01:47:27
開除信放他桌上。

01:47:28 - 01:47:30
但他不知道自己被開除了。

01:47:30 - 01:47:31
因為他沒有進公司嘛。

01:47:32 - 01:47:39
於是這個業務經理在不知道自己已經被開除的情況之下，他還出去簽訂了一份出賣公司的契約。

01:47:39 - 01:47:40
這個叫背信未遂。

01:47:41 - 01:47:44
而且這個是非常典型的主體不能。

01:47:44 - 01:47:49
因為他被開除了，不再是刑法條文所謂的為他人處理事務。

01:47:50 - 01:47:52
可是他主觀上覺得自己是啊，對不對，所以這個叫主體不能。

01:47:54 - 01:47:55
所以中止喔。

01:47:57 - 01:47:58
來。

01:47:58 - 01:47:59
那我再舉一個例子。

01:48:01 - 01:48:02
同學我們去過新北市府,沒去過的話可以去一下哈,新北市府的

01:48:06 - 01:48:07
應該算那個算頂樓嘛,就37樓,他有一個展望臺,蠻漂亮的,可以看這個

01:48:12 - 01:48:15
板橋綜合地區的,還有對面的新莊,那個晚上看這個蠻漂亮的,沒去過可以去一下,新北市府的頂樓。

01:48:19 - 01:48:23
那個地方,我們知道他跟東京都廳水乳交融,因為東京都廳也有一個這樣的地方。

01:48:25 - 01:48:26
那上去也不用錢，我記得，所以同學有去東京旅遊的話，可以去一下都廳。

01:48:29 - 01:48:31
這個都廳頂樓那個地方還蠻漂亮的。

01:48:32 - 01:48:32
好。

01:48:33 - 01:48:36
我每次去新北市府的展望臺的時候。

01:48:37 - 01:48:38
因為他在電梯最上面嘛。

01:48:39 - 01:48:40
然後我搭電梯的時候。

01:48:41 - 01:48:44
我都會看到那個樓層表。

01:48:44 - 01:48:46
其中有市長室。

01:48:46 - 01:48:49
在16樓還是17樓,在中間的樓層,市長室。

01:48:49 - 01:48:51
我每次想說那我如果按市長室。

01:48:52 - 01:48:54
然後打開，去跟好友拍拍肩膀聊聊天，他會理我。

01:48:55 - 01:48:58
應該不會，對不對，搞不好連去都去不了，好。

01:48:58 - 01:48:59
那我要講的是：

01:49:01 - 01:49:04
假設我想去找侯友宜聊天，

01:49:05 - 01:49:07
新北市府的保全擋下來。

01:49:07 - 01:49:09
保全說你是誰。

01:49:09 - 01:49:12
我說我是市井小民啊，我想跟市長吐露我的心事啊。

01:49:13 - 01:49:15
保全說不行啊，你沒有經過允許是不能進去的啊。

01:49:16 - 01:49:19
那我就塞錢給保全啊，拜託啦，你讓我去見市長。

01:49:20 - 01:49:21
保全收了我的紅包，放我過去。

01:49:22 - 01:49:23
結果。

01:49:23 - 01:49:26
當天下午班前,保全越心想越不對勁。

01:49:26 - 01:49:29
想說他收我的紅幫放我去見市長。

01:49:29 - 01:49:30
那不是他

01:49:30 - 01:49:30
的

01:49:30 - 01:49:30
嗎？

01:49:30 - 01:49:30
？

01:49:30 - 01:49:32
他覺得自己很危險，趕緊去跟政風機關坦承。

01:49:32 - 01:49:35
說我收了民眾的紅包，所以這個保全員是貪汙犯罪的主體，不能嗎？

01:49:42 - 01:49:42
不是。

01:49:43 - 01:49:44
這個案例不是，為什麼？

01:49:45 - 01:49:46
因為保全沒有委任事實啊。

01:49:47 - 01:49:48
懂意思吧？

01:49:49 - 01:49:51
保全是不是刑法上的公務員，那個不是事實問題，那個叫法律評價。

01:49:55 - 01:49:59
這跟我們前面那個經理被開除的例子不一樣喔。

01:50:00 - 01:50:00
心理被開除的例子

01:50:00 - 01:50:02
很明顯心理怎麼樣?

01:50:03 - 01:50:04
沒有意識到

01:50:04 - 01:50:06
老闆開除他這件事,對不對?

01:50:06 - 01:50:07
那是無稽之談

01:50:07 - 01:50:09
可是保全這個例子

01:50:10 - 01:50:13
保全對於他是民間保全公司的員工

01:50:14 - 01:50:16
只是受分發來市府這邊工作

01:50:16 - 01:50:17
他對這件事誤認

01:50:17 - 01:50:20
沒有啊，他誤認是說，所以我這樣不算公務員喔

01:50:21 - 01:50:23
他誤認的是這個

01:50:23 - 01:50:23
這個叫什麼？

01:50:23 - 01:50:24
法律評價

01:50:24 - 01:50:26
知道嗎？所以這個跟主體不能沒有關係喔

01:50:26 - 01:50:27
而且喔，這沒有關係喔

01:50:28 - 01:50:29
主體不能是指什麼？

01:50:29 - 01:50:30
事實誤認

01:50:31 - 01:50:33
事實誤認，以為他是指使的主體

01:50:33 - 01:50:34
這個才算喔

01:50:37 - 01:50:40
好，所以這個是第一個要件，不能發生犯罪的結果

01:50:41 - 01:50:42
OK，我們現在這邊休息一下

01:50:42 - 01:50:47
等一下我們再來看最重要的要件，無為危險，這個我們一下再看

01:50:50 - 01:50:53
好，接下來啊，我們來看什麼叫做危險

01:50:53 - 01:50:57
剛剛我說的，不能發生犯罪結果，這個要件說真的它不重要

01:50:57 - 01:51:00
因為不管是哪一種不能

01:51:00 - 01:51:00
沒用嘛

01:51:00 - 01:51:03
你符合要件一沒有用啊,你還要符合要件二啊

01:51:03 - 01:51:04
要件二叫做危險，這才是判斷的關鍵

01:51:04 - 01:51:12
因為我說真的啦，所有的未遂，其實你要去套不能發生犯罪結果，幾乎都套得出來

01:51:13 - 01:51:15
比如說你想槍枝的射程不夠

01:51:16 - 01:51:17
手段不能嗎

01:51:17 - 01:51:18
被害人不在家

01:51:19 - 01:51:20
客體不能，有沒有？

01:51:20 - 01:51:21
其實你都套得出來

01:51:21 - 01:51:22
那個不是關鍵

01:51:22 - 01:51:24
所以關鍵在什麼呢？在無危險

01:51:24 - 01:51:25
好，所以怎麼判斷危險？

01:51:26 - 01:51:28
傳統上這三大不同的說法

01:51:29 - 01:51:30
客觀危險說

01:51:30 - 01:51:31
具體危險說，還有重大無知說

01:51:32 - 01:51:34
傳統上主要是這三說

01:51:35 - 01:51:38
當然啦,有趨勢學者提出一些修正的版本

01:51:38 - 01:51:42
像許恆達老師有一個這個修正版的具體危險說之類的

01:51:42 - 01:51:44
那個有些太細,我就不多說了

01:51:45 - 01:51:46
因為我們準備國考是這樣

01:51:47 - 01:51:48
準備國考

01:51:48 - 01:51:49
我們要學的廣

01:51:49 - 01:51:52
那有一些學者比較少數的個人意見

01:51:53 - 01:51:55
通常我在國考上不見得都會說

01:51:55 - 01:51:56
在這個課堂不見得都會說

01:51:56 - 01:51:59
因為我覺得講太多，有時候會增加同學的負擔，沒有必要

01:52:00 - 01:52:00
考試考不能未遂，你要掌握的就是傳統的這三說。

01:52:03 - 01:52:05
這三說是基本，知道嗎？

01:52:05 - 01:52:09
剩下學者提出來一些變化版的說法，那個可能都是由這三說去衍生的，所以最基本的三說，你一定要知道。

01:52:12 - 01:52:15
首先第一說叫客觀危險說。

01:52:15 - 01:52:21
這一說的主張是從事後的角度去判斷這個行為有沒有危險。

01:52:23 - 01:52:25
他會認為，有沒有危險是事實問題。

01:52:26 - 01:52:30
那既然是事實問題的話，我們就要從事後的角度去判斷。

01:52:30 - 01:52:39
事後來看，如果這個犯罪自始就沒辦法達於既遂的，這叫無危險，這個叫絕對不能，所以他是無危險。

01:52:41 - 01:52:51
相對的，那如果這個行為，他並不是自始註定的，他是行為當下的偶然因素才造成這個行為無法既遂的，那他就是有危險。

01:52:53 - 01:52:56
這個叫相對不能，他就叫做有危險。

01:52:57 - 01:52:59
這個是傳統上面的說法。

01:52:59 - 01:53:01
這個是最早期的說法。

01:53:01 - 01:53:02
這個叫做客觀危險說。

01:53:03 - 01:53:03
所以再講一次喔。

01:53:05 - 01:53:06
客觀危險說的判準是什麼呢？

01:53:07 - 01:53:14
從事後的角度去看，事後來看，如果自始無法既遂。

01:53:14 - 01:53:15
比如說像什麼呢？

01:53:16 - 01:53:17
被害人不在家。

01:53:18 - 01:53:20
槍枝的射程範圍不夠。

01:53:21 - 01:53:22
毒藥的劑量不夠。

01:53:23 - 01:53:23
之類的。

01:53:24 - 01:53:25
應該可以感覺到吧。

01:53:25 - 01:53:28
這種自始註定、自始存在的，它叫做有危險。

01:53:30 - 01:53:37
而相對的，如果這個行為無法既遂，並不是自始的，而是當下的偶然因素，這個是什麼呢？

01:53:40 - 01:53:41
這個是。

01:53:41 - 01:53:43
這個才是有危險。

01:53:43 - 01:53:44
反之前面那個是無危險，知道嗎？

01:53:45 - 01:53:47
後面這種當下偶然因素所導致的，比如說。

01:53:48 - 01:53:50
被害者一個轉身閃過。

01:53:51 - 01:53:53
比如說行為人開槍的時候手抖，沒有打到。

01:53:54 - 01:53:57
或者比如說被害人的一個蹲下的動作，讓子彈沒有命中。

01:53:58 - 01:54:00
或者比如說這一杯飲料的毒。

01:54:00 - 01:54:01
我要劑量是夠強的，

01:54:02 - 01:54:05
只是被害人當天太飽，他喝沒兩口就把這個飲料給丟了。

01:54:05 - 01:54:06
這種的，知道吧？

01:54:07 - 01:54:12
這種當下偶然的因素所導致的，這個叫做有危險，知道嗎？

01:54:12 - 01:54:13
這個是有危險。

01:54:13 - 01:54:17
好，所以這一說法主張，從事後的角度，事後哦，

01:54:18 - 01:54:22
從事後來看，這個行為是自始就達成的，

01:54:22 - 01:54:27
還是行為當下偶然的因素所造成的，

01:54:27 - 01:54:30
前者是危險，後者是有危險。

01:54:31 - 01:54:31
好。

01:54:32 - 01:54:34
可是啊，這一說法是一個歷史上的說法。

01:54:35 - 01:54:37
這一說法現在幾乎沒有人採納了。

01:54:37 - 01:54:37
為什麼？

01:54:38 - 01:54:40
因為後來有一個批評很有趣。

01:54:41 - 01:54:42
後來人就說了，

01:54:42 - 01:54:45
你要從事後判斷有沒有危險，

01:54:46 - 01:54:46
沒有意義。

01:54:47 - 01:54:47
為什麼？

01:54:47 - 01:54:50
因為你要從事後去判斷的話，

01:54:51 - 01:54:53
那所有的未遂幾乎都沒有危險啊。

01:54:54 - 01:54:54
你想一想喔。

01:54:56 - 01:55:00
照原本的說法，子彈差三公分沒有打到被害人，

01:55:00 - 01:55:00
有沒有危險？

01:55:01 - 01:55:03
有危險，對不對？

01:55:03 - 01:55:04
因為那個是當下原因所導致的。

01:55:04 - 01:55:07
被害人突然一個下蹲閃躲的動作，以致被害人沒有中彈。

01:55:07 - 01:55:08
有沒有危險？

01:55:08 - 01:55:09
一樣怎麼樣？

01:55:10 - 01:55:11
有危險。

01:55:11 - 01:55:13
因為被害人閃躲，偶然因素嘛，對不對？

01:55:14 - 01:55:15
可是後者的批評說不對啊。

01:55:16 - 01:55:19
你事後來看的話，你會不會知道子彈差三公分？

01:55:20 - 01:55:21
你知道啊。

01:55:21 - 01:55:22
事後來看你當然知道啊。

01:55:23 - 01:55:26
事後來看，你會不會知道被害人等下會蹲下來？

01:55:27 - 01:55:27
會啊。

01:55:27 - 01:55:28
你會知道啊。

01:55:29 - 01:55:32
那你從上帝視角，你什麼都知道你在回頭看，

01:55:32 - 01:55:33
哪有危險？

01:55:34 - 01:55:35
懂我的意思吧？

01:55:35 - 01:55:37
所以後來就有人說，事後判斷沒有意義。

01:55:38 - 01:55:42
因為你從事後來看的話，我們俗稱事後判斷就是一種上帝視角嘛。

01:55:43 - 01:55:47
你從那種角度來看，將來會發生什麼事，你就已經知道了，

01:55:47 - 01:55:50
那你已經知道一切的事情之後，你再回來看這件事，

01:55:50 - 01:55:50
怎麼會有危險？

01:55:51 - 01:55:56
所以後面就有人說，你真的要貫徹客觀危險說的話，

01:55:57 - 01:55:59
那從事後來看有什麼是有危險的？

01:56:00 - 01:56:05
所以如果貫徹客觀危險說，會導致絕大多數的普通未遂都變成不能未遂。

01:56:06 - 01:56:06
有這個批評。

01:56:08 - 01:56:11
這個批評，我再講一個比喻，應該會更貼切。

01:56:12 - 01:56:15
我不知道同學們看恐怖片的經驗，應該或多或少都有。

01:56:17 - 01:56:18
我還不喜歡看恐怖片。

01:56:19 - 01:56:19
真的啊。

01:56:19 - 01:56:24
就是我會看的電影就是那種劇情類的、溫馨類的、愛情類的，我會看的是那一類的。

01:56:24 - 01:56:29
我真的不喜歡，我最討厭看兩種片，一個是恐怖片，一個是那種槍戰那種動作片。

01:56:30 - 01:56:31
我最不喜歡看這兩種。

01:56:31 - 01:56:34
因為看這兩種，我會緊張，我緊張就會胃痛。

01:56:35 - 01:56:39
真的啊,所以看這種片都會看得不舒服,我很不喜歡那種緊張的感覺。

01:56:40 - 01:56:40
我記得。

01:56:41 - 01:56:45
我之前看過的恐怖片,我看過什麼？

01:56:45 - 01:56:49
之前有一次有朋友邀我去看一部跟飛機有關的恐怖片。

01:56:50 - 01:56:54
十幾年前的泰國片,什麼鬼機Numbereight,簡稱鬼機吧。

01:56:55 - 01:56:58
對,就以前泰國一部跟那個飛機有關的鬼片。

01:56:58 - 01:57:00
那部拍的真的很爛。

01:57:01 - 01:57:05
因為那一部的飛機的駕駛艙跟飛機的外觀是不一致的。

01:57:05 - 01:57:09
所以我身為一個航空人有看的覺得說這個太low了吧,都沒有問過專業人員。

01:57:10 - 01:57:12
然後他那個飛機的開發看起來也不對。

01:57:12 - 01:57:16
比如說要放flap，然後他拉的是一個什麼燈光的開關之類的。

01:57:16 - 01:57:18
就想說是飛機還有這樣開的。

01:57:18 - 01:57:19
好，我想。

01:57:19 - 01:57:21
看那種片，雖然它很爛。

01:57:22 - 01:57:23
但是第一次還是會緊張。

01:57:24 - 01:57:27
因為什麼時候突然有一個人頭飛出來，什麼我根本不知道啊。

01:57:27 - 01:57:33
可是當我看過那部片的時候，假設我隔天或者我等它下檔之後再去上面二刷。

01:57:33 - 01:57:35
我看了，一定不會緊張。

01:57:36 - 01:57:37
剛看過記憶猶新嘛。

01:57:38 - 01:57:39
客觀危險說大概就是這樣的概念。

01:57:40 - 01:57:42
恐怖片第一次看，第二次怎麼會恐怖。

01:57:43 - 01:57:48
你就看過有印象啦，最後誰會活，誰會死，什麼時候會有鬼跳出來，你都知道啦，是怎麼會恐怖，對吧。

01:57:49 - 01:57:53
所以客觀危險說的問題就是這樣。

01:57:54 - 01:57:56
你真的要貫徹事後判斷的角度，

01:57:56 - 01:57:57
那沒有意義。

01:57:57 - 01:58:00
事後判斷來講，幾乎所有的未遂，

01:58:00 - 01:58:01
都會變不能未遂，

01:58:01 - 01:58:02
知道嗎？

01:58:02 - 01:58:03
這是客觀學說的問題，

01:58:03 - 01:58:04
但我要強調喔，

01:58:05 - 01:58:07
所有的未遂都會變不能未遂，

01:58:08 - 01:58:10
這不是客觀危險說的初衷。

01:58:11 - 01:58:13
這學說一開始當然沒那麼爛，知道吧？

01:58:13 - 01:58:18
這個學說他一開始當然會想說，我要從事後的角度去區分，

01:58:18 - 01:58:22
看哪個是自始的，哪個是偶然的。

01:58:22 - 01:58:26
只是學者會說，你用事後的視角自始就不對，

01:58:26 - 01:58:29
因為你用事後的話，那所有的都是不能，瞭解嗎？

01:58:29 - 01:58:32
這個是最早起，客觀寫說，好。

01:58:33 - 01:58:37
再來接著，第二說叫做具體危險說。

01:58:37 - 01:58:40
具體危險說呢，它又叫新客觀說。

01:58:40 - 01:58:42
這一說的視角就不一樣了。

01:58:43 - 01:58:44
具體危險說主張啊,

01:58:45 - 01:58:46
危險不是事實,

01:58:47 - 01:58:49
危險是一種價值判斷。

01:58:50 - 01:58:52
它的前提認知就不一樣了,

01:58:52 - 01:58:55
客觀危險說覺得危險是事實

01:58:55 - 01:58:57
但具體危險說說不對，危險不是事實啦

01:58:57 - 01:59:19
危險是一種感受，

01:59:19 - 01:59:41
是一種價值判斷。

01:59:42 - 01:59:44
我們來思考一下，誰講的對？

01:59:46 - 01:59:47
當然具體危險說講的對

01:59:48 - 01:59:49
危險當然不是事實。

01:59:50 - 01:59:51
相信我，危險真的不是事實。

01:59:52 - 01:59:56
我以前大一的刑總老師舉的一個很深刻的例子，我一直記得到現在。

01:59:56 - 02:00:00
當時老師都跟我們講說危險當然不是事實，危險是一種感覺。

02:00:00 - 02:00:01
飛機逆風才飛得起來啊。

02:00:01 - 02:00:03
那個空氣力學的原理你們想一想就知道,

02:00:03 - 02:00:05
順風怎麼飛得起來,要逆風才飛得起來啊。

02:00:05 - 02:00:07
所以如果你有朋友要出國的話,

02:00:07 - 02:00:09
你不可以祝人家一路順風,知道嗎?

02:00:09 - 02:00:11
飛機起降要逆風啊,好。

02:00:12 - 02:00:14
那個,飛機起降逆風嘛,

02:00:15 - 02:00:16
那側風怎麼辦?

02:00:16 - 02:00:19
風從飛機的左右側吹,側風怎麼辦?

02:00:20 - 02:00:21
你們可以去找影片啊,

02:00:21 - 02:00:24
飛機側風落地的時候,是斜的這樣滑下去,

02:00:25 - 02:00:26
很像螃蟹在走

02:00:26 - 02:00:29
沒錯，飛機側風是斜的這樣滑下去

02:00:29 - 02:00:32
快到跑道的時候，機腳再踩尾舵讓機頭回正。

02:00:33 - 02:00:35
側風是要這樣落的喔，斜的落地。

02:00:36 - 02:00:38
懂飛機的人看到側風落地

02:00:38 - 02:00:40
對啊，本來就斜的飛啊。

02:00:40 - 02:00:43
可是不懂飛機的人想說，蛤，這個飛機怎麼飛成這個樣子？

02:00:44 - 02:00:45
所以你說危不危險，當然不是事實啊。

02:00:45 - 02:00:46
那個是感受啊。

02:00:47 - 02:00:49
懂飛機的人看到覺得說，對啊，本來就這樣飛啊，不然咧。

02:00:50 - 02:00:51
不懂的人看到就說，喔，好危險喔。

02:00:52 - 02:00:54
所以危險不是事實啦，危險是感受。

02:00:54 - 02:00:56
所以你知道嗎，以後啊，

02:00:57 - 02:00:58
如果你在路上飆車，

02:00:59 - 02:01:40
差點撞到人

02:01:40 - 02:01:43
對方很生氣地罵你說你這樣開車很危險欸,

02:01:43 - 02:01:44
你要怎麼回他你知道嗎?

02:01:45 - 02:01:46
你要回他說，蛤，真的哦？

02:01:47 - 02:01:49
可是我不覺得危險欸，不然你想怎樣？

02:01:51 - 02:01:52
你這樣講會不會被打，我不知道。

02:01:53 - 02:01:54
但這個說法邏輯100分。

02:01:55 - 02:01:56
危險是感受不是事實,

02:01:57 - 02:01:58
知道嗎,它是一種感受。

02:01:58 - 02:01:59
所以具體來說危險的主張是好,

02:02:00 - 02:02:01
被害人等一下會不會閃過,

02:02:01 - 02:02:02
旁觀者不知道啊。

02:02:02 - 02:02:03
子彈有沒有差三公分，

02:02:03 - 02:02:04
旁觀者看不出來啊，

02:02:04 - 02:02:05
對不對？

02:02:05 - 02:02:06
所以那些案例，

02:02:06 - 02:02:07
如果照具體危險說的話,

02:02:08 - 02:02:09
當然都有危險,

02:02:10 - 02:02:11
所以請他具體說危險。

02:02:13 - 02:02:14
接下來,

02:02:15 - 02:02:15
下面這邊講,

02:02:16 - 02:02:17
不同的犯罪啊,

02:02:17 - 02:02:19
涉及不同的生活領域,

02:02:19 - 02:02:20
所以這個第三人呢,

02:02:21 - 02:02:25
也必須是這個領域當中具有專門知識的人喔。

02:02:26 - 02:02:27
所以這邊講,

02:02:27 - 02:02:28
像比如說，

02:02:28 - 02:02:30
同樣是毒品案件好了。

02:02:32 - 02:02:32
這裡說，

02:02:32 - 02:02:33
製毒。

02:02:34 - 02:02:34
假設，

02:02:34 - 02:02:36
行為人所採取的,

02:02:36 - 02:02:39
所使用的材料跟化學方法,

02:02:40 - 02:02:42
根本提煉不出毒品。

02:02:43 - 02:02:44
這種我們怎麼判斷？

02:02:45 - 02:02:46
我跟各位講一個小常識。

02:02:48 - 02:02:50
這個是毒蟲之間的都市傳說。

02:02:51 - 02:02:54
各個領域都有各個領域的都市傳說。

02:02:55 - 02:02:57
國考的考生對刑法的作答也有一些都市傳說，

02:02:58 - 02:02:59
這個以後有機會再跟同學分享。

02:03:00 - 02:03:02
毒蟲之間的都市傳說是什麼呢？

02:03:04 - 02:03:06
這個我聽不止一個毒蟲講過。

02:03:07 - 02:03:07
他們說啊,

02:03:08 - 02:03:10
如果驗尿安非他命陽性的話,

02:03:11 - 02:03:11
沒關係,

02:03:12 - 02:03:13
那你就跟檢察官說,

02:03:14 - 02:03:16
你吃的是日本的EVE感冒藥,

02:03:17 - 02:03:19
這樣的話你就可以被不起訴。

02:03:19 - 02:03:20
毒蟲都會這樣說。

02:03:22 - 02:03:23
我之前去日本玩的時候啊,

02:03:23 - 02:03:24
導遊特別跟我們講,

02:03:25 - 02:03:26
說你在日本買那個EVE，

02:03:26 - 02:03:27
你不能買太多。

02:03:28 - 02:03:29
不然的話你回臺灣會被，

02:03:30 - 02:03:32
會被那個海關攔下來。

02:03:32 - 02:03:35
因為日本的EVE跟臺灣的成分不一樣。

02:03:36 - 02:03:39
日本的EVE有一個成分叫做麻黃鹼。

02:03:40 - 02:03:41
那個臺灣的EVE沒有。

02:03:42 - 02:03:44
所以為什麼有些人要買那個EVE，

02:03:45 - 02:03:46
會特別去日本買？

02:03:47 - 02:03:48
因為成分真的不一樣。

02:03:48 - 02:03:51
有些人他們真的覺得日本有麻黃鹼的那個成分,

02:03:51 - 02:03:52
比較有止痛的效果,

02:03:53 - 02:03:53
真的有。

02:03:54 - 02:03:54
好,

02:03:55 - 02:03:56
那個EVE止痛藥,

02:03:57 - 02:03:58
它有麻黃鹼的成分。

02:03:59 - 02:03:59
那個...

02:04:00 - 02:04:00
成分跟安非他命很像。

02:04:03 - 02:04:12
所以呢，呃，如果是驗尿的話，用試紙驗尿的話，確實有可能會產生偽陽性的反應。

02:04:12 - 02:04:13
有可能。

02:04:13 - 02:04:15
所以毒蟲就流傳這個傳說，

02:04:15 - 02:04:15
說沒關係，

02:04:15 - 02:04:17
你以後被驗安非他命陽性的話，

02:04:17 - 02:04:19
你就拿一包EVE給檢察官看，

02:04:19 - 02:04:21
說我吃日本來的EVE，

02:04:21 - 02:04:22
所以那個是偽陽性，

02:04:22 - 02:04:23
那個不可採，

02:04:23 - 02:04:24
你就可以無罪。

02:04:24 - 02:04:24
他們都這樣說。

02:04:25 - 02:04:27
那我跟你們說，那個是假的。

02:04:27 - 02:04:34
因為檢察官要起訴一個人吸毒犯，要判一個人吸毒有罪，不會只憑試紙的初篩。

02:04:35 - 02:04:40
那個就像你去篩武漢肺炎一樣，試紙初篩就像快篩，快篩會偽陽偽陰嘛。

02:04:41 - 02:04:44
所以以前要進一步確認的話要做PCR。

02:04:44 - 02:04:54
那毒品也是，毒品要進一步確認的話，他們會把那個被告的尿拿去儀器裡面跑一個叫做氣相層析法，去做那個質譜儀的檢驗。

02:04:54 - 02:04:56
那個檢驗出來是用數字的。

02:04:57 - 02:05:01
有數字出來的話，到底是吃止痛藥，還是真的用安非他命。

02:05:01 - 02:05:03
那個數字差太多的。

02:05:04 - 02:05:04
不可能。

02:05:05 - 02:05:05
不可能。

02:05:05 - 02:05:09
我以前也遇過有毒蟲，希望我幫他這樣主張無罪。

02:05:10 - 02:05:12
我想說，好啊，你要給我錢，我就幫你寫啊。

02:05:12 - 02:05:14
我這樣會不會違反律師的倫理啊？

02:05:15 - 02:05:17
明明沒有勝算幫他寫，一次而已啦。

02:05:18 - 02:05:19
後來我就覺得這種錢我不想賺。

02:05:21 - 02:05:25
因為有些吸毒的人腦子都怪怪的，有時候是寧可不想賺他們的錢啦。

02:05:27 - 02:05:27
我是講喔。

02:05:29 - 02:05:30
為什麼要講這個都市傳說？

02:05:30 - 02:05:32
對，所以這個不可能，那個不可採。

02:05:33 - 02:05:37
如果你有朋友有在吸毒的話，各位應該沒有啦，如果有的話跟他們說不要再往這方面了，檢察官聽到覺得很煩了。

02:05:39 - 02:05:40
好啦，所以總之喔。

02:05:42 - 02:05:48
因為有些人真的會用那個感冒糖漿或感冒藥想提煉安非他命。

02:05:48 - 02:05:52
但是你要提煉安非他命，那個要化學方法欸。

02:05:52 - 02:05:55
你以為把感冒藥磨碎煮一煮就變成安非他命喔，不可能嘛。

02:05:55 - 02:05:56
那有一些化學方法。

02:05:57 - 02:06:00
所以這裡所取的例子就是說，那如果行為能力

02:06:00 - 02:06:01
他所使用的原料，

02:06:02 - 02:06:05
或者所使用的化學方法根本是錯的。

02:06:05 - 02:06:07
他那樣煉根本就煉不出東西。

02:06:08 - 02:06:10
那旁觀者要從誰的旁觀者的角度去看？

02:06:10 - 02:06:12
所以這裡許澤天老師就說的，

02:06:13 - 02:06:16
我們的旁觀者在一些專業領域當中，

02:06:16 - 02:06:18
你要用什麼旁觀者？

02:06:18 - 02:06:20
懂那個專業領域的角度。

02:06:20 - 02:06:22
不然那個旁觀者是沒有意義的，

02:06:22 - 02:06:22
知道嗎？

02:06:22 - 02:06:24
你要用懂這件事情的旁觀者。

02:06:24 - 02:06:27
所以就製造毒品來說的話，

02:06:28 - 02:06:32
你就要從一個懂製造毒品的旁觀者的角度去做判斷。

02:06:33 - 02:06:33
可是反之，

02:06:34 - 02:06:35
販毒不是喔。

02:06:36 - 02:06:38
有人拿白糖當毒品去販賣。

02:06:39 - 02:06:40
這個是不是不能未遂？

02:06:40 - 02:06:41
這個不是喔。

02:06:41 - 02:06:44
因為販毒這件事不需要專業,

02:06:44 - 02:06:45
它跟製毒不一樣,

02:06:45 - 02:06:46
知道嗎?

02:06:46 - 02:06:47
所以需要專業領域的,

02:06:48 - 02:06:49
需要專業的領域，

02:06:50 - 02:06:52
旁觀者也必須要是一個什麼呢？

02:06:52 - 02:06:53
有這個專業的旁觀者，

02:06:54 - 02:06:55
這是許老師所強調的。

02:06:57 - 02:06:57
好，

02:06:58 - 02:06:58
最後啊,

02:06:58 - 02:06:58
光和三年,

02:06:59 - 02:07:00
重大無知說。

02:07:01 - 02:07:03
那個重大無知說是劉德老師,

02:07:04 - 02:07:05
大家採的說法,

02:07:05 - 02:07:06
重大無知。

02:07:06 - 02:07:07
這一說法啊,

02:07:08 - 02:07:13
只有行為人出於對日常生活知識的重大無知,

02:07:14 - 02:07:17
這才是不為罪。

02:07:18 - 02:07:18
很嚴格喔。

02:07:19 - 02:07:21
重大無知要限於對什麼呢？

02:07:21 - 02:07:22
日常生活的知識。

02:07:24 - 02:07:24
所以我跟各位講，

02:07:24 - 02:07:26
重大無知說白話的意思是什麼？

02:07:27 - 02:07:28
白話的意思就是，

02:07:29 - 02:07:31
你聽了會露出很嫌惡的表情，

02:07:31 - 02:07:31
然後想說，

02:07:32 - 02:07:32
他是智障嗎？

02:07:33 - 02:07:34
為什麼會有人想用這個方式去犯罪？

02:07:35 - 02:07:36
要到這種程度喔。

02:07:36 - 02:07:36
知道嗎？

02:07:36 - 02:07:37
你聽了會想說，

02:07:37 - 02:07:39
這個人是不是智商有問題？

02:07:39 - 02:07:40
怎麼會想用這個方式去犯罪？

02:07:41 - 02:07:44
這種情況才叫做重大無知。

02:07:45 - 02:07:47
我們講日常生活的經驗,

02:07:47 - 02:07:48
日常生活的知識。

02:07:49 - 02:07:49
好,

02:07:49 - 02:07:49
所以比如說,

02:07:51 - 02:07:55
想拿彈弓射下天上的民航機,

02:07:55 - 02:07:56
對,

02:07:56 - 02:07:57
這個是重大無知。

02:07:58 - 02:07:58
然後呢,

02:08:00 - 02:08:01
還有喔,

02:08:01 - 02:08:05
想給孕婦喝菊花茶，讓孕婦流產。

02:08:05 - 02:08:07
這也是重大無知。

02:08:09 - 02:08:11
這個德國的鄉野奇談啦,

02:08:11 - 02:08:12
說孕婦喝菊花茶會流產,

02:08:13 - 02:08:14
這也是重大無知。

02:08:14 - 02:08:16
然後還有什麼,

02:08:17 - 02:08:24
還有比如說，想給糖尿病的病患喝全糖的飲料，讓糖尿病的病患死掉，

02:08:25 - 02:08:26
這也是重大無知。

02:08:27 - 02:08:31
糖尿病的病患喝太甜可能會身體不舒服，但不會直接死掉。

02:08:32 - 02:08:35
會的話臺南不會有糖尿病病患生存的空間。

02:08:36 - 02:08:37
不是嗎？臺南的食物都還蠻甜的啊。

02:08:37 - 02:08:40
我是還蠻喜歡的啦，但很多人就不喜歡啊，所以

02:08:41 - 02:08:42
這點也算重大無知。

02:08:43 - 02:08:45
還有像什麼，我還想到一個例子。

02:08:47 - 02:08:48
田徑比賽的時候，

02:08:48 - 02:08:50
裁判手上不是會有一把槍嗎？

02:08:50 - 02:08:53
砰的一聲有煙跑出來，選手起跑嘛，有沒有？

02:08:54 - 02:08:56
我記得我國小的時候，運動會啊，

02:08:57 - 02:08:59
校長當裁判啊，校長手上那把槍啊，

02:08:59 - 02:09:00
砰的一聲選手起跑。

02:09:01 - 02:09:03
那個時候我在臺下，我看了覺得很錯愕。

02:09:04 - 02:09:05
想說為什麼校長可以有槍。

02:09:06 - 02:09:08
我那時候想說校長的槍是哪來的？

02:09:09 - 02:09:10
是警察借他的嗎？

02:09:11 - 02:09:12
我那時候一直這樣想，

02:09:12 - 02:09:13
一直想說是警察借他的嗎？

02:09:14 - 02:09:16
還是怎樣，為什麼校長有槍不會被抓走？

02:09:17 - 02:09:21
後來我才知道，田徑比賽那把槍它不能擊發子彈啦。

02:09:21 - 02:09:24
它就只是一個手槍造型的鞭炮，

02:09:24 - 02:09:26
它只是一個這樣的東西，它本身沒有任何殺傷力。

02:09:26 - 02:09:35
所以各位啊，如果有人以為田徑比賽的裁判手上那把槍是真槍，他把那個槍搶下，他去射殺別人，

02:09:36 - 02:09:38
那個一般也會認為是一種重大無知,

02:09:38 - 02:09:39
懂嗎？這也可以認為是喔。

02:09:40 - 02:09:40
好,

02:09:41 - 02:09:42
所以這個重大無知說,

02:09:43 - 02:09:47
所以反過來喔，我們講，要一般人想說，蛤，這個怎麼那麼蠢啊。

02:09:47 - 02:09:48
這種才算喔，

02:09:48 - 02:09:51
如果只是單純的失誤，

02:09:52 - 02:09:53
這不算喔。

02:09:54 - 02:09:57
比如說，誤算槍枝的射程範圍，

02:09:58 - 02:09:58
這個不算。

02:09:59 - 02:10:00
搞

02:10:00 - 02:10:02
算錯毒品的提煉方式,

02:10:02 - 02:10:05
這也不算，因為一般人不會煉毒，知道嗎？

02:10:05 - 02:10:08
又或者比如說，算錯毒藥的劑量，

02:10:09 - 02:10:11
這當然不算，一樣不算。

02:10:11 - 02:10:17
或者是下毒的時候拿錯，誤把這個腸胃藥當作是毒藥，

02:10:18 - 02:10:21
依然不算，知道嗎，這個認定非常的嚴格，重大無知說。

02:10:22 - 02:10:27
好，所以我們講，這個無危險有這三種不同的說法，

02:10:28 - 02:10:33
那我們來看一下這幾種不同的說法在個案當中會有什麼樣的差異喔。

02:10:33 - 02:10:35
來下面請說，下面幾個案例我們來看一下。

02:10:37 - 02:10:38
第一個來

02:10:38 - 02:10:40
甲對乙起殺意，向乙連開三槍

02:10:41 - 02:10:42
第一槍中乙的心臟

02:10:42 - 02:10:47
丙不知乙已死，為了幫甲，所以又持刀刺乙兩刀。

02:10:48 - 02:10:50
好，我們說這個是客體不能，因為人已經死掉了

02:10:51 - 02:10:51
那有沒有危險？

02:10:52 - 02:10:53
你看嘛，

02:10:54 - 02:10:55
客觀危險說看起來，

02:10:56 - 02:10:58
無危險，人死掉了啊，註定的啊，

02:10:59 - 02:11:26
具體危險

02:11:26 - 02:11:40
說呢

02:11:41 - 02:11:43
旁觀者不知道人死吧,所以有危險,

02:11:44 - 02:11:45
重大無知說呢,

02:11:46 - 02:11:48
這不是重大無知啊,對不對,所以還是有危險喔。

02:11:49 - 02:11:50
好,另外一個案例。

02:11:52 - 02:11:59
甲搶了值勤中乙警察的配槍之後,要殺乙,並且立刻向乙開槍,但這個手槍沒有裝子彈。

02:12:00 - 02:12:03
客觀危險說來看，一樣沒有危險。

02:12:04 - 02:12:05
沒有疑問嘛，對不對？一樣沒有危險，因為這個很明顯。

02:12:07 - 02:12:09
這個自始是註定的。

02:12:10 - 02:12:11
具體危險說呢？

02:12:11 - 02:12:14
旁觀者腦袋知道打多少才會有危險，對不對？

02:12:14 - 02:12:16
所以當然不算嘛,當然是有危險嘛。

02:12:17 - 02:12:18
重大無知說呢?

02:12:19 - 02:12:21
這種醫學知識的不知算重大無知嗎?

02:12:22 - 02:12:25
不算嘛,所以當然還是怎麼樣,有危險,還是有危險。

02:12:26 - 02:12:27
好,所以你開發這邊會發現。

02:12:29 - 02:12:30
具體危險說

02:12:30 - 02:12:32
跟重大無知說，好像結論都差不多。

02:12:34 - 02:12:36
對吧，雖然判斷標準不同。

02:12:36 - 02:12:39
對，沒錯，他們的結論確實還蠻相似的。

02:12:39 - 02:12:43
於是我們來看這兩說在什麼樣的情況會有差呢？

02:12:43 - 02:12:45
來看到第四說。

02:12:45 - 02:12:51
甲要殺乙，卻誤以為罐中的胃腸藥是毒藥。

02:12:51 - 02:12:54
而把這個胃腸藥拿去給乙吃。

02:12:55 - 02:12:58
是這樣啦，就是那一罐，上面就寫金十字胃腸藥。

02:12:59 - 02:13:02
其實呢，裡面也是金十字胃腸藥。

02:13:02 - 02:13:07
但甲記錯了，甲以為金十字胃腸藥裡面裝的是毒藥。

02:13:07 - 02:13:08
大概是這樣的情況。

02:13:10 - 02:13:10
好。

02:13:11 - 02:13:11
那我們說。

02:13:12 - 02:13:14
客觀危險說來看的話，當然無危險吧。

02:13:14 - 02:13:15
因為那個是腸胃藥。

02:13:16 - 02:13:17
具體危險在哪？

02:13:18 - 02:13:19
旁觀者看到的是腸胃藥啊。

02:13:19 - 02:13:20
所以也無危險。

02:13:21 - 02:13:22
可是照重大無知說呢？

02:13:23 - 02:13:24
沒有危險喔。

02:13:24 - 02:13:24
為什麼？

02:13:25 - 02:13:27
因為搞錯裡面裝什麼東西，那個不算重大無知啊。

02:13:28 - 02:13:32
除非他以為金十字胃腸藥可以把人毒死，那是重大無知。

02:13:33 - 02:13:34
可是這一題不是。

02:13:34 - 02:13:38
這一題他只是搞錯那個容器裡面裝的是什麼東西。

02:13:38 - 02:13:40
那個不算，知道嗎，那個不算。

02:13:40 - 02:13:45
所以這個案例，是少數具體危險說跟重大無知說會有差的案例。

02:13:47 - 02:13:47
好。

02:13:48 - 02:13:50
接下來，我們來看到252頁。

02:13:53 - 02:13:54
來看到這個專題研究。

02:13:55 - 02:13:56
迷信犯跟不能未遂。

02:13:58 - 02:14:00
迷信犯這個東西可能很多同學沒聽過。

02:14:00 - 02:14:00
有提過,沒提過沒有關係,因為這是一個非常有年代感的說法。

02:14:04 - 02:14:08
早期的刑法學界會提出所謂迷信犯的概念,什麼意思呢？

02:14:09 - 02:14:16
迷信犯指的是行為人想透過自然科學所無法驗證的方式去實現犯罪，這個叫做迷信犯。

02:14:17 - 02:14:25
好，那就迷信犯來講，迷信犯算不算是不能未遂？

02:14:26 - 02:14:29
我們要談這個問題，迷信犯算不算是不能未遂？

02:14:31 - 02:14:33
其實迷信犯是這樣。

02:14:34 - 02:14:37
第一個問題是要先確認行為人有沒有故意。

02:14:38 - 02:14:38
好，怎麼說呢？

02:14:39 - 02:14:44
我們之前在講故意的時候，跟同學講過一個概念，不知道同學記不記得。

02:14:45 - 02:14:47
我們說單純的願望不是故意。

02:14:48 - 02:14:50
有印象嗎？什麼叫單純的願望非故意？

02:14:50 - 02:14:55
意思就是這件事行為人也無力支配。

02:14:56 - 02:14:58
怎麼這件事情其實是無力支配的。

02:14:58 - 02:15:02
行為人他就只是希望他無力支配的那件事可以偶然地被實現。

02:15:03 - 02:15:04
這個叫單純的願望。

02:15:05 - 02:15:09
比如說你幫你仇人買機票，希望他可以坐上死亡班機。

02:15:09 - 02:15:14
你勸你仇人這個雷雨天出去散步，希望他被雷打死。

02:15:15 - 02:15:19
瞭解吧，這一種叫做單純的願望，他不是故意的。

02:15:21 - 02:15:23
所以這種迷信犯案例也是喔。

02:15:24 - 02:15:28
因為迷信犯案例有些行為人他根本就只是單純的願望而已。

02:15:29 - 02:15:30
比如說。

02:15:30 - 02:15:31
如果啊。

02:15:33 - 02:15:36
那個人一直對我扎稻草人。

02:15:36 - 02:15:40
他口中一直默唸陳介中去死，陳介中去死，他一直在那邊扎稻草人。

02:15:41 - 02:15:45
假設那人的想法一直覺得說這樣扎他就會死嗎？

02:15:46 - 02:15:47
那人也覺得懷疑。

02:15:47 - 02:15:52
但那人想說沒差，多念多健康，反正多念個幾下，他也不會有什麼損失，睡前多念一下也沒差。

02:15:53 - 02:15:55
如果他是這個想法。

02:15:55 - 02:15:56
那當然他沒有故意啊。

02:15:56 - 02:15:57
單純的願望，對不對？

02:15:58 - 02:16:00
但反過來說，如果伊谷真的信。

02:16:00 - 02:16:01
就迷信了。

02:16:01 - 02:16:03
他就是確信這樣插我會死掉,

02:16:03 - 02:16:03
那有沒有故意？

02:16:03 - 02:16:04
有啊。

02:16:04 - 02:16:05
那有故意的話，這個是不能未遂。

02:16:06 - 02:16:07
手段不能嘛。

02:16:07 - 02:16:07
對不對？

02:16:08 - 02:16:08
手段不能...

02:16:08 - 02:16:10
那有沒有危險？

02:16:10 - 02:16:11
當然沒有啊。

02:16:12 - 02:16:15
所以這種迷信犯，如果我們確認他有故意的的話，

02:16:16 - 02:16:17
接下來他有沒有危險？

02:16:17 - 02:16:18
他一定沒有危險，

02:16:18 - 02:16:19
對不對？

02:16:19 - 02:16:22
所以黃老師說其實迷信犯沒有什麼意義啊，他就是一種嚴重的不能未遂，

02:16:22 - 02:16:23
就這樣子而已啊。

02:16:24 - 02:16:25
所以我們在刑法上會這麼說,

02:16:27 - 02:16:32
我們常講說，迷信犯這個東西，不具有規範上的意義。

02:16:32 - 02:16:34
它只是一種現象的描述。

02:16:35 - 02:16:36
什麼叫不具有規範上的意義？

02:16:37 - 02:16:39
意思就是說，你提出迷信犯這個概念，

02:16:39 - 02:16:44
這個概念本身沒有辦法直接得出法律的效果。

02:16:44 - 02:16:45
它有什麼效果？

02:16:46 - 02:16:49
我們還是要依賴原本刑法的概念。

02:16:50 - 02:16:51
所以迷信犯其實沒有意義，你知道嗎？

02:16:52 - 02:16:53
它只是描述一種現象而已。

02:16:54 - 02:16:56
所以在考試上，你不用特別講迷信犯這個東西。

02:16:57 - 02:16:59
現在的學者也不喜歡提它。

02:16:59 - 02:17:11
它就是個

02:17:11 - 02:17:29
過時的概念，

02:17:29 - 02:17:41
知道吧？

02:17:43 - 02:17:45
好，下面這題我們來看一下喔。

02:17:58 - 02:18:00
這題很尷尬啦。

02:18:01 - 02:18:03
題目說日幣沒有2000，其實有了。

02:18:04 - 02:18:05
真的我上網搜尋過，日幣有2000。

02:18:06 - 02:18:07
真的啊，有啊。

02:18:08 - 02:18:09
只是日幣2000很少流通。

02:18:10 - 02:18:14
日幣2000，大概跟我們的臺幣五角一樣罕見。

02:18:15 - 02:18:16
你們用過五角嗎？

02:18:16 - 02:18:17
應該沒有吧。

02:18:18 - 02:18:22
以前八方雲集漲價前，好像水餃一顆五塊半對不對？

02:18:22 - 02:18:24
還是鍋貼一顆五塊半。

02:18:25 - 02:18:27
你就跟他說我要買一顆，看他會回什麼。

02:18:28 - 02:18:29
對啊，你要找我五角。

02:18:30 - 02:18:32
他會覺得你神經病不會理你，對不對？

02:18:33 - 02:18:36
其實五角是我們的法定貨幣啊，是啊，只是幾乎沒有流通啊。

02:18:36 - 02:18:37
日幣2000塊也是。

02:18:38 - 02:18:39
聽說日幣2000塊，有，真的有。

02:18:40 - 02:18:44
只是它非常少流通，頂多在沖繩地區會看到。

02:18:44 - 02:18:51
聽說是這樣啦，所以很多留日的老師甚至日本當地的居民都不知道日幣其實有2000元。

02:18:51 - 02:18:51
好。

02:18:52 - 02:18:53
那這一題我們怎麼寫？

02:18:55 - 02:18:56
你要打臉出題老師嗎？

02:18:57 - 02:18:58
說老師，其實日幣有2000喔。

02:18:59 - 02:19:00
那，那這題就沒得寫，對不對？

02:19:01 - 02:19:03
所以我就說，要相信題目所述為真。

02:19:04 - 02:19:06
以前不是帶各位看過香蕉船那一題嗎？

02:19:07 - 02:19:11
什麼駕駛香蕉船，那香蕉船上還掉像浮板，超不合理，對不對？

02:19:11 - 02:19:13
那相信它是真的，好嗎？

02:19:13 - 02:19:15
所以這一題當中啊，行為人涉及什麼罪？

02:19:17 - 02:19:18
我們看喔。

02:19:19 - 02:19:21
他拿偽鈔要去做兌換。

02:19:22 - 02:19:25
而他以為這個是真鈔。

02:19:26 - 02:19:29
所以理論上來說,這個叫行使偽造有價證券的未遂。

02:19:29 - 02:19:31
但那條罪沒有罰未遂。

02:19:31 - 02:19:34
所以這邊極有可能檢討的是什麼呢?詐欺未遂。

02:19:35 - 02:19:40
所以你想喔,他拿一個不存在的面額的紙鈔,

02:19:40 - 02:19:41
外幣紙鈔,

02:19:42 - 02:19:42
要去兌換。

02:19:43 - 02:19:44
你們就想像一個更極端的案例。

02:19:45 - 02:19:49
有個人,拿著一張面額500塊的美金。

02:19:50 - 02:19:51
面額500哦。

02:19:52 - 02:19:54
正面還有川普的頭像哦。

02:19:54 - 02:19:59
你們想像那個畫面喔，拿了一張面額500塊，而且正面有川普肖像的美金。

02:20:00 - 02:20:03
他拿去銀行說我要兌換成新臺幣。

02:20:03 - 02:20:05
而這個行為人還以為這個真的是美鈔。

02:20:06 - 02:20:07
假設他這樣以為。

02:20:09 - 02:20:10
假設行為人呢。

02:20:10 - 02:20:12
不要講說他以為真的是偽鈔

02:20:12 - 02:20:13
他就覺得這個鈔票怪怪的

02:20:14 - 02:20:15
他想說管他的

02:20:15 - 02:20:16
反正我要拿去換

02:20:16 - 02:20:17
是不是跟這題一樣?

02:20:18 - 02:20:19
那他是不是詐欺未遂？

02:20:19 - 02:20:19
對，

02:20:20 - 02:20:20
他是詐欺未遂。

02:20:22 - 02:20:23
因為銀行行員一定會識破嘛，

02:20:24 - 02:20:24
有沒有危險？

02:20:26 - 02:20:26
手段不能啊,

02:20:27 - 02:20:28
有沒有危險？

02:20:28 - 02:20:28
當然沒有啊,

02:20:28 - 02:20:29
為什麼？

02:20:30 - 02:20:32
因為沒有這個面額。

02:20:32 - 02:20:33
一般人會知道嗎？

02:20:33 - 02:20:33
對啊。

02:20:33 - 02:20:34
一般人會知道啊。

02:20:35 - 02:20:36
而且，

02:20:36 - 02:20:36
而且，

02:20:37 - 02:20:39
旁觀者會不會覺得有危險？

02:20:40 - 02:20:41
當然不會啊，

02:20:41 - 02:20:42
所以這個案例一定是甚麼？

02:20:42 - 02:20:43
不能未遂。

02:20:43 - 02:20:43
知道嗎？

02:20:43 - 02:20:44
這題是不能未遂喔。

02:20:45 - 02:20:45
好,

02:20:47 - 02:20:47
再來,

02:20:48 - 02:20:49
我們來看一個比較難的問題。

02:21:25 - 02:21:27
我們接著要來看這個比較難的問題是,

02:21:28 - 02:21:32
不能為遂要放在三階論的哪裡？

02:21:33 - 02:21:36
這個東西其實是一個很久以前的爭議,

02:21:37 - 02:21:37
這個東西流行,

02:21:38 - 02:21:40
這個爭議流行的時候大概是十幾年前啦,

02:21:40 - 02:21:43
就是2006年刑法剛修正之後,

02:21:43 - 02:21:44
那一陣子有人在探討,

02:21:45 - 02:21:46
但近年的考試,

02:21:46 - 02:21:48
至少在四五年前還是有出,

02:21:48 - 02:21:49
所以我覺得還是有必要來講。

02:21:50 - 02:21:50
來,

02:21:50 - 02:21:51
不能未遂

02:21:51 - 02:21:53
我們要放三階論的哪裡？

02:21:54 - 02:21:54
你看喔

02:21:55 - 02:21:56
26條的不能未遂

02:21:56 - 02:21:57
它的效果叫做不罰

02:21:58 - 02:22:00
我們知道不罰就是無罪。

02:22:00 - 02:22:04
那不法的無罪當然不見得是在哪一個階層啊

02:22:04 - 02:22:07
刑法12條說行為非出於故意或過失不罰

02:22:08 - 02:22:08
那個是什麼問題

02:22:09 - 02:22:10
構成要件不該當,對不對

02:22:11 - 02:22:13
23條說正當防衛不法，那個叫阻卻違法

02:22:14 - 02:22:16
18、19條說無責任的人不法，那個叫阻卻罪責，對不對

02:22:19 - 02:22:23
所以26的不法我們放三階論的哪裡

02:22:24 - 02:22:25
兩大陣營

02:22:26 - 02:22:29
有些人把26的不法放構成要件

02:22:31 - 02:22:32
劉老師居多啦

02:22:33 - 02:22:38
這種說法又可以以另外一個東西為代表性，所謂不能未遂，無著手

02:22:39 - 02:22:40
這個說法什麼意思？

02:22:41 - 02:22:46
剛剛我講在花蓮海邊開槍要打美國人那個例子

02:22:47 - 02:22:48
你們想一想喔

02:22:49 - 02:22:51
採客觀著手理論的話

02:22:52 - 02:22:53
不能未遂有沒有著手

02:22:54 - 02:22:55
沒有,對不對,沒有

02:22:56 - 02:22:57
那著[redacted]　是什麼階層的問題

02:22:58 - 02:22:59
構成要件的問題啊

02:22:59 - 02:23:01
所以這個說法很有趣喔

02:23:01 - 02:23:05
這個說法他覺得不能未遂根本就沒有著手

02:23:06 - 02:23:08
那我們講未遂犯不是四大要件

02:23:09 - 02:23:10
故意,著手,未遂,明文

02:23:11 - 02:23:15
所以不能未遂根本沒有著手,構成要件不該當的話

02:23:16 - 02:23:17
不能未遂還是未遂嗎？

02:23:17 - 02:23:20
其實不是，他只是這個長得跟未遂犯很像的東西，對，沒有錯啊。

02:23:21 - 02:23:26
確實有學者把26條的不能未遂放哪裡？放構成要件。

02:23:27 - 02:23:30
這個說法代表性的一說就是不能未遂，沒有。

02:23:30 - 02:23:30
著手

02:23:31 - 02:23:33
當然還有其他更細緻的區分，但我們不要講那麼細，我們講個大概的方向就好，知道嗎？

02:23:33 - 02:23:37
講太細我怕同學覺得亂，所以有人把不放紅色這一條線，認為不能未遂根本沒有著手，構成要件不該當。

02:23:45 - 02:23:45
好。

02:23:46 - 02:23:49
那目前學理上主流的見解會把不能未遂放在黃色這一條線。

02:23:54 - 02:23:59
這是蔡老師提出的一個說法，蔡聖偉老師提出的說法，叫做事理上的阻卻。

02:24:00 - 02:24:00
刑罰是有的。

02:24:03 - 02:24:05
剛剛我講蔡老師那篇文章叫惡視力，那篇你們真的可以去看，因為我覺得那篇還蠻淺顯的，而且那篇把不能未遂幾個重要的考點都寫出來了，那篇還蠻有趣的。

02:24:15 - 02:24:19
來，蔡聖偉老師，對他來說，不能未遂是他的專長的，因為蔡老師以前在國內念碩士的時候，他的碩論就是寫不能為罪，所以他對這塊非常的有研究。

02:24:27 - 02:24:33
那照蔡聖偉老師的說法，他認為說，不能未遂之所以無罪，跟不法沒有關係，跟罪責也沒有關係。

02:24:36 - 02:24:41
他是純粹基於情勢政策的考量而放棄刑罰。

02:24:42 - 02:24:42
好，怎麼說呢？

02:24:43 - 02:24:44
蔡老師提出的觀點。

02:24:45 - 02:24:52
蔡老師認為啊，處罰未遂犯，是為了要維護行為規範的效力。

02:24:53 - 02:24:54
你說這句話什麼意思？

02:24:54 - 02:24:56
什麼叫維護行為規範的效力？

02:24:57 - 02:25:01
我們講所有的行為規範，不管是法律規範或道德規範都一樣。

02:25:02 - 02:25:04
行為規範要怎麼樣才會有效？

02:25:05 - 02:25:06
就是對違反規範的人要制裁。

02:25:07 - 02:25:08
這樣那個規範才會有效。

02:25:09 - 02:25:14
反過來說，如果你對違反規範的人沒有制裁的話，久而久之，大家就不把規範當一回事了。

02:25:14 - 02:25:15
一定的嘛。

02:25:16 - 02:25:17
我舉一個我氣憤的經驗。

02:25:19 - 02:25:21
我當初大二考上東吳轉學考的時候啊，來到東吳嘛。

02:25:23 - 02:25:27
當時要做一個外語能力的分級測驗，因為大二有英聽課。

02:25:28 - 02:25:29
那我英文本來就沒有很好。

02:25:30 - 02:25:31
啊我也沒有興趣講到英文變好。

02:25:32 - 02:25:33
所以當時那個外語分級測驗呢,

02:25:34 - 02:25:37
會聽得懂的,我故意選錯的。

02:25:38 - 02:25:41
聽不懂的,我故意亂選,選一個不可能的。

02:25:41 - 02:25:44
後來果真如我所願啊,我進到英語初級班,我好高興。

02:25:46 - 02:25:48
教材翻開來超簡單，國中程度我好高興，進到初級班。

02:25:50 - 02:25:53
結果我進到初級班之後啊，我後悔了。

02:25:55 - 02:25:57
因為那個老師感覺非常的龜毛。

02:25:58 - 02:26:00
一般的老師講

02:26:00 - 02:26:00
上課規則

02:26:01 - 02:26:03
頂多講10分鐘20分鐘吧,

02:26:03 - 02:26:08
結果那個老師第一堂課好像花了一堂課還兩堂課的時間在講他的上課規則,

02:26:08 - 02:26:10
我想說天啊,規矩也太多了吧。

02:26:11 - 02:26:12
什麼沒交作業扣分啊,

02:26:12 - 02:26:14
你遲到會怎麼扣分,

02:26:14 - 02:26:15
你曠課又怎麼扣分怎樣怎樣的，

02:26:16 - 02:26:17
講超多規則。

02:26:18 - 02:26:18
當時我就後悔了，

02:26:19 - 02:26:21
我想說我是不是不應該進初級班，我是不是誤上賊船。

02:26:22 - 02:26:23
可是後來發現，

02:26:24 - 02:26:25
這個老師說一套做一套。

02:26:26 - 02:26:27
因為後來我發現，

02:26:28 - 02:26:29
當有同學違規，

02:26:30 - 02:26:31
他也沒有真的制止啊，

02:26:31 - 02:26:32
他也沒有真的扣分啊。

02:26:33 - 02:26:34
比如說後來有同學打瞌睡,

02:26:34 - 02:26:36
老師就嘴說，那幾位同學，

02:26:36 - 02:26:38
醒一醒喔，不要再睡了。

02:26:38 - 02:26:40
然後有同學講話，

02:26:40 - 02:26:41
老師也只說，

02:26:41 - 02:26:43
那幾位同學，你們不要再講話了。

02:26:43 - 02:26:45
所以後來我發現，

02:26:45 - 02:26:46
一整個學年下來，

02:26:46 - 02:26:48
根本沒有人被他扣過分。

02:26:49 - 02:26:51
所以我就心想，那他當初講那麼多規則幹什麼？

02:26:52 - 02:26:54
所以其實這個課到了後期啊,

02:26:54 - 02:26:54
秩序不是很好。

02:26:55 - 02:26:56
大家都發現老師不會扣分嘛,

02:26:57 - 02:26:58
所以大家就隨便了啊。

02:26:58 - 02:27:01
大家所以就想說，那老師一開始講那個規則講那麼多幹嘛？

02:27:02 - 02:27:06
所以反過來說,如果當時英文老師在發現有同學違規之後,

02:27:06 - 02:27:08
老師馬上拿出點名簿,

02:27:08 - 02:27:10
所以那個同學你剛睡很久了喔,

02:27:10 - 02:27:12
不要怪我不客氣喔,扣一分。

02:27:13 - 02:27:14
大家都不敢睡啦,

02:27:14 - 02:27:14
對不對？

02:27:15 - 02:27:17
所以我就說，行為規範要怎麼樣才會有效？

02:27:18 - 02:27:21
對違反規範的人要施以制裁，它才會有效。

02:27:22 - 02:27:22
來，

02:27:23 - 02:27:24
回到刑法當中也是。

02:27:25 - 02:27:26
你們想一件事喔,

02:27:27 - 02:27:31
如果從今以後，未遂犯不被處罰，大家會怎麼想？

02:27:32 - 02:27:33
我就試試看去犯罪。

02:27:34 - 02:27:36
反正人沒死沒有既遂，我就不會有事。

02:27:37 - 02:27:38
那大家就去犯罪啦。

02:27:39 - 02:27:41
那刑法上的規範什麼不可以殺人、不可以竊盜什麼的，

02:27:42 - 02:27:43
就不會有人管他了嘛，

02:27:43 - 02:27:43
對不對？

02:27:44 - 02:27:48
所以如果不處罰未遂犯，確實會導致行為規範失效。

02:27:49 - 02:27:51
進而，為什麼要罰未遂犯？

02:27:51 - 02:27:54
因為要維護行為規範的效力。

02:27:54 - 02:27:56
好，那我們以此來看喔。

02:27:57 - 02:27:58
不能未遂。

02:27:59 - 02:27:59
那各位啊，

02:28:01 - 02:28:04
如果我們的刑法不處罰不能未遂

02:28:05 - 02:28:08
會影響行為規範的效力嗎？

02:28:08 - 02:28:15
好，當你聽說有個人想用彈弓射下民航機，而且這個人他真的確信他的彈弓可以把民航機打下來喔。

02:28:16 - 02:28:19
當你聽到這個人沒有被處罰的時候，你會想試試看嗎？

02:28:20 - 02:28:22
不會，你會覺得那個人是智障，對吧？

02:28:22 - 02:28:29
或者比如說，當有人想用全糖的飲料毒殺糖尿病的病患，而這個人沒有被處罰。

02:28:30 - 02:28:32
難道你會想說，我也要試試看？

02:28:32 - 02:28:34
不會啊，你會覺得那個人無聊，對吧？

02:28:34 - 02:28:37
所以蔡老師的說法就是，為什麼不罰未遂犯？

02:28:38 - 02:28:39
跟違法跟罪責沒有關係了

02:28:40 - 02:28:44
而是從形式政策的角度來講，這種重大無知的行為

02:28:45 - 02:28:48
就算不罰他，也不會有人想模仿啊

02:28:48 - 02:28:51
他不會破壞行為規範的效力啊，那你罰他幹什麼，對不對

02:28:51 - 02:28:53
所以他把不能未遂放哪裡，放三階外面

02:28:54 - 02:28:56
放在黃色這條線，三階外面

02:28:57 - 02:28:57
好

02:28:58 - 02:29:00
所以不能未遂放哪裡,大概有這兩說

02:29:01 - 02:29:02
好,區別實益在哪裡

02:29:04 - 02:29:05
我這邊列一跟二,對不對

02:29:05 - 02:29:08
我跟各位說,主要的區別實益是一二,一其實還好

02:29:11 - 02:29:12
主要的實益是一二

02:29:14 - 02:29:14
也就是

02:29:14 - 02:29:18
對不能未遂，可不可以成立共犯，主要的實益在這邊，共犯

02:29:19 - 02:29:19
好，為什麼

02:29:23 - 02:29:24
先跟各位講，共犯，就是教唆跟幫助

02:29:27 - 02:29:30
要成立教唆犯，要成立幫助犯，怎麼樣

02:29:30 - 02:29:33
必須那個正犯有該當且違法

02:29:34 - 02:29:34
這才可以，知道嗎

02:29:35 - 02:29:35
再講一次喔

02:29:36 - 02:29:44
要成立教唆犯，要成立幫助犯，必須那個被教唆被幫助的正犯，該當且違法

02:29:45 - 02:29:46
這樣共犯才能成立，知道嗎

02:29:47 - 02:29:48
我們先確定這意思，所以各位啊

02:29:49 - 02:29:53
那個流浪漢被小屁孩欺負，我跟流浪漢說，你怎麼不打回去？

02:29:56 - 02:29:58
然後我還給他一根棍子，流浪漢果真

02:30:00 - 02:30:02
就把欺負他的小屁孩痛打一頓了

02:30:02 - 02:30:06
這樣的情況，我會成立傷害罪的教唆犯跟幫助犯嗎？

02:30:07 - 02:30:07
不會，為什麼？

02:30:08 - 02:30:10
因為流浪漢打回去，那個叫正當防衛。

02:30:11 - 02:30:13
我幫助別人做什麼？

02:30:13 - 02:30:14
合法行為啊。

02:30:14 - 02:30:14
這不會有共犯，知道吧？

02:30:14 - 02:30:21
所以我們講,要成立共犯,必須正犯該當且違法,這個叫做共犯從屬性

02:30:21 - 02:30:23
好,所以各位你看黑板

02:30:24 - 02:30:31
那如果行為人教唆幫助別人做一個不能未遂的行為呢?

02:30:31 - 02:30:32
好,舉例

02:30:34 - 02:30:40
假設我是個超迷信的人,我確信扎稻草人可以把人扎死

02:30:41 - 02:30:46
於是，我出於要讓陸伯言死於非命的想法

02:30:47 - 02:30:48
我想被他扎稻草人

02:30:49 - 02:30:50
但是我沒有草人

02:30:51 - 02:30:57
於是我去我家附近的神壇，跟裡面的那個神壇的主持人講我的計畫，說

02:30:57 - 02:31:00
那個師父啊，你可不可以給我幾個稻草人？

02:31:00 - 02:31:05
神壇的主持人聽到我的計畫之後，二話不說，拿了十個稻草人給我

02:31:05 - 02:31:06
我就真的回去狂扎

02:31:07 - 02:31:09
這樣的話，我叫殺人犯不能未遂對不對？

02:31:10 - 02:31:13
那個神壇的師傅會不會成立殺人未遂的幫助犯？

02:31:14 - 02:31:15
他不能未遂放哪裡啊？

02:31:16 - 02:31:16
知道吧？

02:31:17 - 02:31:19
如果不能未遂放紅色這一條線

02:31:21 - 02:31:23
那我扎稻草人根本共識要了解不該當

02:31:24 - 02:31:25
他怎麼論共犯，瞭解吧？

02:31:26 - 02:31:33
可是如果不能未遂放黃色這一條線的話，我扎稻草人是該當違法且有責，只是三千元以下無罪喔

02:31:34 - 02:31:35
那那個師傅可不可能幫助犯人?

02:31:36 - 02:31:36
可以啊

02:31:37 - 02:31:37
瞭解吧?

02:31:37 - 02:31:39
主要的實益在這個地方,OK,主要實益在這個地方

02:31:39 - 02:31:41
這以前國考有考過

02:31:43 - 02:31:44
相對的

02:31:44 - 02:31:45
括號一

02:31:46 - 02:31:48
可不可以對不能未遂正當防衛？

02:31:48 - 02:31:50
我跟你講，這個東西現在大家比較不覺得它是個實益

02:31:52 - 02:31:54
我們連接到前面的概念

02:32:11 - 02:32:15
來147頁中間假侵害。

02:32:17 - 02:32:18
我們連接到這個概念。

02:32:20 - 02:32:23
你寫一下，哪些不能為正當防衛，你就寫147。

02:32:23 - 02:32:26
P147，然後旁邊寫假侵害。

02:32:27 - 02:32:28
我們連接到這個概念。

02:32:30 - 02:32:30
然後跟妳說。

02:32:33 - 02:32:35
現在的看法會覺得。

02:32:36 - 02:32:38
對不能未遂、不能正當防衛。

02:32:39 - 02:32:40
這是現在主流的意見。

02:32:41 - 02:32:43
以前有一些爭執，但現在意見這樣。

02:32:43 - 02:32:45
不能對不能為正當防衛,為什麼？

02:32:46 - 02:32:48
因為現在的說法是好。

02:32:48 - 02:32:50
就算你把不能未遂放在三界外。

02:32:51 - 02:32:54
說他該當違法且有責,只是阻卻其發動,就算你採這個說法好了。

02:32:56 - 02:32:59
可是問題在於不能未遂,他對法益沒有危險。

02:33:00 - 02:33:01
他哪叫侵害？

02:33:02 - 02:33:04
我的意思是，因為正當防衛要對現在不法侵害。

02:33:04 - 02:33:06
好，就算不得為是一個不法的行為。

02:33:07 - 02:33:08
可是他不叫侵害啊。

02:33:09 - 02:33:10
他有什麼危險，我的意思是。

02:33:11 - 02:33:17
所以比如說,如果我在諮詢室對路伯言狂扎稻草人,那稻草人上面寫劉珞亦,有他的生辰八字,我在那邊狂扎狂扎,然後一直念念有詞,去死去死死。

02:33:24 - 02:33:25
陸伯言看到了超火。

02:33:26 - 02:33:27
想把我的稻草人拿走正當防衛可不可以？

02:33:28 - 02:33:29
不可以喔,為什麼？

02:33:31 - 02:33:31
你看黑板。

02:33:33 - 02:33:35
如果不能未遂放紅色這一條線。

02:33:36 - 02:33:37
那他當然不能正當防衛嘛。

02:33:38 - 02:33:41
因為連輕微侵害都不該當，連不法都沒有啊，對不對？

02:33:42 - 02:33:45
那如果不能未遂放黃色這條線，路人可不可以阻擋正當防衛？

02:33:46 - 02:33:47
一樣不可以啦，為什麼？

02:33:48 - 02:33:49
雖然他不法沒有錯。

02:33:50 - 02:33:52
可是我扎稻草人對路人又會怎樣？

02:33:53 - 02:33:54
不會怎樣啦，那哪叫侵害，瞭解吧。

02:33:55 - 02:33:59
所以現在多數的說法是，就算不能未遂放黃色，一樣是這樣。

02:34:00 - 02:34:00
不一樣。

02:34:00 - 02:34:01
不能正當防衛，

02:34:01 - 02:34:01
為什麼？

02:34:02 - 02:34:02
他不構成威脅啊，

02:34:03 - 02:34:03
你給人家防衛幹什麼？

02:34:04 - 02:34:05
是現在多數的說法。

02:34:05 - 02:34:05
懂嗎？

02:34:05 - 02:34:09
所以其實真正的區別是一會集中在哪裡？

02:34:09 - 02:34:10
共犯，

02:34:10 - 02:34:11
集中在共犯。

02:34:12 - 02:34:12
好。

02:34:12 - 02:34:14
下課前我勾幾個題目你們回去看。

02:34:21 - 02:34:22
那個題目本,

02:34:33 - 02:34:34
來，剛剛那個，

02:34:34 - 02:34:36
我們講不能未遂的定位，

02:34:36 - 02:34:38
對於共犯的影響。

02:34:39 - 02:34:42
剛剛課本255頁那個花生牛奶那一題，

02:34:42 - 02:34:43
那個是一個例子，

02:34:43 - 02:34:44
那個我們明天會講。

02:34:45 - 02:34:46
然後再來，

02:34:47 - 02:34:48
另外一個題目是在，

02:34:49 - 02:34:49
我看一下喔。

02:34:51 - 02:34:55
在課本的20頁第16題。

02:34:56 - 02:34:58
20頁16題，

02:34:58 - 02:34:58
不是課本，

02:34:58 - 02:34:59
題目本啦。

02:34:59 - 02:35:23
題目本的20頁

02:35:23 - 02:35:40
第16題。

02:35:41 - 02:35:42
那一題很重要，

02:35:42 - 02:35:43
那一題你們回去看，

02:35:43 - 02:35:44
我明天講，

02:35:44 - 02:35:45
20頁16題。

02:35:46 - 02:35:46
這題還滿重要的。

02:35:47 - 02:35:49
然後其他的考題的話，

02:35:49 - 02:35:50
我看喔，

02:35:51 - 02:35:51
其他的，

02:35:52 - 02:35:59
其他我看有沒有什麼特別要你們回去看的。